

张明楷讲义 · 答案讲解

整理自张明楷《刑法学》第七版全九章 + 绪论 Flash Cards 背面

目录

- 绪论
 - 第一节刑法学与刑事法学
 - 第二节刑法解释论与刑法立法论
 - 第三节刑法解释学与刑法教义学
 - 第四节刑法解释学与刑法哲学
 - 第五节刑法解释学与社科法学
 - 第六节学派之争与学术发展
 - 当代刑法理论的论争
 - 我国刑法理论现状
 - 第七节理论体系与研究方法
 - 自测卡专区
- 第一章刑法概说
 - 第一节刑法的概念、渊源与分类
 - 第二节刑法的性质、机能与目的
 - 第三节刑法的制定、修改与根据
 - 第四节刑法的规范、体系与解释
 - 自测卡专区
- 第二章刑法的基本原则
 - 第一节刑法的基本原则概述
 - 第二节罪刑法定原则
 - 第三节法益保护原则
 - 第四节责任主义原则
 - 自测卡专区
- 第三章刑法的适用范围
 - 第一节刑法的空间适用范围
 - 第二节刑法的时间适用范围
- 第四章犯罪概说
 - 第一节犯罪的一般概念
 - 第二节犯罪的基本分类
 - 第三节犯罪的成立条件
 - 本章核心概念串讲
- 第五章不法

- 第一节不法概述
- 第二节构成要件符合性
- 第三节违法阻却事由
- 全章综合
- 第六章责任
 - 第一节责任概述
 - 第二节积极的责任要素
 - 第三节消极的责任要素
 - 全章综合
- 第七章犯罪的特殊形态
 - 第一节犯罪的特殊形态概述
 - 第二节犯罪预备
 - 第三节犯罪未遂
 - 第四节不能犯
 - 第五节犯罪中止
 - 全章综合
 - 自测卡专区
- 第八章共同犯罪
 - 第一节共同犯罪的理论前提
 - 狭义的共犯
 - 全章综合
 - 自测卡专区
- 第九章罪数
 - 罪数概说
 - 单纯的一罪
 - 包括的一罪与科刑的一罪
 - 全章综合
 - 自测卡专区

绪论

第一节 刑法学与刑事法学

刑法学有哪三层含义？张明楷这本书定位于哪一层？

填空：

1. 最广义的刑法学 = 实体刑法规范 + 犯罪原因与对策 + 刑事诉讼程序 + 刑罚执行 等一切研究犯罪及其法律后果的学科
2. 广义的刑法学 = 刑法解释学 + 刑法哲学（或理论刑法学） + 刑法史学 + 比较刑法学

3. 狭义的刑法学 = 仅指刑法解释学

4. 本书定位：刑法解释学与刑法哲学的统一体，必要时涉及刑法史学与比较刑法学

...

💡 记忆窍门：最广义 = "犯罪+刑罚+程序+执行"全包 → 像一个大筐什么都往里装；狭义 = 只研究怎么理解和适用法条 → 一门手艺活；本书走中间路线 → 手艺活得有理有据。

举例：你想搞懂"故意杀人罪"，狭义刑法学只告诉你第232条怎么用；本书还会追问：凭什么杀人就该判死刑？这个刑罚的目的是什么？古代中国怎么处理杀人的？（刑法哲学+刑法史学）

刑法学和犯罪学有什么区别和联系？填空：

区别：

- 犯罪学研究的是犯罪原因与对策，属于事实学（做经验研究）
- 刑法学研究的是刑法规范和理论，不直接研究犯罪原因
- 犯罪学的对策范围更广，刑法学只研究刑罚和保安处分为手段的对策

联系：犯罪学给刑法学提供经验素材，为刑事政策制定和刑罚制度改革奠定基础

...

💡 打个比方：犯罪学像医生研究病因（为什么有人高血压？遗传、饮食、压力...）；刑法学像药典编写者（高血压该吃什么药、剂量多少）。医生不直接开药方，但药方得建立在医生的病因研究上。

🌟 小预告：后面第五～六章讲"不法"和"责任"时，很多判断标准（如"期待可能性"、"违法性认识"）其实都隐含了对"人为什么会犯罪"的经验判断——这就是犯罪学对刑法解释学的渗透。

第二节 刑法解释论与刑法立法论

刑法学的本体是解释论（刑法解释学）。解释论和立法论的根本区别是什么？为什么张明楷说"所谓的刑法缺陷，大体上都是解释者解释出来的"？

解释论和立法论的根本区别：解释论是在法哲学指导下，基于社会生活事实、联系具体案例，对现有刑法规范做出解释，发现真实含义；立法论是批评现行刑法的缺陷，提出修改建议。

为什么说"缺陷是解释出来的"？因为除了数字等极少数实在无法解释的用语，刑法的任何用语都有很大的解释空间。很多人还没认真解释，就急着下结论说"法条有问题，得改"。实际上，通过妥当解释，大多数"缺陷"都可以被消化。

...

举例：刑法有"财物"概念，传统上财物 = 有体物。有人说"QQ靓号、游戏装备不是财物，所以盗窃虚拟财产无法定罪——这法条有缺陷！"但张明楷会反问：你为什么不能把"财物"解释得更宽一点？"财物"在今天的含义和一百年前能一样吗？社会的"财产"形态变了，解释也可以跟着变。

💡 刑法完善的真正路径是：立法→解释→司法实践反馈→立法修正→再解释→再反馈……像呼吸一样循环往复，而不是"一有问题就喊改法"。

填空：解释性的批判不同于立法论。凡是通过解释使刑法条文适应社会生活事实的，就不应当主张修改刑法。

...

深层逻辑：

- 解释本身就包含了批判，但这种批判不是指修改法条，而是通过解释得出合理的结论
- 如终身监禁：从刑法第383条获得了"形式的合理性"，但还需要追问"这个规定有没有正当化根据？"——这是解释学层面的深层批判

举例：法官拿到一个案子，法条字面含义如果机械套用会导致荒谬结果——法官不用等立法机关改法，而是可以在合理范围内灵活解释，这就是"将批判寓于解释之中"。

💡 一句话记：解释做得好，改法就没那么急。刑法学者首先要当"解释大师"，别一上来就当"批评家"。

第三节 刑法解释学与刑法教义学

刑法解释学和刑法教义学是什么关系？张明楷为什么认为"没有必要区分"二者？

刑法教义学原本就是刑法解释学。二者没有必要区分，也不要再在解释学之外另建一门教义学。

...

"教义学" (Dogmatik) 源自希腊语 Dogma，意思是"基本确信"、"信仰规则"——不是通过理性证明，而是通过权威宣言来排除怀疑。法律教义学三种活动的混合体：（1）描述现行有效法律、（2）对法律做概念-体系研究、（3）提出解决疑难案件的建议。

三点主张：

1. 不需要区分：德国、日本的刑法教科书既是教义学也是解释学，不能硬分为"你的书是教义学，我的书是解释学"
2. 不能另起炉灶：不要在解释学之外再建一门教义学
3. 改名不能进步：把"解释学"改成"教义学"不等于学术飞跃——"解释目标、解释方法、解释理由"不可能被"教义目标、教义方法、教义理由"替代

💡 记忆：解释学和教义学就像"水"和" H_2O "——同一个东西的两种叫法。不会因为你用化学式称呼它就变成另一种液体。

第四节 刑法解释学与刑法哲学

解释学和哲学之间是什么关系？张明楷用哪一句话概括了二者的不可分割性？

解释学和哲学是鱼水关系，二者缺一不可。张明楷用一句话概括："没有诠释的分析是空泛的，没有分析的诠释是盲目的。"

...

- 离开哲学的解释学：没有哲学基础，容易就事论事，难以深入。比如只会套法条，不知道"为什么要这么规定"
- 离开解释学的哲学：没有具体法条支撑，容易空泛议论。比如大谈"正义"而不落在具体罪名上

本书立场：以自然法学、实证主义法学与社会法学相协调的法哲学观念指导刑法解释。

补充：解释学不是低层次学问。从希腊神谕→圣经诠释→哲学本体论（海德格尔、伽达默尔）→语言与存在的统一（利科尔），解释学走过的路标明——它从一开始就是哲学的核心关切。刑法解释学同样深含哲学原理。

💡 一句话记：解释是血肉，哲学是骨架。没有骨头的肉是摊烂泥；没有肉的骨头是骷髅。

第五节 刑法解释学与社科法学

"社科法学 vs 法教义学"之争中，张明楷的四点主张是什么？填空：

1. 不应当贬低法教义学
2. 永远需要法教义学，不可能用社科法学取代法教义学
3. 法教义学与社科法学的完全融合是不可能的
4. 法教义学与社科法学不是对立的

...

1. 不应当贬低法教义学——它为法科学生和实务人员提供了无穷无尽的便利
2. 永远需要法教义学，不可能用社科法学取代法教义学
3. 法教义学与社科法学的完全融合是不可能的——前者是规范研究/文本研究（创造原理），后者是事实研究（关注事实而非抽象）
4. 法教义学与社科法学不是对立的——刑法学原本就包括社科法学内容（如犯罪学、因果关系判断中引入流行病学方法）

关键反驳：批评者说法教义学是"封闭的规范系统"、"只看书本不看实践"——张明楷反驳：法教义学从来就是向生活事实开放的！社会变迁必然导致法条含义变迁，任何解释结论都不是终局真理。

💡 做减法记：别把教义学和社科法学当敌人，它们本来就是一家的。学科标签之争不如实际问题重要。

第六节 学派之争与学术发展

旧派要反对的是封建刑法的哪四个特点？这四个特点背后最根本的原因是什么？

封建刑法有四大特点：干涉性、恣意性、身份性、残酷性。根本原因是国家权力的集中性、庞大性与绝对性——国家是个人生活的唯一场所，个人极为渺小。

...

1. 干涉性：刑法干涉个人生活的所有领域（你信什么教、谈什么恋爱，国家都要管）
2. 恣意性：对什么行为处以什么刑罚，事前没有法律明文规定——皇帝/国王说了算
3. 身份性：你是贵族还是平民，决定了处罚的有无和轻重
4. 残酷性：刑罚大部分是死刑与身体刑（砍头、剁手、烙刑……）

举例：在封建时代，平民偷了一块面包可能被绞死，贵族杀了平民可能只是被罚一笔钱。法律不是保护所有人的，而是保护等级制度的。

💡 思考：旧派为什么要“反封建”？因为它要证明——国家权力是国民给的（社会契约论），所以国家的刑罚权不能无限制地扩张。罪刑法定、法益保护、责任主义——这三根柱子就是旧派为了限制国家刑罚权打下的。

前期旧派的五大基本观点是什么？（填关键词）

1. 思想基础：个人主义和自由主义
2. 对人的假设：人都有理性和自由意志
3. 刑事责任的基础：行为及其实害（客观主义）
4. 责任的本质：道义责任论
5. 刑罚的正当化根据：报应的正义性（报应刑论）

...

1. 思想基础：个人主义和自由主义——人的存在本身就是目的，国家权力应当尽可能少地限制个人自由
2. 对人的假设：人都有理性和自由意志——可以自主选择做好事还是做坏事
3. 刑事责任的基础：行为及其实害（客观主义）——不能因为“你有恶的思想”就处罚你
4. 责任的本质：道义责任论——对基于自由意志所做的客观不法行为，可以进行非难和谴责
5. 刑罚的正当化根据：报应的正义性（报应刑论）——恶有恶报，善有善报；刑罚与罪行等价

代表人物：费尔巴哈（德国）——罪刑法定主义之父，三重限制国家刑罚权；泷川幸辰（日本）——认为"刑法是犯人的大宪章"，刑法存在的理由在于保障犯人的权利。

💡 像一组锁链：限制自由？不行！→ 罚内心的恶？不行！→ 罚没有报应基础？不行！→ 每一步都在为国家刑罚权设限。

新派（近代学派）是在什么背景下产生的？两个原因分别是什么？

新派产生于19世纪中叶以后欧洲大陆大工业发展、犯罪率飙升的大背景下。两个原因分别是：1. 现实原因——旧刑法对累犯、常习犯、少年犯束手无策，社会防卫呼声高涨。2. 理论原因——犯罪学的发达（凯特勒统计证明犯罪有社会原因、龙勃罗梭提出"天生犯罪人"、实证哲学推动）。

...

1. 现实原因——旧刑法"不管用"了

- 1871年德国新刑法典对累犯、常习犯、少年犯没有任何专门规定
- 人们发现：旧派那套"自由意志+报应刑"在面对来势汹汹的新型犯罪时束手无策→社会防卫的呼声高涨

2. 理论原因——犯罪学的发达

- 凯特勒（统计学）：用数据证明犯罪有社会原因（不是自由意志）
- 龙勃罗梭（犯罪人类学）：提出"天生犯罪人"概念（遗传学原因！）
- 菲利（犯罪社会学）：强调社会原因+物理原因
- 李斯特（德国综合）：重视预防犯罪人重新犯罪的刑罚目的
- 背后还有实证哲学的推动——一切知识必须以观察到的事实为基础

💡 一波接一波：先有社会危机（工业革命带来犯罪潮）→ 社会呼吁"防卫！" → 科学家们出来说"犯罪不是自由意志决定的，是有原因的" → 新派应运而生。像天气变冷了，自然有人发明暖气。

🌐 小预告：新派虽然在犯罪论中退出了历史舞台（第五章会讲），但在刑罚论中留下了印记——今天的刑罚不只是"报应"，还要考虑"预防"（相对报应刑论）。这就是新派的遗产。

新派的五大基本观点是什么？（填关键词，与旧派对比记忆）

1. 国家目的：社会利益优先（社会本位）
2. 对人的假设：否认自由意志（决定论）
3. 刑事责任的基础：犯罪人的危险性格（主观主义）
4. 责任的本质：社会责任论
5. 刑罚的正当化根据：目的的正当性（目的刑论）

...

1. 国家目的：社会利益优先（社会本位）

2. 对人的假设：否认自由意志（决定论）——"人的任何行为均系人格与人所处的环境相互作用的结果"（菲利）
3. 刑事责任的基础：犯罪人的危险性格（主观主义）——外部行为只是发现危险性格的"表征"（征表说）
4. 责任的本质：社会责任论——犯罪人因为性格上有危险性，所以处于承受社会防卫处分的地位
5. 刑罚的正当化根据：目的的正当性（目的刑论）——不是为了报应，而是为了让他不再犯罪（特殊预防）

💡 新旧五对五，可用口诀同时记：旧派个人、自由意志、行为、报应；新派社会、决定论、行为人、目的。看看"报应 vs 目的"——旧派说"你该的"，新派说"治好了就行"。

前期旧派 vs 后期旧派有什么不同？为什么后期旧派在"反新派"的同时又背离了前期旧派的某些初心？

背景设置题——后期旧派的前期旧派的"变体"，变了什么？

1. 法与伦理的关系：前期严格区分，后期同等看待
 2. 自由意志的含义：前期是合理权衡利害的能力，后期是形而上学的、没有原因的自由意志
 3. 报应的理解：前期以一般预防为目的，后期带强烈的绝对报应、赎罪色彩
 4. 整体倾向：后期有明显的国家主义、权威主义倾向
- ...

1. 法与伦理的关系：前期严格区分，后期同等看待——后期旧派往国家道德主义退了半步
2. 自由意志的含义：前期是合理权衡利害的能力（哪种选择更有利就选哪种），后期是形而上学的、没有原因的自由意志——变得更玄了
3. 报应的理解：前期以一般预防为目的，后期带强烈的绝对报应、赎罪色彩——变得更"狠"了
4. 整体倾向：后期有明显的国家主义、权威主义倾向

为什么会有这种变化？以19世纪40年代普鲁士国家主义为背景形成的黑格尔学派深刻影响了后期旧派。落后的资本主义国家要追赶先进国，需要国家出面整合资源，但又又要保障个人自由活动以激发经济活力——这种"国家自由主义"的矛盾心态就是后期旧派的精神底色。

💡 一言蔽之：前期旧派是"反封建的自由派"；后期旧派是"带国家主义色彩的保守自由派"。骨子里仍有自由主义的一面（如要求刑罚与责任相适应），但态度比前期"硬"多了。

旧派与新派的本质区别是什么？用一句话概括。

然后思考这个"反转"：为什么旧派研究抽象人却具体适用，新派研究具体人却抽象适用？

旧派重规范，新派重事实。

. . .

展开理解——

- 旧派从刑法规范出发，规范是针对一般人制定的→研究时用"抽象人"；但适用于具体个案时，又结合具体人的知能水平来判断（如：判断A能不能预见结果→看A本人的智力水平）
- 新派从事实出发，认为每个人都是不同的（有人天生就有犯罪倾向）→研究时用"具体人"；但为了保护社会，适用时又以一般人标准要求所有人（如：判断A能不能预见结果→看一般人能不能预见，一般人能预见=A就有过失）

这就是"双重反转"：

学派	研究其理论根基时	适用规范于个案时
旧派	用抽象人、一般人	用具体人、个别人
新派	用具体人、个别人	用抽象人、一般人

💡 如果你觉得这个反转别扭——那就对了。这就是很多学者批评新派的地方：你口口声声说每个人都不一样，结果判案的时候又拿"一般人标准"来衡量？这不自相矛盾吗？

填空：张明楷认为，旧派与新派的初始对立实际上是对刑法解释学与犯罪学的侧重不同。

旧派的学说本质上是标准的刑法解释学，注重研究刑法规范；新派的初始学说基本上只是犯罪学，注重研究犯罪原因和犯罪对策。

最终结论："现代学派刑法理论的基本架构，实为旧派所建构。"

. . .

- 旧派的学说本质上是标准的刑法解释学：注重研究刑法规范，犯罪表现为行为→所以旧派重视行为；刑法规定的是刑罚→所以旧派只研究刑罚作为对策
- 新派的初始学说基本上只是犯罪学：注重研究犯罪原因和犯罪对策；要研究犯罪原因就必须研究犯罪人→所以新派重视行为人；作为犯罪对策不能只用刑罚→所以新派主张更广泛的社会对策

最终结论："现代学派刑法理论的基本架构，实为旧派所建构。"新派并没有形成自己完整的理论体系，只是基于自己的立场对旧派架构缝缝补补。

💡 像建房子：旧派搭好了整个房子的架构（犯罪论体系）；新派来说"你这家具体有问题，得换"、"你这面墙颜色不对"——但没有重建整栋房子的能力。

当代刑法理论的论争

犯罪论领域的当代两大对立是什么？各自怎么定义违法性的根据？

犯罪论领域的当代两大对立是：1. 结果无价值论 vs 行为无价值论（关于违法性的根据）。2. 实质解释论 vs 形式解释论（关于构成要件的解释方法）。张明楷分别采取结果无价值论和实质解释论。

...

1. 结果无价值论 vs 行为无价值论

- 结果无价值论：违法性的根据 = 行为对法益的侵害及其危险结果（结果恶才是违法性的根据）
- 行为无价值论：违法性的根据 = 行为本身的样态（反伦理性、违反行为规范等）+ 行为时的心情（行为本身恶是违法性的根据）
- 张明楷采取：结果无价值论

2. 实质解释论 vs 形式解释论

- 实质解释论：以犯罪的本质为指导来解释构成要件，将不值得科处刑罚的行为排除在构成要件之外
- 形式解释论：对构成要件做形式化解释，文字是什么就是什么
- 张明楷采取：实质解释论 —— 因为构成要件是"违法类型"，解释时当然要以违法的实质为指导

💡 一块蛋糕：行为无价值论者说"用不干净的手拿到的蛋糕，即使肚子上没坏，也是坏的"；结果无价值论者说"管你怎么拿的，蛋糕本身没坏就没问题"。张明楷站后者——看结果，不看姿势。

我国刑法理论现状

我国刑法理论的现状如何？（三问）

1. 传统刑法理论受哪个国家的影响最大？现在又受了哪些国家的影响？
2. 犯罪论体系方面，多数学者采用的是什么体系？
3. 为什么说"我国还没有形成学派之争"？为什么学派之争是好事？
4. 传统上明显受苏联刑法学说影响；现在同时受德国、日本刑法理论影响，但尚未形成自主的刑法学知识体系。
5. 犯罪论体系方面：多数学者仍采用源于苏联的四要件体系；也有学者主张采用德国的三阶层体系或融合改良。
6. 没有形成学派之争，但多方面存在激烈争论。学派之争能将刑法理论引向深入，有利于刑事立法完善与刑事司法公正。

...

为什么我们缺少学派之争？张明楷诊断：我国刑法理论缺乏理论根基的争论，存在具体结论与基本立场不一致的现象，尤其缺少真正的学术创新。学术创新靠的是学者之间的批评和对话，而不是"不争论、求共识"。共识是暂时的，不可能是永久性的——刑法学就是在"形成共识→推翻共识→再形成新共识"的循环中前进的。

💡 观点之争不是窝里斗，是磨刀石。没有学派之争的学界，就像没有对手的运动员——永远破不了纪录。

第七节 理论体系与研究方法

张明楷的刑法学总论体系是如何构成的？每个部分的核心概念对是什么？

填空：

- 刑法基础论的两个核心概念：法益保护与人权保障
- 犯罪论的两个核心概念：不法与责任
- 法律后果论的两个核心概念：责任刑（报应刑）与预防刑（目的刑）

张明楷为什么把传统的"刑事责任"换成"法律后果"？

张明楷的刑法学总论体系由三大模块构成：

1. 刑法基础论：核心概念 = 法益保护 + 人权保障
2. 犯罪论：核心概念 = 不法 + 责任
3. 法律后果论：核心概念 = 责任刑（报应刑） + 预防刑（目的刑）

这三个模块及其核心概念是整个刑法总论的骨架。

...

为什么换成"法律后果论"？

- 张明楷在"非难可能性"意义上使用"责任"一词（你在犯罪论里是有责任的 = 你可以被谴责）
- 但传统的"刑事责任"是犯罪的法律后果（刑罚、非刑罚处罚、单纯宣告有罪）
- 这两个"责任"含义不同，为避免混淆，犯罪论后的第三编叫做"法律后果论"

💡 三块拼图：基础论 = 游戏规则；犯罪论 = 你有没有犯规；法律后果论 = 犯规了怎么罚。整本书就是这三块拼成。考试时记住每一块的"二字经"概念对。

🌟 小预告（五种研究方法）：①注释研究法（分析条文） ②哲学研究法（用法哲学原理指导） ③历史研究法（弄清刑法的来龙去脉） ④比较研究法（对照不同国家不同时期的刑法） ⑤社会学研究法（考察刑法与社会现象的互动）。这些方法渗透在后续每一章中，比如下一章讲"刑法的适用范围"就会用到比较研究法和历史研究法。

自测卡专区

选择题。关于刑法学的含义，下列哪一说法不正确？

A. 最广义的刑法学（刑事法学）包括犯罪原因与对策、刑事诉讼程序、刑罚执行等内容



B. 狭义的刑法学仅指刑法解释学 

- C. 本书定位为刑法解释学与刑法哲学的统一体，完全不涉及刑法史学与比较刑法学 ✖
- D. 犯罪学属于事实学，进行经验研究；而刑法学属于规范学 ✔

答案：C

...

💡 张明楷原文："本书尝试一种中间意义的刑法学，即刑法解释学与刑法哲学的统一体，但必要时仍然会涉及刑法史学与比较刑法学。"陷阱在副词"完全不"——实际是"必要时仍然会"。

选择题。关于法教义学与社科法学之争，张明楷的四点主张中，下列哪一项表述错误？

- A. 不应当贬低法教义学 ✔
- B. 永远需要法教义学，不可能用社科法学取代法教义学 ✔
- C. 法教义学与社科法学可以完全融合 ✖（完全融合是"不可能"的）
- D. 法教义学与社科法学不是对立的 ✔

答案：C

...

💡 张明楷原文："法教义学与社科法学的完全融合是不可能的。法教义学是一种规范研究或文本研究，关注的是通过永远面向抽象化的过程来创造原理；而社科法学强调的是一种相反的途径，要求人们关注事实而非抽象。"

判断对错（T/F）。请判断以下关于学派之争的说法是否正确。

1. (T) 旧派主张报应刑论，新派主张目的刑论。（"恶有恶报"vs"治好了就行"）
2. (T) 就犯罪论而言，新派已经退出了历史舞台，当今主要是结果无价值论与行为无价值论之争。
3. (F) 张明楷认为，中国的刑法理论已经形成了成熟的学派之争。（原文："还没有形成学派之争"）
4. (F) 前期旧派与后期旧派在法与伦理的关系上观点一致。（前期严格区分，后期同等看待）

...

💡 判断题陷阱集中在"尚未"vs"已经"、"一致"vs"不同"这种副词替换上。考试时特别注意这些修饰词。

填空题。请完成旧派与新派的五对五对比。

	旧派	新派
出发点	个人 自由优先	社会 防卫优先
怎么看人	人有自由意志	人是被决定的
处罚依据	客观主义（看行为）	主观主义（看行为人）
刑罚目的	报应刑论	目的刑论
本质	重规范	重事实

...

💡 五对五口诀：旧个人/自由意志/客观/报应/规范；新社会/决定论/主观/目的/事实。连续念三遍就能记住。

辨析题。张明楷说"所谓的刑法缺陷，大体上都是解释者解释出来的"。请判断以下案例是否说明了这个观点：

有人主张"QQ靓号和游戏装备不是传统意义上的'财物'，所以盗窃虚拟财产无法按盗窃罪定罪——这法条有缺陷，得改。"

张明楷会如何回应？

- A. 同意，确实有缺陷，应该立法修改 ❌
- B. 不同意，可以把"财物"解释得更宽，适应社会变化 ✅
- C. 同意有缺陷，但暂时通过类推解释解决 ❌
- D. 不同意，虚拟财产根本不该受刑法保护 ❌

答案：B

...

💡 核心理念：除了数字等极少数实在难以解释的用语以外，刑法的任何用语都有很大的解释空间。"财物"在今天的含义和一百年前能一样吗？社会的"财产"形态变了，解释也可以跟着变。刑法完善的路径是：立法→解释→司法反馈→立法修正→再解释→循环往复。

匹配题。请将左列描述与右列学派或理论正确匹配。

左列描述	右列
1. 犯罪人是被遗传和环境决定的	B. 新派
2. 以社会契约论和自然法为思想基础	A. 前期旧派
3. 刑罚的正当化根据在于目的正当性	B. 新派
4. 有明显的国家主义、权威主义倾向	C. 后期旧派
5. 违法性的根据在于法益侵害及其危险	D. 结果无价值论

...

💡 记忆要点：1和3都是新派（决定论+目的刑）；2是前期旧派（反封建自由派）；4是后期旧派（经过黑格尔学派洗礼的"国家自由主义"）；5是结果无价值论（张明楷的立场）。

综合选择题。关于绪论的核心命题，下列组合正确的是：

- ① 刑法学的本体是解释论，重心是立法论 ❌（重心是解释论）
- ② 刑法教义学需要在解释学之外另建体系 ❌（不需要另建）
- ③ 旧派=报应刑+客观主义+自由意志 ✅
- ④ 新派=目的刑+主观主义+决定论 ✅
- ⑤ 张明楷采取客观解释论和结果无价值论 ✅
- ⑥ 我国刑法理论已经形成自主的知识体系 ❌（尚未形成）

A. ①③⑤ ❌ B. ②④⑥ ❌ C. ③④⑤ ✅ D. ①②⑥ ❌

答案：C（③④⑤）

...

💡 这种组合题是考试经典题型——一句话正误判断+组合选项。关键：①②⑥都是张明楷明确反对的命题，一一排除即可。

速记自测——请在一分钟以内完成以下填空。

1. 张明楷总论体系三块：刑法基础论 → 犯罪论 → 法律后果论
2. 犯罪论的两个核心概念：不法 + 责任
3. 旧派 vs 新派的本质区别一句话：旧派重规范，新派重事实
4. 张明楷采取的两大方法论立场：客观解释论 + 结果无价值论
5. 本书主张的刑法学定位：刑法解释学与刑法哲学的统一体

...

💡 一分钟全对=绪论过关。有错→翻回对应卡片重看。这五问覆盖绪论全部七节的核心知识。

第一章 刑法概说

第一节 刑法的概念、渊源与分类

刑法是规定犯罪及其法律后果（主要是刑罚）的法律规范。

为什么德国、日本虽然有"刑法"和"犯罪法"两个词，但最终都只用"刑法"？我国为什么也不需要改叫"罪刑法"？

德国、日本虽有"刑法"和"犯罪法"两个词，但指的完全是一部法律——德国日本虽有保安处分仍叫"刑法"。我国也不需要改名，因为有约定俗成的说法："刑随罪至，罪因刑显"，单叫刑法或犯罪法都能概括罪刑兼有之义。

...

有学者认为"刑法"重视规范一面，"犯罪法"重视事实一面。也有学者认为"刑法"侧重于国家（施加刑罚方），"犯罪法"侧重于国民（加害方/被害方）。

💡 就像"番茄"和"西红柿"——两个名字指同一个东西。

补充：刑法在各类法律分类中的定位：

- 刑事法/民事法：属于刑事法
- 实体法/程序法：属于实体法
- 母法/子法：属于子法（根据宪法制定）
- 强行法/任意法：属于强行法
- 公法/私法：属于公法
- 固有法/继受法：基本属于固有法（自定为主+借鉴为辅）
- 立法法/司法法/行政法：属于司法法（指导原理是法的安定性）

填空：刑法是一门独立的法律。为什么说"刑法是第二次规范"的观点只有部分合理性？

刑法不是第一次规范的简单补充，犯罪行为已经超出了其他法律的规制范围。

...

为什么"第二次规范"说只有部分合理性？

- 这种观点认为：民法、行政法等是"第一次规范"→立法者认为第一次规范不够力→刑法作为"第二次规范"补充上来
- 合理性：强调了刑法的补充性（最后手段性）
- 不合理之处：不能据此认为刑法从属于民法、行政法。原因是：犯罪行为已经超出了其他法律的规制范围——犯罪行为不是"先违反民法、然后再加个刑"那么简单，而是有其独立的判断标准

举例：杀人行为不仅仅是一个"民事侵权"的升级版，而是有其独立的犯罪构成。你不能说"杀人=民事侵权+加刑"，因为杀人的规范判断从一开始就是刑法层面的独立评价。

💡 刑法和其他法律的关系像"特种部队"和"常规部队"——不是特种部队隶属于派出所，而是各自有各自的战场和判断标准，只不过特种部队只在常规手段不够用的时候才出动。

刑法的三种渊源分别是什么？填空：

1. 刑法典：以刑法名称颁布的、系统规定犯罪及其法律后果的法律。说"刑法第X条"时指的就是它。

2. 单行刑法：以决定、规定、补充规定、条例等名称颁布的，规定某一事项或某一类犯罪的法律。现行有效的仅存一部——1998年的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》。
3. 附属刑法：附带规定于民法、经济法、行政法等非刑事法律中的罪刑规范。我国的现状是：没有真正意义上的附属刑法。

...

1. 刑法典：如1979年刑法、1997年修订的现行刑法
2. 单行刑法：现行有效的仅存一部——1998年《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》
3. 附属刑法：附带于非刑事法律中的罪刑规范。我国现状：没有真正意义上的附属刑法——现行行政法、经济法中的相关条款大多只是形式上重申"构成犯罪的，依法追究刑事责任"，没有设置真正的罪刑规范

此外：民族自治地方的省级人民代表大会根据当地特点制定的变通或补充规定，也可谓刑法的渊源（但只在特定地域适用，没有普遍效力）。

💡 口诀：典→单→附，层次递减。我国以"典"为绝对主力，"单"仅存一部，"附"则有名无实。

刑法的形式分类对号入座——

1. 根据范围：广义刑法（刑法典+单行刑法+附属刑法） vs 狭义刑法（仅刑法典）
2. 根据适用范围：普通刑法（刑法典） vs 特别刑法（仅适用于特定人/时/地/事项）
3. 根据名称：形式刑法（名称上看得出是刑法） vs 实质刑法（名称上看不出但内容规定了犯罪和刑罚）
4. 根据犯罪类型：固有刑法（规定自然犯/刑事犯） vs 行政刑法（规定行政犯）

...

1. 广义刑法 vs 狭义刑法
2. 普通刑法 vs 特别刑法（特别法优于普通法）
3. 形式刑法 vs 实质刑法（形式刑法=刑法典+单行刑法，影响性强、威慑力大→适合规定重罪；实质刑法=附属刑法，容易被忽视→适合规定轻罪）
4. 固有刑法（刑事刑法） vs 行政刑法（规定行政犯的刑法规范，特点是较弱的伦理性、较大的变易性、较广的散在性）

特别说明：行政刑法 ≠ 行政法。行政刑法是刑法的组成部分。在我国没有附属刑法的情况下，行政刑法的内容全部纳入刑法典中。

💡 快记：广狭对范围，普特对适用，形实对名称，固有行政对犯罪类型。

第二节 刑法的性质、机能与目的

刑法区别于其他法律的六项特有属性是什么？用最少的字概括每一项。

1. 规制内容的特定性
2. 制裁手段的严厉性
3. 法益保护的广泛性
4. 处罚范围的不完整性
5. 部门法律的补充性
6. 对其他法律的保障性

...

1. 特定性——只规定犯罪及其法律后果，其他法律规定一般违法行为
2. 严厉性——刑罚是国家最严厉的制裁方法（赔偿vs死刑，天壤之别）
3. 广泛性——一般部门法只保护某一方面的法益，刑法保护人身的、经济的、财产的、社会秩序的……几乎所有方面
4. 不完整性——并非所有侵害法益的行为都是犯罪、立法者选择性地只规定其中一部分、且受罪刑法定原则限制只能类型化地规定
5. 补充性——只有当一般部门法不能充分保护法益时，刑法才出场。"刑罚如两刃之剑，用之不得其当，则国家与个人两受其害"
6. 保障性——其他法律调整的社会关系最终依靠刑法保障（没有刑法，海关法、税法等于没牙的老虎）

💡 六字诀：特、厉、广、缺、补、保。连续念三遍就能记住。

关键理解："广泛性"和"不完整性"不矛盾。广泛性是指保护的法益种类多；不完整性是指处罚的行为只是其中一部分。就像图书馆藏书千万册（广泛），但每本书只借给特定的人（不完整）。

刑法的两大机能是什么？填空：

法益保护机能 + 人权保障机能

为什么张明楷不把"行为规制机能"当作独立的第三机能？

刑法的两大机能是法益保护机能与人权保障机能。

...

为什么行为规制机能不算独立机能？

- 传统学说认为刑法有三机能：行为规制、法益保护、人权保障
- 张明楷认为：行为规制只是法益保护的实现手段。刑法把侵犯法益的行为类型化并规定法定刑→自然产生了行为规制效果，不需要单独列为一个机能
- 此外，行为规制机能不是与法益保护、人权保障并列的——规制国民行为是为了保护法益，规制司法人员行为是为了保障国民自由，各自分属两大机能

两大机能的紧张关系：

- 法益保护依赖刑罚的适用（越多越保护）
- 人权保障依赖限制刑罚的适用（越少越保障）
- 结局：只能在罪刑法定限度内调和。张明楷认为人权保障机能优先于法益保护机能

💡 一句话：刑法既是"善良人的大宪章"（保护你免受犯罪侵害），也是"犯罪人的大宪章"（保护你不被国家乱罚）。两面都要护，但后面一面是底线。

刑法的目的是什么？填空：保护法益。

为什么说"研究刑法目的有利于对刑法进行目的论解释"？当出现不同的解释结论时，最终起决定性作用的是什么？

目的论解释的决定性作用：

- 不管法条的文字表述如何，都不能脱离法条的目的做出解释
- 当出现不同的解释结论时，最终起决定性作用的是（没有超过法条文字可能具有的含义的）目的论解释

...

三层目的体系（由高到低）：

- 高层次：刑法的整体目的（保护法益）
- 中层次：分则各章的目的（如保护人身权利、保护财产.....）
- 低层次：具体条文的目的（如保护人的生命、保护公私财物.....）

低层次目的受高层次目的制约，高层次目的依赖低层次目的体现。正确理解了条文目的，就找到了理解刑法文字的指南。

💡 打个比方：法条是"路线图"，法条目的是"目的地"。不看目的地只看路线图，你可能会被任何一条路绕晕；知道了目的地，你才能判断哪条路是对的。

第三节 刑法的制定、修改与根据

新中国第一部刑法典是哪一年通过的？填空：1979年7月1日通过，1980年1月1日起施行。

现行刑法典是哪一年修订的？此后立法机关主要以什么方式修改刑法？

- 新中国第一部刑法典：1979年7月1日通过，1980年1月1日起施行
- 现行刑法典：1997年修订
- 此后主要以刑法修正案方式修改

...

历史脉络速记：

- 1950-1954：草拟两稿，条件不成熟，未公布

- 1954-1957: 从13稿到22稿, 因"反右"和法律虚无主义中断
- 1962-1963: 第33稿, 因"四清"和"文革"中断
- 1978: 重新组建修订班子
- 1979: 改革开放元年, 刑法典诞生
- 1997: 全面修订, 将20多部单行刑法全部纳入

💡 40年立法路, 三次中断(反右→文革→四清), 最终在改革开放大门打开的同时完成。刑法典的诞生过程折射出: 法治的命运和国家的命运绑在一起。

三种刑法立法观念填空:

1. 消极刑法观: 不应当积极增设新罪, 不能扩大犯罪圈
2. 积极刑法观: 通过积极立法扩大处罚范围, 使刑法满足社会变化的需要
3. 折中刑法观: 既要考虑打击犯罪, 又要特别谨慎、稳健

张明楷主张哪一种? 他给出的四条理由是什么?

张明楷主张积极刑法观。折中刑法观的实质是消极刑法观。

. . .

四条理由:

1. 法益在增长: 社会越发展, 需要保护的利益越多(如虚拟财产)。法益没有自然法的永恒效力, 跟随社会关系变迁而变化
2. 侵害在升级: 同样的行为在过去轻微, 在当下可能严重。高度技术化的社会使个人行为的潜在危险性飞跃增大
3. 处罚漏洞多: 现行刑法缺乏类型性(如用十几个法条描述一种犯罪类型, 仍有漏洞); 许多法条缺乏有效性
4. 成立 ≠ 处罚: 扩大轻罪的成立范围, 不意味着必须科处刑罚。可以酌定不起诉或非刑罚处罚——这是同时实现法益保护与自由保障的最佳路径

💡 一句话: 不能因为不想多处罚, 就不去承认新出现的"坏行为"是犯罪。认它是犯罪和实际处罚它, 是两回事。

刑法第1条规定了制定刑法的两个根据, 填空:

"为了惩罚犯罪, 保护人民, 根据宪法, 结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况, 制定本法。"

1. 宪法根据: 宪法。刑法不能与宪法相抵触, 解释刑法也必须与宪法协调。
2. 实践根据: 国情与经验。立足于本国实情, 在吸收借鉴外国经验时不能脱离中国基本国情。

. . .

1. 宪法根据（法律依据）
2. 实践根据（国情与经验）

深层含义：

- 宪法不仅是制定刑法的依据，也是解释刑法的依据。任何刑法解释都不能违反宪法
- 实践根据意味着刑法不能脱离实际、超越阶段；吸收国外经验 ≠ 照搬国外立法

💡 像造房子：宪法是“地基”——决定了房子能盖多高、什么结构；实践根据是“建材”——要根据本地有什么材料来建造，不能光看别人家用什么砖就买什么砖。

第四节 刑法的规范、体系与解释

填空：刑法规范首先是裁判规范，同时也隐含了行为规范。

裁判规范指向的对象是司法工作人员，行为规范指向的对象是一般国民。

为什么张明楷认为“不应追求裁判规范与行为规范的分离”？

刑法规范首先是裁判规范，同时也隐含了行为规范。

- 裁判规范 → 指向司法工作人员（指示如何定罪量刑）
- 行为规范 → 指向一般国民（禁止/命令/允许/豁免）

...

“不应追求分离”的原因：

- 法条表述是“……的，处……”——这是裁判规范的描述方式，行为规范暗含其中
- 一般国民通过阅读法条或了解判决，能领会行为规范：什么是不法行为、犯罪会受什么制裁、什么情况下可以正当防卫
- 如果追求分离（如：对国民说A行为构成犯罪，但对法官说实际上不构成），这既具有欺骗性，也具有恐吓性，侵犯国民尊严

💡 就像交通法规：它的写法是“违反XX规定的，处XX罚款”（裁判规范），但老百姓读到它就知道“不能闯红灯”（行为规范）。法官和司机看的是同一本法条。

填空：分则规范分为两种——

1. 完备刑法：构成要件有明确、完备的规定，适用时无须参照其他法律。
2. 空白刑法：构成要件没有做出完备规定，适用时需要参照其他法律、法规。

适用空白刑法时，司法机关不能只是抽象地说“行为违反了什么法律”，而必须具体说明行为违反了什么法律、法规的第X条、第X款、第X项。

...

1. 完备刑法

2. 空白刑法

适用空白刑法的关键要求：

- 必须参照该空白刑法所指明的相关法律、法规，准确界定构成要件内容
- 司法机关必须具体说明行为违反了什么法律、法规的第X条、第X款、第X项
- 不能只抽象地说明"违反了什么法律"，也不能直接根据司法解释认定犯罪
- 当刑法分则要求的是"违反国家规定"时，仅违反部门规章的行为不成立犯罪

举例：刑法第155条说"直接向走私人非法收购……"，其中"非法"=违反海关法规。要认定犯罪，必须具体指出违反了《海关法》哪一条。只说"违反海关法规"是不够的。

💡 空白刑法就像"填空题"——刑法给你一个框架，具体内容要从其他法律里填。但填的时候必须精确到条款号。

刑法为什么一定需要解释？（至少填 3 个原因）

填空：张明楷采取客观解释论（客观/主观）。

主观解释论追求立法者的原意，客观解释论追求刑法规范中的客观意思。

张明楷采取客观解释论。主观解释论追求立法者的原意，客观解释论追求刑法规范中的客观意思。刑法必须解释。

...

为什么刑法一定需要解释？

1. 文字的多义性：任何用语核心意义明确，但边缘模糊，需要解释界定边界
2. 法条目的不明确：即使文字含义看似明确，法条目的也需要通过解释才能发现
3. 刑法有缺陷：文字表述缺陷或立法原意缺陷，需要通过解释克服
4. 抽象vs具体：刑法规定是对犯罪的抽象类型化，现实案件是具体的，二者之间有距离
5. 稳定性vs变化：稳定刑法要适应不断变化的社会生活，只能靠解释

客观解释论 vs 主观解释论：

- 客观解释论（张明楷采取）：追求刑法规范中的客观意思
- 主观解释论：追求立法者制定时的主观意思（立法原意）

为何选客观解释论？十个理由浓缩为两条：

- 立法者是一个集体，不存在统一的"原意"；且立法时无法预见未来所有案件形态
- "解释者对法律的理解可能比立法者更为出色；法律必须比它的制定者更为聪明"

💡 法官不是在考古——不是在挖掘"当年立法者怎么想的"；而是在翻译——把法条的文本翻译成当下社会能理解的正义。

刑法解释方法分为两组：

1. 解释技巧：条文的适用方法（只能选一种）——平义解释、扩大解释、缩小解释、当然解释、反对解释、类推解释、比附、补正解释
2. 解释理由：为选择何种技巧提供依据（可以并用）——文理解释、体系解释、历史解释、比较解释、目的解释、合宪性解释

哪两种解释理由具有决定性？

...

1. 解释技巧
2. 解释理由

具有决定性的两种理由：

- 文理解的决定性：所有解释从法条文理开始，且不能超出刑法用语可能具有的含义（罪刑法定原则的边界）
- 目的解释的决定性：当法条可以做出两种以上解释时，只能采纳符合法条目的的解释结论

关键论断："正确的解释，必须永远同时符合法律的文言与法律的目的，仅仅满足其中一个标准是不够的。"

禁止的技巧：对被告人不利的类推解释和比附是罪刑法定原则绝对禁止的。

💡 像开车——文理解释是"车道线"（不能越界），目的解释是"目的地"（往哪开）。两条缺一不可：只看车道不管目的地，会迷路；只盯着目的地不管车道，会撞车。

自测卡专区

选择题。刑法区别于其他法律的六项特有属性中，下列哪一项表述错误？

- A. 制裁手段的严厉性——刑罚是"两刃之剑" ☒
- B. 法益保护的广泛性——所以处罚范围也广泛 ☒（"广泛性"指保护的法益种类多，和"处罚范围广泛"是两回事）
- C. 处罚范围的不完整性——并非所有侵害法益的行为都是犯罪 ☒
- D. 部门法律的补充性——刑法是保护法益的最后手段 ☒

答案：B

...

💡 陷阱：用"广泛性"偷换"处罚范围的广泛性"。张明楷明确指出"广泛性"和"不完整性"不矛盾。

选择题。关于裁判规范与行为规范，下列哪一说法正确？

- A. 裁判规范指向一般国民，行为规范指向司法工作人员 （方向反了——裁判规范→法官，行为规范→国民）
- B. 张明楷认为应追求裁判规范与行为规范的分离 （反对分离——“既具有欺骗性，也具有恐吓性，侵犯国民尊严”）
- C. 刑法规范的表述方式是裁判规范，行为规范暗含其中 
- D. 对国民说A构成犯罪、对法官说A不构成犯罪是可行的 （“不可取”）

答案：C

...

💡 “就像交通法规：它的写法是‘违反XX规定的，处XX罚款’（裁判规范），但老百姓读到它就知道‘不能闯红灯’（行为规范）。法官和司机看的是同一本法条。”

判断对错（T/F）。

1. （ F ）刑法是独立的部门法，“刑法是第二次规范”的观点完全不正确。——“第二次规范”说强调了刑法的补充性，具有一定合理性，不能据此认为刑法从属于民法行政法
2. （ F ）行政法规可以规定犯罪与刑罚。——《立法法》第12条明文禁止
3. （ T ）习惯法在解释构成要件时可以成为考虑因素。——“习惯法虽然不能成为刑法的渊源，但仍然是解释构成要件和判断违法性、有责性时必须考虑的因素”
4. （ T ）我国目前没有真正意义上的附属刑法。——“现行行政法、经济法中的相关条款大多只是形式上重申，没有设置真正的罪刑规范”
5. （ F ）空白刑法适用时只需抽象说明“行为违反了什么法律”。——必须具体说明违反了什么法律、法规的第X条、第X款、第X项

...

💡 五个判断题分别测试刑法独立性、法律主义、习惯法、附属刑法和空白刑法，覆盖第一章核心考点。

辨析题。“对国民说A行为构成犯罪，但对法官说实际上不构成犯罪”——这种做法违反了张明楷的哪一观点？

- A. 刑法解释学与刑法哲学的统一 
- B. 裁判规范与行为规范不应分离 
- C. 客观解释论优于主观解释论 
- D. 积极刑法观优于消极刑法观 

答案：B

...

💡 张明楷认为追求裁判规范与行为规范分离是错误做法：“这既具有欺骗性，也具有恐吓性，侵犯了国民的尊严。既然法条的真实含义并非如此，就不能向国民撒谎。”解释者不应対法条做出两种不同的解释，一种给国民看，一种给法官看。

填空题。刑法解释的两种决定性理由及各自的含义。

解释理由	决定性含义
文理解释	所有解释从法条文理开始，且不能超出用语可能具有的含义
目的解释	当有两种以上解释时，只能采纳符合法条目的的解释

关键论断："正确的解释，必须永远同时符合法律的文言与法律的目的，仅仅满足其中一个标准是不够的。"

. . .

💡 两句口诀：文理解释=车道线（不能越界）；目的解释=目的地（往哪开）。两条缺一不可。

快速自测——请排列从高到低的三层目的体系。

高层次：刑法的整体目的→保护法益

中层次：分则各章的目的→如保护人身权利

低层次：具体条文的目的→如保护人的生命

填空：刑法的目的是保护法益。当出现不同解释结论时，最终起决定性作用的是目的论解释（没有超过法条文字可能具有的含义的）。

. . .

💡 "正确理解了条文目的，就找到了理解刑法文字的指南。"法条是"路线图"，法条目的是"目的地"。不看目的地只看路线图，任何一条路都能绕晕你；知道了目的地，才能判断哪条路是对的。

综合选择题。下列关于刑法性质的组合判断，正确的是：

- ① 刑事法/民事法：刑法属于刑事法 ☒
- ② 实体法/程序法：刑法属于程序法 ☐（刑法属于实体法，刑事诉讼法属于程序法）
- ③ 公法/私法：刑法属于公法 ☒
- ④ 固有法/继受法：我国刑法基本属于继受法 ☐（基本属于固有法——自定为主+借鉴为辅）
- ⑤ 强行法/任意法：刑法属于强行法 ☒
- ⑥ 立法法/司法法/行政法：刑法属于立法法 ☐（属于司法法——指导原理是法的安定性）

A. ①③⑤ ☒ B. ②④⑥ ☐ C. ①②③ ☐ D. ④⑤⑥ ☐

答案：A（①③⑤）

...

💡 刑法七大分类：刑事法/实体法/子法/强行法/公法/固本法/司法法。口诀："刑实子强公固司"。

辨析题。关于积极刑法观，以下哪一项不是张明楷主张的理由？

- A. 法益没有永恒效力，跟随社会变迁而变化——虚拟财产等新法益需要刑法保护 ☒
- B. 同样的行为在过去轻微、现在严重——高度技术化社会使个人行为危险性飞跃增大 ☒
- C. 扩大犯罪圈就等于扩大处罚范围——因此要慎重 ☒
- D. 犯罪的成立范围 ≠ 处罚范围——认它是犯罪和实际处罚它，是两回事 ☒

答案：C

...

💡 积极刑法观的核心逻辑：法益在增长（社会越发展需要保护的利益越多）→侵害在升级→有处罚漏洞要补→扩大成立范围 ≠ 必须处罚（可酌定不起诉或非刑罚处罚）。这四条理由缺一不可。

匹配题。请将左列描述与右列刑法观正确匹配。

左列	右列
1. 不应当积极增设新罪，不能扩大犯罪圈	B. 消极刑法观
2. 通过积极立法扩大处罚范围满足社会变化	A. 积极刑法观
3. 既要打击犯罪又要特别谨慎稳健	C. 折中刑法观
4. 折中刑法观的实质是	D. 消极刑法观
5. 张明楷主张	E. 积极刑法观

答案：1→B，2→A，3→C，4→D，5→E

...

💡 三观简记：消极=保守（不扩圈）；积极=进取（妥当处罚，顺应时代）；折中=伪积极（说积极但加"谨慎"=实质保守）。

辨析题。张明楷为什么采取客观解释论而不是主观解释论？

以下哪一项不是张明楷的理由？

- A. 立法者是一个集体，不存在统一的"原意" ☒
- B. 立法时无法预见未来所有案件形态 ☒
- C. 主观解释论有利于保持刑法的稳定性 ☒
- D. "解释者对法律的理解可能比立法者更为出色" ☒

答案：C

...

💡 客观解释论十条理由浓缩为两条核心：①不存在统一的"立法原意"（立法者是集体+无法预见未来）；②法律比立法者更聪明。客观解释论不是在考古——不是在挖掘"当年立法者怎么想的"，而是在翻译——把法条文本翻译成当下社会能理解的正义。

第二章 刑法的基本原则

第一节 刑法的基本原则概述

刑法基本原则的三个条件是什么？填空：

1. 应是刑法所特有的原则，而不是各个部门法所共有的原则
2. 必须是贯穿于刑法始终，具有全局性、根本性的准则
3. 必须是刑法的制定、解释与适用都必须遵循的准则

...

刑法明文规定的三原则：罪刑法定、平等适用刑法、罪刑相适应。

张明楷主张的五原则：除了上述三个明文规定的外，法益保护与责任主义也是刑法的基本原则。理由：犯罪的实体是不法与责任——不法的本质是侵犯法益，责任是就不法行为对行为人的非难。与之对应，法益保护与责任主义应当成为基本原则。刑法总则第1条、第2条、第13条以及分则条文共同体现了法益保护原则；刑法关于故意、过失、责任能力等规定表明了责任主义原则。

💡 刑法的适用存在三大危险：①一旦发生冲动案件就产生强烈处罚感情，不顾刑法有无规定便予以处罚；②因行为人主观恶劣而不管客观上是否侵犯法益便予以处罚；③因侵犯了法益而不问行为人是否具有非难可能性便予以处罚。三大原则恰好——对抗这三重危险。

第二节 罪刑法定原则

罪刑法定原则的法律渊源演进——填空：

现代意义上罪刑法定原则的法律渊源是法国1789年的《人权宣言》、1791年的《法国宪法》与1810年的《法国刑法典》。

罪刑法定不仅是刑法原则，也是宪法原则。我国的宪法根据是《宪法》第37条。

...

时间线速记：1215年英国《大宪章》第39条（思想基础）→ 1789年法国《人权宣言》第8条（宪法化）→ 1810年《法国刑法典》第4条（法典化）→ 被写入《世界人权宣言》《公民权利和政治权利国际公约》等国际条约 → 成为各国宪法原则。

我国宪法根据：《宪法》第37条"中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯"，结合第5条依法治国、第33条尊重和保障人权，共同构成罪刑法定的宪法基础。

💡 没有罪刑法定原则，就不可能有现代意义的法治。戴雪所提出的第一个法治原则便是罪刑法定。

罪刑法定原则的两大思想基础是什么？填空：

1. 民主主义：国家的重大事务应由国民自己决定。刑法处罚范围与程度直接关系每一个人的生命、身体、自由、财产与名誉，应当由国民选举的立法机关制定刑法。
2. 尊重人权主义：为了使国民能够事先预测自己行为的性质与后果，必须事先明确规定犯罪与刑罚。这也称为预测可能性原理。

...

民主主义 → 法律主义（成文法主义）、禁止处罚不当罚行为、罪刑均衡。

尊重人权主义 → 法律主义、禁止事后法（溯及既往）、禁止类推解释、明确性原则。

此外，一般预防与责任主义也能为罪刑法定提供思想基础：事前明确规定被禁止行为 → 人们才能不实施犯罪；行为人只有在事前知道或有机会知道行为被禁止时 → 才能讨论非难可能性。

💡 两个词记：民主=法要由人民制定；自由=人民能预知什么该做什么不该做。

罪刑法定原则的形式侧面与实质侧面分别指什么？

形式侧面（传统内容）：法律主义、禁止事后法、禁止类推解释、禁止不定（期）刑

实质侧面（限制立法权）：明确性原则、刑罚法规内容的适正原则

...

形式侧面源于三权分立和心理强制说，旨在限制司法权（法院严格执行议会制定的法律即可保障自由）。实质侧面是实质法治的表现——不仅所有人都在法律之下，而且以实在法之外的标准衡量和检测法律，限制立法权（反对恶法亦法）。

实质侧面中"刑罚法规内容适正"又包含三层要求：①禁止违反宪法的人权保障规定；②禁止处罚不当罚的行为；③禁止不均衡的、残虐的刑罚。

💡 形式侧面=限制法官（法官不能自己造法），实质侧面=限制立法者（立法者不能立恶法）。两个侧面共同保障自由。

法律主义（成文的罪刑法定）的四项具体要求是什么？

1. 规定犯罪及其后果的法律只能是立法机关制定的法律，行政机关不能制定刑法
2. 必须用本国通用文字表述

3. 习惯法不得作为刑法的渊源

4. 判例不得作为刑法的渊源

...

行政法规能否制定罚则？ 《立法法》第12条明文规定：有关犯罪和刑罚的事项，不得授权国务院制定行政法规。我国严格遵循了罪刑法定。

习惯法为何不能做刑源？ 缺乏明确表达（无法预测行为后果）、不具一般性、难以限制司法权力。但习惯法在解释构成要件和判断违法性、有责性时可作为考虑因素。

判例法能否做刑源？ 不能。判例法实际上是法院公然立法，彻底违反民主主义原理。我国"两高"的案例指导制度只是司法解释的另一种表述，不是将判例作为法源。

💡 类案检索制度的警示：无罪判决罕见→只要检索到有罪判决就可能以此为据→导致错案。"理应追求案件处理在当下是正确的，而不是与过去相同。"

禁止溯及既往（事前的罪刑法定）——填空：

禁止事后法是保障国民自由的要求。因为国民总是根据现行有效的法律来计划、决定和实施自己的行为。

禁止溯及既往既是司法原则，也是立法原则。禁止事后法只是禁止不利于被告人的溯及既往；如果新法有利于被告人，则可以溯及既往。

...

禁止事后法包含的八项内容：（1）行为时未禁止的不得科刑；（2）行为时有法律禁止但未以刑罚禁止的不得科刑；（3）不得事后减少或降低犯罪成立条件；（4）不得事后提高法定刑或加重刑罚；（5）不得事后增加或加重保安处分；（6）不得事后将自诉罪变更为公诉罪；（7）不得事后延长或取消追诉时效；（8）不得事后改变刑事证据规则降低证明标准。

💡 如果今天的合法行为会被明天的法律宣告为非法，国民就没有丝毫自由可言。

禁止类推解释（严格的罪刑法定）——填空：

类推解释，是指需要判断的具体事实与法律规定的构成要件基本相似时，将后者的法律效果适用于前者。

类推解释可由民主主义解释（刑法由国民制定）、预测可能性原理解释（超出国民预测）、责任主义解释（无预测则无非难可能）。

现在的通说：禁止不利于被告人的类推解释，但允许有利于被告人的类推解释。

...

类推解释 vs 扩大解释（八个判断标准）：

1. 用语可能具有的含义（核心标准）+ 处罚必要性

2. 根据本国刑法用语判断，不能照搬外国标准
3. 考虑用语发展趋势（如电子邮件→"信件"）
4. 考虑相关法条的保护法益
5. 考虑该用语在刑法中应有的含义（行政犯≠行政法定义）
6. 考虑与相关条文的关系及整体协调性
7. 考虑解释结论的合理性
8. 考虑一般国民的接受程度

💡 扩大解释在"射程"之内，类推解释在"射程"之外。但两者的界限并非固定不变——以前属于类推的，以后可能属于扩大，反之亦然。

明确性原则（明确的罪刑法定）——填空：

明确性包括刑事立法的明确性与刑事司法的明确性。

犯罪构成的明确性：规定犯罪的法律条文必须清楚明确，使人能确切了解违法行为的内容，准确确定犯罪行为与非犯罪行为的范围。

法定刑的明确性：不得规定绝对不定（期）刑，而应规定相对确定的法定刑。

...

明确性源于美国"因不明确而无效"的宪法原则（1914年确立）。明确性要求的三项机能：①事前适正地告知国民什么是犯罪；②给法官适用法律提供指针；③为诉讼当事人的诉讼活动提供指针。

刑事司法的明确性包括：①司法解释与指导性案例必须明确——不得导致司法人员对其内容朝相反方向理解；②判决书与起诉书必须明确——事实描述、适用法条、裁判说理均需明确。

💡 "没有法律就没有刑罚的原则的真正危险并非来自于类推，而是来自于不确定的刑法规定。"

处罚的适正性（适正的罪刑法定）——三项要求填空：

1. 禁止违反宪法有关人权保障的规定
2. 禁止处罚不当罚的行为
3. 禁止不均衡的、残虐的刑罚

...

禁止处罚不当罚行为的四步审查（刑事立法比例原则）：

①目的是否具有合理性？（保护法益的需要？目的合宪？法益有重要价值？目的明确具体？）

②刑罚是不是达到合理目的的有效手段？

③是否存在替代刑罚的手段？（非刑罚手段能否有效保护法益？利弊权衡？）

④利用刑罚保护法益的同时可能造成何种损害？（刑罚的附随萎缩效果必须明显小于所追求的利益）

禁止不均衡、残虐刑罚：罪刑均衡不是"以眼还眼"的简单报复，而是罚与罪的严重程度相当。残虐刑罚=以不必要的精神肉体痛苦为内容、人道上残酷的刑罚，相对于任何犯罪都是不均衡的。

💡 比例原则四个字：不能为了打一只蚊子用大炮。

刑法第3条"法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。"

对前段有两种解释——填空：

解释一：前段不是对罪刑法定原则的规定，而是针对我国刑法分则的特点，突出刑法的法益保护机能，防止司法人员随意出罪。

解释二：前段仍然是对罪刑法定原则的规定，含义是只能依照刑法的规定定罪量刑，而不能违反刑法的规定定罪量刑。

...

张明楷的立场：不赞成将前段解释为"积极的罪刑法定原则"。罪刑法定原则旨在限制入罪权、施刑权、制刑权，而"有罪必罚"不是这个意思。前段和后段都旨在限制司法权，只是限制内容不同。

实质解释论 vs 罪刑法定：实质解释论并非违反罪刑法定——它是在法条文字可能具有的含义内，以保护法益为指导进行解释。只有通过类推解释才能填补的漏洞才是真正的漏洞（只能由立法填补）。可以通过扩大解释等方法来填补的"漏洞"都不是真正的漏洞。

💡 核心：不要先想"这是什么行为"再找法条，而是要先把法条规定的犯罪构成作为大前提，再把具体事实作为小前提，最后得出结论。先定性后找法=想入罪便入罪，想出罪便出罪。

第三节 法益保护原则

法益的定义是什么？填空：

法益，是指根据宪法的基本原则，由法所保护的、客观上可能受到侵害或者威胁的人的生活利益。

由刑法所保护的人的生活利益，就是刑法上的法益。

...

界定法益的五项原则：

1. 必须与利益相关联——利益是能满足人们需要的东西
2. 必须与法相关联——不受法保护的利益不能叫法益
3. 必须具有可侵害性——价值观本身不是法益
4. 必须与人相关联——只有人的利益才值得刑法保护
5. 必须与宪法相关联——刑法保护什么利益必须符合宪法原则

实质法益概念 vs 形式法益概念：

- 实质法益概念（前实定/批判立法）：刑法应当保护什么利益？具有批判立法的功能——不得设置没有保护法益的犯罪
- 形式法益概念（实定/方法论）：刑法正在保护什么利益？指导对罪刑规范的解释
- 两者不可分离：确定分则条文的保护法益时，必须联系实质法益概念

💡 法益=我国传统刑法理论中的"犯罪客体"。用法益代替"社会关系"更准确——如破坏环境资源保护罪，用法益（生态环境）比"社会关系"好理解得多。

法益的种类——填空：

最常见的三分法：国家法益、社会法益与个人法益。

二元论：个人法益与超个人法益（后者可还原为前者）。

一元论：法益仅有个人法益，任何超个人法益只是多数个人法益的集合。

张明楷新增概念：集体法益——限定为超个人法益中被累积犯所侵犯的法益。

...

集体法益的三个特点：

1. 所有个人都能平等地、没有冲突地享受的利益（并非与个人法益分离）
2. 具有不可分配性——不可能分配给特定公民
3. 个别人或少数人的不法行为不会使其丧失，但多数人实施则会导致丧失

不属于集体法益的常见误区：环境犯罪（我国要求实害，是个别法益侵害）、公共危险犯（放火爆炸直接侵害具体个人）、寻衅滋事罪（有具体被害人）、金融诈骗罪（侵犯个人法益）。

💡 关键是区分"真正的集体法益"和"假象的集体法益"。很多法条实际上保护的是个人法益，只不过刑法保护的时间节点被提前了，形成保护集体法益的假象。

法益保护原则对刑事立法的两个要求——填空：

1. 消极标准：不得设置且必须废除没有保护法益的犯罪
2. 积极标准：要求为保护法益增设新罪

法益保护原则对刑事司法的要求——填空：对犯罪构成要件的解释结论，必须以法条的保护法益为指导，而不能仅停留在法条的字面含义上。

...

消极标准四不得：

- ①不得将单纯违反伦理的行为规定为犯罪（如兽奸）
- ②对于没有被害人的自损行为不得规定为犯罪（如吸食毒品）
- ③对于参与有处分权的自我损害行为不得规定为犯罪
- ④对于单纯有损国家机关权威性但没有侵犯法益的行为不得规定为犯罪

法益保护的限度：法益保护主义必须受到罪刑法定原则的约束——如果某行为严重侵害法益但刑法没有规定为犯罪，不能以"遵守宪法原则"为由直接入罪。法益保护原则只能是"补充性的法益保护原则""谦抑性的法益保护原则"。

💡 法益保护 ≠ 一切法益侵害都要入罪。刑法是最后手段，只有在其他法律不够用时才出场。

第四节 责任主义原则

责任主义的两层含义——填空：

广义责任主义包括主观责任与个人责任。

1. 主观责任：只有当行为人对所实施的违法行为与结果具有责任能力以及故意、过失、违法性认识的可能性与期待可能性时，才能进行非难。
2. 个人责任：只能就行为人实施的个人的行为进行非难。

...

消极责任主义（通说）："没有责任就没有刑罚"——责任是犯罪成立条件，也是刑罚的上限。即使一般预防与特殊预防必要性很大，也不得超过责任的上限量刑。

积极责任主义 vs 消极责任主义：

- 积极："有责任就有刑罚"（必须处罚）
- 消极："没有责任就没有刑罚"（不得滥罚）——通说采取消极责任主义

近代以前的责任形态：客观责任（结果责任，只要造成危害就追究）和团体责任（株连）。责任主义正是为了反对这两种形态而生的。

💡 责任主义把"人"当人看——只有对自己意志选择的行为才能被谴责，否则就是把人物化为预防犯罪的工具。

责任主义的宪法根据是什么？填空：

我国《宪法》第33条第3款："国家尊重和保障人权。"第38条前段："中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。"

德国在《基本法》第1条第1款（人的尊严不可侵犯）和第2条第1款寻找根据。日本在《宪法》第13条寻找根据。

...

为什么人的尊严能成为责任主义根据？

- 尊重人=将人作为自在目的，不能作为实现任何目的的手段
- 责任以可供取舍可能性（他行为可能性）为前提——行为人在没有实施其他合法行为的可能性时，追究责任就是把人物化为手段
- 故意与过失是行为人主观选择的结果——没有故意、过失的行为不是意志选择的结果，作为犯罪就是不尊重人

💡 一句话：责任是一种将人和其他动物区别开来的特性。不要求责任=不把人当人。

责任主义的贯彻——填空：

1. 在刑事立法上，不应当存在违反责任主义的规定。禁止事后法就是尊重人的基本要求。
2. 刑法解释与适用不得做出违反责任主义的解释结论。例如：不能得出"醉酒的人犯罪，即使在行为时没有责任能力，也应当负刑事责任"的结论。
3. 反对严格责任——即使参与风险行为的人没有故意与过失也要承担责任的做是不正当的。

...

贯彻责任主义的六个具体要求：

- ①违法性认识的可能性与期待可能性属于责任要素，不能因刑法没有明文规定就排除
- ②单位犯罪中只能处罚具有责任的直接负责主管人员和其他直接责任人员
- ③结果加重犯必须行为人对加重结果至少有过失
- ④探讨原因自由行为的处罚根据，确保不违反责任主义
- ⑤分则条文中没有处罚过失的文理根据时，只能确定为故意犯罪
- ⑥升格法定刑的适用必须贯彻责任主义——行为人没有认识到升格条件时不能适用升格法定刑

举例：行为人客观上盗窃了数额特别巨大的财物，但只认识到自己盗窃的是数额较大的财物→不能适用数额特别巨大的法定刑，只能适用数额较大的法定刑。

💡 责任是刑罚的天花板——无论这个人多危险、多需要"杀一儆百"，刑罚都不能超过他应受谴责的程度。

罪刑法定 + 法益保护 + 责任主义——三大原则互相对照各防范什么危险？

原则	防范的危险
罪刑法定	一旦发生冲动案件，不顾刑法有无明文规定便予以处罚
法益保护	因行为人主观恶劣，而不管客观上是否侵犯法益便予以处罚
责任主义	因为侵犯了法益，而不问行为人是否具有非难可能性便予以处罚

...

三大原则形成三道防线：

第一道：罪刑法定——法没写的不算犯罪

第二道：法益保护——没伤到人的不算犯罪

第三道：责任主义——不能怪到你头上的不算犯罪

三道防线对应犯罪成立三阶层：构成要件符合性（罪刑法定）→ 违法性（法益保护）→ 责任（责任主义）。

💡 把三大原则想象成三道安检：第一道查你有没有"票"（法条），第二道查你有没有"伤到人"（法益），第三道查你能不能"怪到你"（责任）。

张明楷对本章的核心立场——填空选择：

1. 刑法第3条前段：不赞成解释为"积极的罪刑法定"
2. 解释论立场：采取实质解释论
3. 类推 vs 扩大：在用语可能具有的含义内，同时考虑处罚的必要性
4. 立法观：法益保护原则同时具有消极标准（废除旧罪）和积极标准（增设新罪）
5. 责任主义：采取消极责任主义，责任是刑罚的上限

...

全书立场速记口诀：

- 刑法论：客观解释 + 实质解释 + 结果无价值
- 三大铁律：法不写不罚 → 没伤不管 → 不能怪不罚
- 法益论：既要删（废无益之罪）又要增（保新生之法益）
- 责任论：没有责任就没有刑罚，有责任也不能超过责任罚

💡 考试遇到问"张明楷怎么看"，以上五个填空就是标准答案框架。展开时逐一对照本章对应卡片内容。

自测卡专区

选择题。关于罪刑法定原则的法律渊源，下列排序正确的是：

- A. 法国《人权宣言》→ 英国《大宪章》→ 法国《刑法典》 ❌
- B. 英国《大宪章》→ 法国《人权宣言》→ 法国《刑法典》 ✅

- C. 法国《刑法典》→英国《大宪章》→法国《人权宣言》 ❌
D. 英国《大宪章》→法国《刑法典》→法国《人权宣言》 ❌

答案: B

...

💡 时间线: 1215 (大宪章) → 1789 (人权宣言) → 1810 (法国刑法典)。先有思想、再有宣言、最后入典。

判断对错 (T/F)。关于罪刑法定各项内容。

1. (F) 行政机关经立法委任可以制定罚则。——《立法法》第12条明文禁止授权国务院制定有关犯罪和刑罚的规定
2. (T) 禁止事后法只是禁止不利于被告人的溯及既往。——如果新法有利于被告人, 则可以溯及既往, 从旧兼从轻
3. (F) 对被告人有利的类推解释也一律禁止。——通说: 允许有利于被告人的类推解释
4. (F) "绝对不定期刑"符合罪刑法定原则。——明确性要求必须规定相对确定的法定刑
5. (F) 判例法可以作为我国刑法的渊源。——"判例法实际上是法院公然立法, 彻底违反民主主义原理"

辨析题。甲的行为根据旧法构成A罪 (法定刑3-7年), 根据新法构成B罪 (法定刑2-5年) ——但新法同时规定犯B罪"必须并处罚金", 旧法没有附加刑。如何处理?

- A. 适用旧法 (不并处罚金, 但刑期可能更长) ❌
B. 适用新法 (并处罚金, 但刑期更短) ✅
C. 适用新法的法定刑但排除附加刑 ❌
D. 由法官自由裁量 ❌

答案: B

...

💡 张明楷认为应当完整适用新法。"既然新条文规定的法定刑整体较轻时, 就要适用新条文 (不能因为新条文规定的附加刑重于旧条文, 就不适用新条文)。既然适用新法, 就应完整适用, 仅适用某一款或某一项的部分内容是不合适的。"选新法就整条吃, 不能挑食。

填空题。法益概念的五个界定原则。

1. 必须与利益相关联
2. 必须与法相关联
3. 必须具有可侵害性
4. 必须与人相关联
5. 必须与宪法相关联

法益的定义：根据宪法的基本原则，由法所保护的、客观上可能受到侵害或威胁的人的生活利益。

辨析题。法益保护原则的消极标准与积极标准各指什么？

以下哪项属于消极标准的作用？

- A. 要求为保护法益增设新罪 ✖
- B. 不得设置没有保护法益的犯罪 ✔
- C. 法益概念指导构成要件解释 ✖
- D. 以法益是否受侵害判断既遂未遂 ✖

答案：B

...

💡 消极标准（非犯罪化根据）：不得设置且必须废除没有保护法益的犯罪。积极标准（犯罪化根据）：要求为保护法益增设新罪。消极=删，积极=增。

填空题。责任主义的宪法根据和贯彻要求。

宪法根据：《宪法》第33条第3款"国家尊重和保障人权"+第38条"公民的人格尊严不受侵犯"。

核心三句：

- 责任是犯罪的成立条件，没有责任就没有犯罪
- 责任是刑罚的上限，禁止刑罚超过责任程度
- 严格责任违反宪法，反对在任何情况下适用

💡 "责任是一种将人和其他动物区别开来的特性。不要求责任=不把人当人。"

快速自测——三大原则对照表填空。

原则	防范的危险
罪刑法定	不顾刑法有无规定便处罚
法益保护	因主观恶劣而不管是否侵犯法益
责任主义	因侵犯法益而不问能否非难

张明楷不赞成"积极的罪刑法定"；采取实质解释论；采取消极责任主义。

💡 三原则=三道安检。第一道查"票"，第二道查"伤"，第三道查"心"。

判断对错（T/F）。关于罪刑法定原则的形式侧面与实质侧面。

1. （ F ）形式侧面包括法律主义、禁止事后法、禁止类推解释、明确性原则。——明确性原则是实质侧面，形式侧面的第四项是"禁止不定（期）刑"
2. （ F ）实质侧面主要限制司法权，形式侧面主要限制立法权。——刚好反了：形式侧面限制司法权，实质侧面限制立法权（反对恶法亦法）
3. （ T ）"因不明确而无效"是美国联邦最高法院于1914年确立的宪法原则。
4. （ F ）明确性原则只针对刑事立法，不针对刑事司法。——张明楷认为也包括刑事司法的明确性（司法解释、判决书、起诉书都必须明确）
5. （ T ）处罚的适正性=禁止违反宪法的人权保障+禁止处罚不当罚+禁止不均衡残虐的刑罚。

...

💡 口诀：形式四件套=法律主义+禁事后+禁类推+禁不定刑（限制法官）。实质两件套=明确性+适正性（限制立法者）。

辨析题。下列哪种解释属于类推解释而非扩大解释？

- A. 将"电子邮件"解释为刑法中的"信件" ❌（符合用语发展趋势，是扩大解释）
- B. 将"组织男性向男性提供有偿性服务"解释为"组织卖淫" ❌（同时代解释，是扩大解释）
- C. 将"语言暴力"解释为刑法分则中的"暴力" ✅（超出"暴力"一词可能具有的含义，是类推解释）
- D. 将"被害人陈述"解释为"证人证言" ❌（可通过扩大解释解决，不是类推）

答案：C

...

💡 张明楷原文："不能一概以概念的日常口语含义作为区分扩大解释与类推解释的标准。国民普遍使用'语言暴力''网络暴力''冷暴力'概念，但是，如果认为刑法分则中的'暴力'包括'语言暴力''网络暴力''冷暴力'，则必然是类推解释。"扩大解释在射程内，类推在射程外。

填空题。处罚适正性中的"禁止处罚不当罚的行为"——刑事立法的四步审查法。

1. 目的是否具有合理性？（保护法益的需要？合宪？有重要价值？明确具体？）
2. 刑罚是不是达到合理目的的有效手段？
3. 是否存在替代刑罚的手段？（非刑罚手段能否有效保护法益？利弊权衡？）
4. 利用刑罚保护法益的同时可能造成何种损害？（附随萎缩效果必须明显小于所追求的利益）

...

💡 四步记：目的→手段→替代→副作用。不符合任一步=不应入罪。来源于普鲁士行政法的比例原则，但在刑法上更为严格——刑罚副作用必须明显小于收益，才能动用。

辨析题。关于实质解释论，下列哪一说法符合张明楷的观点？

- A. 实质解释论就是类推解释，违反罪刑法定原则 ❌ ("断言实质解释违反罪刑法定原则，或许出于偏见，也许基于误解")
- B. 实质解释论主张超出构成要件范围进行实质考虑 ❌ ("并非主张超出构成要件的范围进行实质的考虑")
- C. 实质解释论要求将符合字面含义但不值得科处刑罚的行为排除在构成要件之外 ✅ (实质解释三点内容之第二点)
- D. 只有通过扩大解释才能填补的漏洞才是真正的漏洞，必须由立法填补 ❌ ("只有通过类推解释才能填补的漏洞，才是真正的漏洞")

答案：C

. . .

💡 实质解释三点内容：①以保护法益为指导解释构成要件；②将不值得科处刑罚的行为排除在构成要件之外；③在罪刑法定前提下可作不利于被告人的扩大解释。D项致命错误：类推解释→真正的漏洞（须立法填补）；扩大解释→不是真正的漏洞。

匹配题。请将左列描述与右列法益类型正确匹配。

左列	右列
1. 所有个人都能平等享受、不可分配、个别人不法不会使其丧失	D. 集体法益
2. 以国家作为法律人格者所拥有的公法益	A. 国家法益
3. 以社会整体作为法律人格者所拥有的公共利益	B. 社会法益
4. 由自然人所拥有、由刑法保护的重要生活利益	C. 个人法益
5. 张明楷的定义=超个人法益中被累积犯所侵犯的法益	D. 集体法益

答案：1→D, 2→A, 3→B, 4→C, 5→D

. . .

💡 法益分类口诀：国家=公权力主体（国家安全、国家存在条件）；社会=社会整体公共利益；个人=自然人生命身体财产自由；集体=超个人法益中累积犯侵犯的那种（不可分配、需要多数人侵害才丧失）。注意：集体法益≠所有超个人法益，公共危险犯（如放火）就不是集体法益。

快速自测——第二章核心数字与概念速查。

1. 罪刑法定法律渊源时间线：1215（年）→1789（年）→1810（年）
2. 形式侧面四项：法律主义、禁止事后法、禁止类推解释、禁止不定（期）刑
3. 类推vs扩大八个判断标准中第一个：用语可能具有的含义（同时考虑处罚必要性）
4. 法益界定五原则：与利益相关、与法相关、具有可侵害性、与人相关、与宪法相关
5. 法益保护原则对立法两标准：消极标准（删）和积极标准（增）
6. 消极责任主义的核心：责任是刑罚的上限

...

💡 一分钟全对=第二章通关。这六问覆盖本章最容易被忽略的细节——时间数字、分类清单、核心命题。考试前过一遍就够了。

第三章 刑法的适用范围

第一节 刑法的空间适用范围

属地管辖原则——填空。刑法第6条第1款：

"凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。"

"领域"包括领陆、领水和领空。"法律有特别规定"不适用本法包括哪三种情形？其中哪一种才是属地管辖原则的真正例外？

...

"法律有特别规定"三种情形：

1. 不适用中国刑法（广义）：享有外交特权和豁免权的外国人→通过外交途径解决（刑法第11条）← 这是属地管辖的真正例外
2. 不适用中国内地（大陆）刑法：香港、澳门、台湾→"一国两制"，适用当地刑法（不是例外，只是事实上的限制）
3. 不适用中国刑法典部分条文：特别刑法优于普通法时的法条竞合；民族自治地方的变通或补充规定（不是例外，只是适用刑法典的例外）

💡 一句话：只有外交豁免才是真"例外"，港澳台只是"特区"，变通只是"用哪条"的问题。领地三件套=领陆+领水+领空。

属地管辖的补充——填空。

刑法第6条第2款："凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。"

船舶、航空器不论航行或停放于何处，都适用旗国刑法，这被称为旗国主义。这是属地管辖原则的补充或扩张。

民族自治地方的变通规定由自治区或者省的人民代表大会制定，报请全国人大常委会批准施行，且必须符合刑法的基本原则。

. . .
"中华人民共和国船舶或航空器"的范围：不仅包括悬挂中国国旗的，还包括悬挂中国国徽等表明中国所有标志的，以及没有悬挂任何标志但事实上属于中国国家、法人或国民所有的。位于公海上的石油钻井台→与船舶适用同样原则。

国际列车：按我国与相关国家签订的管辖协定确定；无协定→列车行驶在我国境内时发生的犯罪=在我国领域内犯罪。

驻外使领馆：不可一概而论，需考虑犯罪主体身份、犯罪性质等因素，按相关协定解决。

💡 船舶航空器=浮动领土。旗国主义=国旗飘到哪，刑法管到哪。

犯罪地的确定——填空。我国采取遍在说（刑法第6条第3款）。

"犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。"

仅一部分行为或一部分结果发生在我国→也认为是在我国领域内犯罪。

单纯的过境地既不是行为地也不是结果地。例如：甲从东京寄敲诈信给巴黎的乙，信件过境中国→中国只是过境地。

. . .

四种学说对比：行为地说（只看行为地）→ 结果地说（只看结果地）→ 中间地说（行为→结果的通过地，实为结果地补充）→ 遍在说（我国采用，任一项即可）

"结果"的广义理解：既包括构成要件的基本实害结果与加重结果，也包括具体危险、刑法规范禁止的结果、客观处罚条件、超过要素的结果。如故意杀人未遂但造成伤害结果，伤害结果发生在我国→适用我国刑法。

网络犯罪的特殊问题：A在甲国网络传播淫秽作品，中国公民能从网上观看→结果已发生在中国。但需国际社会共同努力。当下处理：实害结果与具体危险发生在我国→适用我国刑法；但行为地国不处罚该行为→不应适用我国刑法。

💡 遍在说=行为地和结果地"只要有一个在中国"就归我们管。但"路过"（过境）不算。

属人管辖原则——填空。刑法第7条：

1. 国家工作人员和军人在领域外犯我国刑法规定之罪的，无限制地适用中国刑法。
2. 上述人员以外的中国公民在领域外犯罪→原则上适用中国刑法；但最高刑为3年以下有期徒刑的，可以不予追究。

张明楷补充：虽然条文没写双重犯罪原则，但如果中国公民在国外行为没有触犯所在地国刑法且未侵犯我国法益→应当类推适用刑法第8条的但书，不追究刑事责任。但被害人是中国公民时不需要双重犯罪原则。

...

我国采取的是有限制的属人管辖（除国家工作人员和军人外，只对严重犯罪行使管辖权）。

新国民问题：外国人取得中国国籍后，发现其以前在国外犯罪且未过追诉时效→适用我国刑法（"中华人民共和国公民"不限于行为时，包括裁判时）。但所犯之罪按犯罪地法律不受处罚→除外。

三种理论根据：国家利益符合说（唤醒守法意识）、忠诚义务说（效忠母国）、代理处罚说（本国不引渡=代理外国处罚）。

💡 属人=管自家人。国家工作人员+军人=全管；普通国民=严重犯罪才管（最高刑3年以上）。

保护管辖原则——填空。刑法第8条：

"外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为3年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。"

适用保护管辖必须同时具备哪三个条件？

- ①所犯之罪侵犯了我国国家或公民的法益
- ②按我国刑法最低刑为3年以上有期徒刑（严重犯罪）
- ③按照犯罪地的法律也应受处罚（双重犯罪原则）。

...

保护管辖的实质意义：保护本国利益与本国公民的法益。因侵犯本国利益的=国家保护原则；因侵犯本国公民法益的=国民保护原则（消极的属人管辖）。

反恐例外：《反恐怖主义法》第11条→对危害我国国家、公民或机构的恐怖活动犯罪行使管辖权，不受上述②③条件限制。同理《反洗钱法》第12条、《反间谍法》第4条第2款也有类似例外规定。

💡 保护管辖=外国人在外国欺负了我们的人或国家→我们也要管！条件：欺负得够狠（3年以上）+ 当地法律也认为是犯罪。

普遍管辖原则——填空。刑法第9条：

"对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的，适用本法。"

行使普遍管辖权的三个限制条件是什么？

- ①我国行使普遍管辖权的犯罪应是国际条约所规定的罪行
- ②我国是相关条约的缔约国或参加国
- ③国内刑法也将该行为规定为犯罪。

实体法适用根据是国内刑法而非国际条约（因为国际条约没有规定法定刑）。

. . .

四种做法对比：绝对的世界主义（不问任何条件一概适用）→自主的世界主义（自主确定范围）→附条件的世界主义（我国采取，做一定限制）→义务的世界主义（只在义务范围内行使）。

原则上应要求罪犯出现在我国领域内。典型国际条约：《海牙公约》（非法劫持航空器）、《蒙特利尔公约》（危害民航安全）。

💡 普遍管辖=国际公敌（海盗、劫机、贩毒），谁抓到谁管。但必须三步齐：条约有规定+我国签了+国内也写了。

对国外刑事判决的承认——填空。刑法第10条：

"凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻处罚。"

我国采取的是消极承认。内地居民在香港、澳门、台湾受刑事审判→不宜采取消极承认。

. . .

积极承认：外国确定的有罪判决=本国判决→执行外国判决，已执行完毕或宣告无罪则本国不再追诉（欧洲多国采用）。理论基础：国际协同+人权保障+避免双重处罚。

消极承认（我国）：外国判决不制约本国刑罚权→仍可追诉，但考虑已受刑罚事实（可免除或减轻）。理论基础：国家主权原则。

港澳台特别规则：香港、澳门、台湾的审判不是"外国审判"→类推适用消极承认不利于被告人→违反罪刑法定。应从"一国"角度采取积极承认。

💡 消极承认=外国判了不算完，我们还能再追究，只是给"折扣"。核心考虑：国家主权优先。

第二节 刑法的时间适用范围

刑法的生效与失效——填空。

生效两种情形：自公布之日起生效；公布后间隔一段时间才生效（如现行刑法典1997年3月14日公布，1997年10月1日起生效）。后者更合理，因为要使规范产生实效，就得使人们事先了解规范的存在及其内容。

失效两种情形：由立法机关明文宣布废止；新法的施行使原有法律自然失效。

. . .

修正案间隔期实例：《刑法修正案（八）》2011.2.25公布→5.1施行；《刑法修正案（九）》2015.8.29公布→11.1施行；《刑法修正案（十一）》2020.12.26公布→2021.3.1施行；《刑法修正案（十二）》2023.12.29公布→2024.3.1施行。

💡 公布 ≠ 生效。像学校发新校规——先贴公告让大家看，过一两个月才正式执行。这保障了预测可能性。

从旧兼从轻原则（核心）——填空。刑法第12条采取从旧兼从轻原则。

基本含义：原则上适用行为时的法律（从旧），但新法对行为人有利时适用新法（从轻）。

四种情形分别怎么处理？

1. 行为时不犯罪、新法为犯罪 → 适用旧法，无溯及力（无罪）
2. 行为时犯罪、新法不犯罪 → 适用新法，有溯及力（无罪）
3. 新旧都犯罪且应追诉 → 原则上适用旧法，新法处刑较轻 → 适用新法
4. 已生效判决 → 继续有效

. . .

"处刑较轻"的比较方法：法定刑较轻 → 先比法定最高刑 → 若相同比法定最低刑 → 若还相同比附加刑（有无、种类、数量、必科/选科）。不是比个案量刑轻重！

重要：量刑规则也要从轻：决定适用新法还是旧法时，不仅比法定刑，还要比量刑规则。不允许"表面上适用较轻法定刑、实际上适用较重量刑规则"。例如：新法法定刑轻但量刑规则重 → 不能因为法定刑轻就适用新法而受更重处罚。

罪刑相适应 vs 从旧兼从轻：从旧兼从轻是罪刑法定原则的重要内容，罪刑相适应原则受其制约。只要适用旧法符合从旧兼从轻，就不得以"罪刑相适应"为由绕过。

💡 从旧=法不溯及既往（保护预测）；从轻=新法更温柔就用新的（保护自由）。比轻重先看最高刑 → 最低刑 → 附加刑。

从旧兼从轻——新旧法同时适用与部分适用。填空。

新法条文既有有利规定又有不利规定时 → 适用有利的规定，不适用不利的规定。这可能对一个行为同时适用旧法和新法（组装原则）。

举例：《刑法修正案（七）》修改的逃税罪——第1款扩大处罚范围（不利）+第4款增设处罚阻却事由（有利）。如何处理？适用旧法第1款（从旧，不定罪范围窄）+ 新法第4款（从轻，有处罚阻却事由）= 整体有利于被告人。

新法公布后生效前，如果新法有利于行为人，司法机关不得抢在新法生效前按旧法做出不利判决。为什么？

. . .

不得抢跑的核心理由：适用法条不仅是适用字面含义，还应适用法条精神。立法机关已修改 → 旧法精神也随之改变 → 按旧法字面含义判不符合新法精神 → 属于适用法律错误。已做的此类判决应通过审判监督程序改正。

经典例：2011年《刑法修正案（八）》删除盗窃罪死刑（5月1日生效）。某人在2010年盗窃金融机构数额特别巨大→2011年2-4月审理→不得判处死刑。

另一经典例：2019年修订《药品管理法》不再将未经批准进口的药品规定为假药（12月1日施行）→2019年8-11月审理此类案件→不得认定为销售假药罪（新法精神已公之于众）。

💡 从旧兼从轻是"乐高原则"——左手用旧法的定罪，右手用新法的量刑，怎么对被告人有利怎么拼。新法一公布，旧法精神就变了，不能抢跑。

从旧兼从轻——三个延伸规则。填空。

1. 行为连续或持续到新法生效以后→适用新法。
2. 按照审判监督程序重新审判的案件→适用行为时的法律。
3. 刑法修正导致罪名变更→如果适用修正前的刑法条文→应适用修正前的罪名。

保安处分的适用也遵循从旧兼从轻原则。

...

行为持续举例：旧法不认为犯罪、新法认为犯罪，但行为连续或持续到新法生效后→适用新法。同理，旧条文不认为犯罪、修正后条文认为犯罪，行为持续到修正案生效后→适用新法。

罪名变更举例：2015年11月1日前非法获取公民个人信息→适用修正前刑法第253条之一→仍用"非法获取公民个人信息罪"的罪名（不是"侵犯公民个人信息罪"），因为行为时不存在后一罪名。

保安处分举例：《刑法修正案（九）》增设第37条之一从业禁止→对于2015年10月31日以前利用职业便利实施犯罪的→不能适用该保安处分。

💡 三条延伸记清楚：持续跨线→用新法；再审翻案→用旧法；罪名变了→行为时叫啥还叫啥。

主刑有利但附加刑不利时怎么处理？填空。

例如：甲在《刑法修正案（九）》生效前贪污4万元→行为时旧法法定刑为"一年以上七年以下有期徒刑"→新法为"三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金"。对甲能否并处罚金？

张明楷认为能，因为新法整体法定刑较轻就要适用新法，既然适用新法就应完整适用，仅适用某一款或某一项的部分内容是不合适的。

溯及力是就具体行为而言，还是就整体案件而言？→具体行为。

...

完整适用原则：不能把一条拆开——取主刑从轻的部分、丢附加刑从重的部分。既然选了新法，就整条适用。（刑法第12条："如果本法.....处罚较轻的，适用本法"，意味着适用完整的"本法"）

溯及力针对具体行为：例如甲2023年11月教唆乙非法经营同类营业，乙2024年3月1日后实施→正犯乙适用新法（行为在新法后），但教唆犯甲的行为发生在修正案前→对甲不能适用新法以教唆犯处罚。

💡 选新法就整条吃，不能挑食。溯及力看行为时点，不是看同案其他人。

有权解释的时间效力——填空。

正式解释不是刑法本身，因此不存在从旧兼从轻的问题。

四种情形的处理：

1. 行为时无解释、审理时有→适用正式解释
 2. 行为时无解释、实务不按犯罪处理、后来解释为犯罪→认定行为人不存在违法性认识的可能性→不以犯罪论处
 3. 旧解释不犯罪、新解释犯罪→按法律认识错误处理→排除有责性
 4. 旧解释犯罪、新解释不犯罪→不以犯罪论处（因为该行为本来就没有违反刑法）
- ...

为什么不存在从旧兼从轻：正式解释不是刑法渊源。如果承认→等于司法解释与立法同一效力位阶→违背立法权与司法权分离的法治原则。不能以错误适用刑法为代价来肯定以往错误解释的效力。

司法犯罪化后立法变更（高空抛物为例）：《刑法修正案（十一）》前，司法解释将高空抛物认定为以危险方法危害公共安全罪→《刑法修正案（十一）》增设高空抛物罪（较轻法定刑）→对修正案施行前的高空抛物行为→如果本来不构成其他明文规定的犯罪→只能宣告无罪（不能适用新法按高空抛物罪处理，更不能维持错误司法解释）。

💡 司法解释只是“解释”，不是“造法”。错了就改——之前错判的不等于以后也要错下去。

限时法是只在一定时期内实施的法律。空白刑罚规范不是限时法。

空白刑法规范补充规范废止后→行为依行为时的法律处理。如果废止后行为不构成犯罪→依废止后的法律→不当犯罪处理。

...

动机说（限时法补充）：如果限时法因立法者认为该行为不再具有可罚性而废除→时限过后发现的行为不能依限时法处理。如果限时法只是因某种状态消失而废除→时限过后仍可依限时法处理。

💡 限时法是“限时特供”的法律，过期可能不候。空白刑罚规范不是限时法（它不是刑法本身）。补充规范废止→按行为时处理，但如果废止后不犯罪→就从轻不当犯罪。

全章四原则速记：属地管辖（领域内）→ 属人管辖（自家人）→ 保护管辖（被欺负了）→ 普遍管辖（国际公敌）

关键数字：属人管辖普通公民界限 "3年"；保护管辖门槛 "3年"；从旧兼从轻比较顺序：先比最高刑 → 再比最低刑 → 再比附加刑。

...

四原则递进关系：属地管辖是基础（国内犯）→ 属人管辖是第一补充（中国人在国外）→ 保护管辖是第二补充（外国人欺负中国）→ 普遍管辖是最后补充（国际犯罪，谁抓到谁管）。四者形成完整无死角的管辖网络。

💡 空间效力=画圈（在哪儿管、管谁）。时间效力=画线（从什么时候管到什么时候）。圈要画全，线不能往回画。

辨析题。下列情形，中国刑法是否可以适用？选出最终结论全部正确的一项。

- ① 美国公民甲在飞往东京的中国国际航班上盗窃——可以适用 ☒（刑法第6条第2款，旗国主义：船舶航空器=浮动领土）
- ② 中国公民乙（普通公民）在泰国赌博，泰国不处罚赌博——不可适用 ☒（张明楷补充：行为未触犯所在地国刑法+未侵犯我国法益→不宜适用，应类推适用第8条但书）
- ③ 日本公民丙在公海上对中国渔船实施海盗行为——可以适用 ☒（刑法第9条，海盗是国际条约规定的罪行，我国是缔约国）
- ④ 中国国家工作人员丁在法国受贿——必须适用 ☒（刑法第7条，国家工作人员域外犯罪，无限制地适用中国刑法）

- A. ①②③④全对 ☒
- B. 仅①③④对
- C. 仅①②④对
- D. 仅①④对

答案：A

...

💡 四原则口诀：领域内=属地（含船舶航空器）；中国人=属人（国家工作人员全管，普通公民3年以下可不追）；欺负中国=保护（三条件）；国际公敌=普遍（三限）。一题串起四个管辖原则。

辨析题。甲在《刑法修正案（九）》生效前贪污4万元，修正案生效后接受审判。旧法："一年以上七年以下有期徒刑"（无附加刑）。新法："三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金"。以下哪一处理正确？

- A. 适用旧法，不并处罚金（避免附加刑，虽刑期可能更长） ☒
- B. 适用新法，并处罚金（新法整体刑轻，完整适用） ☒

C. 适用新法的法定刑但不并处罚金（拆开选用有利部分）✗

D. 由法官综合裁量 ✗

答案：B

...

💡 张明楷原文："新条文规定的法定刑整体较轻时，就要适用新条文（不能因为新条文规定的附加刑重于旧条文，就不适用新条文）。既然新条文规定并处罚金，在适用新条文时应当对甲并处罚金。仅适用某一款或者某一项的部分内容是不合适的。"核心：选新法就整条吃，不能挑食。

辨析题。《刑法修正案（七）》修改逃税罪：第1款扩大了处罚范围（不利），第4款增设了处罚阻却事由（有利）。对修正案施行前的偷税行为，下列哪一处理正确？

A. 全部适用旧法（旧法对被告人有利，只能从旧）✗

B. 全部适用新法（新法有有利条款，只能从新）✗

C. 适用旧法第1款（从旧，不定罪范围窄）+ 新法第4款（从轻，有处罚阻却事由）✓

D. 适用新法第1款（扩大处罚）+ 旧法第4款（没有阻却事由）✗

答案：C

...

💡 这是"新旧法同时适用"的经典案例。张明楷："根据从旧兼从轻的原则，对于修正案施行前行为的认定应当适用修改前的第1款（从旧），但同时必须适用修改后的第4款（从轻）。"左手用旧法的定罪，右手用新法的量刑——怎么对被告人有利怎么来。这被称为"组装原则"。

辨析题。2011年《刑法修正案（八）》2月25日公布、5月1日生效，删除了盗窃罪死刑。甲在2010年盗窃金融机构数额特别巨大，法院在2011年3月审理。能否判甲死刑？

A. 能——新法尚未生效，应按行为时旧法处理 ✗

B. 不能——新法虽未生效但法条精神已改变，按旧法字面含义判不符合新法精神 ✓

C. 能——但应减轻为死缓 ✗

D. 不能——但理由是从旧兼从轻原则 ✗

答案：B

...

💡 张明楷认为不能判死刑，但理由不是"从旧兼从轻"（新法尚未生效，不适用第12条），而是——"适用法条并不只是适用法条的字面含义，还应当适用法条的精神。既然立法机关已经修改了第264条，就表明对盗窃罪不应当适用死刑……不符合法条精神。"已做此类判决的应通过审判监督程序改正，属于适用法律错误。注意这个理由和第12条从旧兼从轻的区别。

辨析题。关于有权解释的时间效力，张明楷的核心观点是：正式解释不存在从旧兼从轻的问题。理由是：正式解释不是刑法本身，不能以错误适用刑法为代价来肯定以往错误解释的效力。如果旧解释认为不是犯罪、新解释认为是犯罪→行为人按法律认识错误处理→排除有责性。

· · ·

💡 张明楷明确反对将正式解释纳入从旧兼从轻："否则，会出现以错误地适用刑法为代价来肯定以往的错误解释的效力这一不可思议的现象。不仅如此，承认司法解释适用禁止溯及既往的原则，还会形成司法解释与立法处于同一效力位阶的不当局面，违背立法权与司法权相分离的法治原则。"

第四章 犯罪概说

第一节 犯罪的一般概念

犯罪的实质定义——填空。我国刑法第13条：

"一切危害……的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。"

从文理上说，犯罪有两个基本特征：社会危害性与依照法律应受刑罚处罚性。

从论理（实质）上说，犯罪的实体是不法与责任。其中，不法是前提，责任是对不法的责任。

· · ·

各国犯罪定义立法例：①形式定义（法国1810年：违警罪/轻罪/重罪）；②实质定义（苏俄1922年：危害社会的作为或不作为）；③形式+实质统一（我国刑法第13条）。

"依照法律应当受刑罚处罚"的三层意思：①行为必须被刑法类型化为构成要件（罪刑法定）；②符合正当化事由或情节显著轻微→不应受处罚（法益保护+谦抑性）；③行为人具有故意/过失、达到法定年龄、有责任能力、具有违法性认识可能性与期待可能性（责任主义）。

犯罪概念在不同语境下含义不同：如刑法第20条第3款的"暴力犯罪"=不法意义上的犯罪（不要求侵害者具有责任）；第115条第2款"过失犯前款罪"中的"罪"=仅指客观不法行为。

💡 犯罪=不法+责任。不法回答"做了什么坏事"，责任回答"能不能怪你"。11岁小孩杀人=有不法但无责任→不构成犯罪，但可以制止和防卫。

但书——填空。刑法第13条但书："情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。"

"情节"是指行为过程中影响不法程度的各种情况（如法益的性质、行为的危险与实害结果等），不应包括行为前后的表现。

张明楷主张入罪限制条件说：符合但书规定的行为，原本就不符合犯罪的构成要件。

...

"但书"不应直接作为出罪根据的五种不当做法：

- ①行为完全符合犯罪构成→不能以但书宣告无罪（如安乐死、醉酒驾驶）
- ②对构成要件形式化理解→先认为符合构成要件，再用但书出罪（应直接认为不符合构成要件）
- ③原本不符合构成要件→以但书为根据出罪（多此一举，应直接说不符构成要件）
- ④有违法阻却事由→用但书出罪（应用违法阻却事由）
- ⑤把自首、坦白、赔偿等罪后表现作为但书出罪依据（罪后表现只影响量刑，不影响定罪）

💡 但书不是"免死金牌"，是构成要件解释的指南。行为不值得罚=本来就不符合犯罪的模板，不需要但书来"救"。

第二节 犯罪的基本分类

犯罪的理论分类——对号入座。

- 1. 重罪 vs 轻罪：以法定刑为标准。张明楷标准：法定最低刑为3年以上有期徒刑的为重罪。
- 2. 形式犯 vs 实质犯：张明楷认为不存在形式犯，所有犯罪都是实质犯（因为任何行为都是因严重侵犯法益才被规定为犯罪）。
- 3. 自然犯 vs 法定犯：自然犯是违反伦理道德的犯罪（如杀人、盗窃）；法定犯是违反行政法规的犯罪（以违反行政法/经济法为前提）。
- 4. 隔隙犯 vs 非隔隙犯：隔隙犯=实行行为与结果之间存在时间或场所的间隔。

...

重罪轻罪区分意义：刑法第7条（属人管辖"3年以下可不追究"）、第72条（缓刑条件）、刑事诉讼法简易程序等都以3年为界。

自然犯 vs 法定犯区分意义：①判断违法性认识可能性时（自然犯容易被认识，法定犯相反）；②判断罪行轻重时（自然犯>法定犯）；③法定犯以违反前置法为前提。但二者区分具有相对性。

隔隙犯细分：隔时犯（时间间隔→以行为时为犯罪时）、隔地犯（场所间隔→行为地与结果地均为犯罪地）。

💡 重罪轻罪看3年（法宝数字）。自然犯=人人知道是坏事；法定犯=法律规定才是坏事。隔隙犯=行为和结果"天各一方"。

犯罪的法定分类——对号入座。

1. 国事犯罪 vs 普通犯罪：前者=刑法分则第一章；后者=第二章至第十章。
2. 自然人犯罪 vs 单位犯罪：单位犯罪以刑法明文规定为前提。
3. 身份犯 vs 非身份犯：真正身份犯=特殊身份是构成要件要素（如贪污罪的国家工作人员）；不真正身份犯=特殊身份只是刑罚加减事由（如诬告陷害罪的国家机关工作人员从重）。
4. 亲告罪 vs 非亲告罪：亲告罪=告诉才处理。告诉是诉讼条件，不同于自诉。
5. 基本犯 vs 加重犯 vs 减轻犯：加重犯包括结果加重犯与情节加重犯。

...

亲告罪三个特点：

- ①只侵害个人法益且较轻微
- ②往往发生在亲属、邻居、同事之间
- ③涉及被害人名誉，任意诉讼可能损害名誉

告诉才处理 ≠ 自诉：告诉才处理是对国家追诉原则的限制（没有被害人告诉就不能进入刑事诉讼）；自诉是国家追诉原则的例外（为减轻追诉机关负担）。日本实行国家追诉主义、没有自诉制度，但同样有亲告罪。

基本犯/加重犯/减轻犯举例：抢劫罪基本犯→3-10年；入户抢劫（情节加重犯）→10年以上；抢劫致人死亡（结果加重犯）→最高死刑。

💡 身份犯=不是谁都能犯的罪。亲告罪=被害人告诉，国家不管。加重犯=基本款+升级条件=更重的刑。

第三节 犯罪的成立条件

德国三阶层体系——填空。

三阶层：构成要件符合性 → 违法性 → 有责性

判断顺序：由客观到主观、由抽象到具体、由定型到非定型。

古典体系的核心命题：不法是客观的，责任是主观的。但这个命题后来被打破了一一目的行为论将故意从责任移到构成要件（成为主观违法要素）。

...

三阶层体系演变：

- 古典体系（贝林、李斯特）：纯客观构成要件→纯主观责任（心理责任论）
- 新古典体系（麦耶）：目的等主观要素进入构成要件→规范的心理责任论
- 目的行为论（韦尔策尔）：故意完全移到构成要件→纯规范责任论
- 折中体系（罗克辛）：故意双重地位+客观归责理论

三种构成要件概念（德国）：①体系构成要件=成立犯罪条件之一；②错误构成要件=故意必须认识到的客观构成要件；③保障构成要件=保障罪刑法定实现所要求的全部要件。

💡 三阶层像闯三关：先看"做了模板里的事吗"→再看"有合法理由吗"→最后问"能怪你吗"。顺序不能乱。

我国传统四要件体系——填空。

四要件：犯罪客体 + 犯罪客观方面 + 犯罪主体 + 犯罪主观方面。源于苏联体系。

四要件之外再讨论正当防卫、紧急避险等排除犯罪的事由。

犯罪客体=刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系。张明楷认为应当用法益概念取代，理由是什么？

...

张明楷对四要件体系的五条批评：

1. 犯罪客体不应作为构成要件——客体=法益=条文目的，将目的本身作为要件不合适。且客体本身没有具体要素，交由法官评价会损及罪刑法定机能。
2. 没有区分不法与责任——四个要件只能综合作用，否认"没有责任的不法"，无法说明对精神病人的防卫、无法合理处理共犯问题。
3. 责任要素与预防要素不分——故意/过失是责任要素，累犯/惯犯是预防要素，四要件混为一谈。
4. 难以从客观到主观认定犯罪——有的教科书按"主体→主观→客观→客体"排列，从主观到客观认定犯罪，回到主观主义立场。
5. 正当防卫等被排到最后——割裂了违法性判断，容易导致将正当防卫认定为符合犯罪构成后竟认为需用"社会危害性"出罪。

💡 四个要件平起平坐=四个和尚没水喝。不法+责任二分=有主有次，各司其职。

张明楷的犯罪构成体系——填空。

本书采取形式上的两阶层、实际上的三阶层体系。

犯罪构成由不法与责任组成。

1. 不法：构成要件符合性 + 违法阻却事由。构成要件是违法类型。
2. 责任：对不法的非难可能性。包括需要积极判断的要素（如故意、过失、目的）和只需消极判断的要素（如违法性认识的可能性与期待可能性）。

认定犯罪必须从客观到主观、从不法到责任。

...

为什么采取这个体系？七条理由：

- ①犯罪的实体就是不法和责任——对应必须有表明不法的要件和表明责任的要素
- ②坚持客观违法性论——11岁的人杀人不以犯罪论处不是因为不违法，而是因为没责任
- ③处理好不法与责任的关系——特殊身份是违法要素（不是主观要素），年龄/责任能力是

责任要素

- ④在责任判断前先判断违法阻却事由——实践中对正当防卫和构成要件判断几乎同时进行
- ⑤区分违法阻却事由与责任阻却事由——可制止不法行为（但对正当防卫不能制止），保安处分只适用于有不法但无责任者
- ⑥使"犯罪"概念保持相对性——不法层面犯罪（如防卫对象）vs 最终意义犯罪（不法+责任）
- ⑦体系经济性——避免重复和浪费司法资源

💡 两阶层本质是三阶层：构成要件符合性→违法阻却事由→责任。因为先把不法合在一层，认定路径依然是三步走。

犯罪构成概念总结——填空。

犯罪构成是刑法规定的，反映行为的法益侵犯性与非难可能性，而为该行为成立犯罪所必须具备的不法要件和责任要素的有机整体。

犯罪构成 ≠ 犯罪构成事实。前者是法律规定，后者是具体案件事实。

犯罪构成是认定犯罪的唯一法律标准。行为符合犯罪构成是认定犯罪的唯一根据。

...

犯罪构成的六项机能：

- ①区分罪与非罪（人权保障机能）
- ②区分此罪与彼罪（犯罪个别化机能）
- ③区分一罪与数罪（罪数区分机能）
- ④区分重罪与轻罪（罪行评价机能）
- ⑤实现罪刑法定主义（罪刑法定主义机能）
- ⑥保障公民自由（法治机能）

本书术语约定：犯罪构成 ≠ 构成要件。构成要件=违法构成要件=客观构成要件（三个概念等同使用）。责任要素 ≠ 责任要件（不使用"主观构成要件"表述）。

💡 犯罪构成=法定的犯罪模板。模板写在刑法里，具体案件要来"对号入座"。对上就成立犯罪，对不上就不成立。唯一标准，没有第二条路。

国外的其他犯罪论体系——填空。

法国：二元论体系。"犯罪"部分包括法定要素与事实要素；"责任"部分包括故意/过失、行为主体、责任减轻/免除事由。同样区分了违法与责任。

英美："犯罪成立的一般要件" + "抗辩事由"体系。一般要件=犯行（actus reus）+犯意（mens rea）。抗辩事由分为正当事由（正当防卫等）与免责事由（未成年、精神障碍等）。

...

法国体系简述：法定要素=罪刑法定原则要求的内容（正当防卫等使法定要素消灭）；事实要素≈客观构成要件（含未遂、中止）。责任部分=故意/过失+自然人与法人+精神错乱/被强制/认识错误等免责事由。

英美体系简述：犯行≈客观构成要件；犯意=故意与过失。正当事由=行为本身不违法（正当防卫、紧急避险）；免责事由=行为违法但行为人不应受罚（未成年、精神障碍、被胁迫）。

共同点：无论德国三阶层、法国二元论还是英美抗辩体系，都区分了违法与责任。这说明区分不法与责任是刑法学的普遍共识。

💡 法德英美，体系各异，但殊途同归：都先看"行为本身是不是坏事"（不法），再看"能不能怪到行为人头上"（责任）。

四要件体系的其他改良方案有哪些？张明楷如何评价？

改良一：罪体（罪体构成要素-罪体排除事由）→罪责→罪量。张明楷评价：罪量都是不法要素，应当放在不法中讨论，不必独立。

改良二：犯罪客观要件→犯罪主观要件→犯罪排除事由。张明楷评价：将犯罪的实体停留在客观与主观两个描述性概念，导致判断成为没有目标指引的纯形式判断。

改良三：四要件=积极要件；正当防卫等=消极要件。张明楷评价：这没有对四要件进行实质改造，传统四要件也是先积极后消极。

...

改良一的实质：大体属于两阶层体系（罪体=不法）。张明楷赞同方向，只反对把罪量单列。

改良二的缺陷：客观与主观只是描述性概念，而不法与责任才是评价性概念。没有"法益侵犯"作为目标指引的客观判断=盲目判断。

改良三的缺陷：司法实践将大量正当防卫认定为犯罪的事实表明，这种"先积极后消极"的排列容易导致在肯定积极要件后就直接认定为犯罪。

张明楷的最终立场：要克服四要件体系的根本缺陷，只能采取三阶层或两阶层（不法与责任）体系。

💡 各种改良方案都在往"不法+责任二分"的方向靠。说明这是一个共识方向，区别只在于拐了多少个弯。

法国、英美、德国三阶层 + 我国改良方案——它们有什么共同结论？

填空：不管哪个国家、哪种体系，都区分了违法（不法）与责任。

这说明：区分不法与责任是刑法学的普遍共识。

· · ·

为什么要区分不法和责任？（本张卡打通前面所有内容）

1. 哲学与社会心理学根据：行为客观上侵害了法益（不法）≠行为人主观上应当受谴责（责任）。两者是不同层面的评价。
2. 与刑法两大机能对应：法益保护机能→判断不法（有没有侵害法益）；自由保障机能→判断责任（能不能怪行为人）。
3. 区分违法阻却事由与责任阻却事由：正当防卫→阻却违法（行为合法）；精神病人杀人→阻却责任（行为违法但不应罚）。前者不能制止，后者可以制止。
4. 妥善解决共犯问题：共犯共同的是"不法"，各算各的"责任"。15岁和20岁一起抢劫→在"不法"层面成立共犯，但责任各自判断。
5. 保安处分制度：对有不法但无责任的人（如精神病人），可施以保安处分；对无不法的人，绝对不能施以保安处分。

💡 不分不法与责任=把"做了什么"和"该不该怪你"搅在一起。搅在一起的结果就是：不知道什么时候能防卫、不知道共犯怎么算、不知道保安处分给谁用。

本章核心概念串讲

犯罪的概念在不同刑法条文中含义不同——填空对号入座。

1. 刑法第13条："一切……危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪。" → 这里的"犯罪"指最终意义（不法+责任）的犯罪。
2. 刑法第20条第3款："对正在进行行凶、杀人、抢劫……的暴力犯罪，采取防卫行为……" → 这里的"犯罪"指不法意义上的犯罪（不要求不法侵害者具有责任）。
3. 刑法第115条第2款："过失犯前款罪的……" → 这里的"罪"仅指客观上符合第1款的构成要件且违法的行为（不要求故意）。
4. 刑法第312条："明知是犯罪所得的赃物……" → 这里的"犯罪"指不法意义上的犯罪。

· · ·

为什么必须承认"犯罪"概念的相对性？

- 如果不承认相对性，刑法第20条第3款的"暴力犯罪"就要求侵害者有责任→对11岁人的杀人行为不能防卫→荒谬。
- 如果不承认相对性，刑法第312条的"犯罪所得"就要求上游行为人具备责任→上游是精神病人盗窃的财物不能被认定为赃物→荒谬。
- 如果不承认相对性，刑法第115条第2款"过失犯前款罪"中的"罪"就要求故意→无法理解该款。

💡 "犯罪"一词在刑法里有三种用法：①完整的犯罪（不法+责任）；②只要求不法（防卫对象、赃物犯罪的上游）；③只要求客观不法（作为过失犯的前提）。读法条时要判断用的是哪一种。

本章与前后章节的关系——填空。

本章 = 第二编犯罪论的"总论章"，承上启下。

承上：犯罪是不法 + 责任 → 对应刑法的两大机能（法益保护 vs 人权保障）→ 对应三大基本原则中的法益保护原则和责任主义。

启下：第五章 = 展开"不法"（构成要件+违法阻却）；第六章 = 展开"责任"（故意/过失+期待可能性等）。

...

本章在全书的定位：

第一章 刑法概说（刑法是什么）

第二章 基本原则（凭什么罚）

第三章 适用范围（管哪管谁）

第四章 犯罪概说（犯罪是什么）← 你现在在这里

第五章 不法（行为违法吗？）← 下两章

第六章 责任（能怪你吗？）

💡 第四章是总论中的总论。把"犯罪=不法+责任"这个公式刻在脑子里，后面两章就是分别展开公式的两半。第五章=左边（不法），第六章=右边（责任）。

张明楷体系 vs 传统四要件——速记对比表。

	张明楷体系	传统四要件
结构	两（三） 阶层	四要件并列
判断顺序	客观→主观	各要件综合判断
犯罪实体	不法+责任	社会危害性（综合）
犯罪客体	=法益（目的）	=社会关系（要件之一）
正当防卫	不法阶层内判断	四要件之后
故意位置	责任要素	主观方面

...

最大区别：传统体系=四个要件拼成一张完整图→"综合"判断→先肯定成立再考虑排除事由。张明楷体系=逐层过滤→先客观后主观→不法层先判断是否违法再判断是否阻却违法→责任层最后把关。两者认定的终点可能相同，但路径的清晰度和对人权的保障程度不同。

💡 四要件=四人并排走，不法+责任=前后排队走。并排容易撞，排队有秩序。

第四章必考速查——填空自测。

- 1. 犯罪的实质定义：社会危害性 + 应受刑罚处罚性的统一（刑法第13条）
- 2. 犯罪的实体：不法 + 责任
- 3. 但书的机能：入罪限制条件说（原本就不符合构成要件）
- 4. 重罪标准：法定最低刑3年以上
- 5. 自然犯 vs 法定犯：前者违反伦理道德，后者违反行政法规
- 6. 亲告罪中的"告诉"是诉讼条件，不同于自诉
- 7. 三阶层顺序：构成要件符合性→违法性→有责性
- 8. 张明楷体系核心：两阶层，由不法和责任组成
- 9. 故意在张明楷体系中是责任要素
- 10. "犯罪"概念有相对性：最终意义和不法意义
- ...

💡 全答对=本章过关。有错→翻回对应卡片重看。记住本章是犯罪论的总门户，"不法+责任"这五个字后面两章天天要见。

辨析题。请将下列条文与"犯罪"的含义正确匹配。

条文	"犯罪"的含义
刑法第13条".....都是犯罪"	B. 最终意义的犯罪（不法+责任）
刑法第20条第3款"暴力犯罪"	A. 不法意义上的犯罪
刑法第115条第2款"过失犯前款罪"	C. 仅指客观上符合构成要件且违法的行为

答案：A（13条→B，20条→A，115条→C）

...

💡 如果不承认"犯罪"概念的相对性→第20条的"暴力犯罪"要求侵害者有责任→对11岁人的杀人行为不能防卫→荒谬。同样第115条第2款如果要求故意→无法理解"过失犯前款罪"。读法条时必须判断用哪种含义。

辨析题。关于但书的正确用法，张明楷采取什么说？

邮政工作人员甲私拆了一封没有重要内容的信，没有造成严重后果。以下哪种处理方式符合张明楷的观点？

- A. ☒ 甲的行为符合私自开拆邮件罪的构成要件，但根据刑法第13条但书"情节显著轻微危害不大"，宣告无罪
- B. ☐ 甲的行为原本就不符合私自开拆邮件罪的构成要件（不值得科处刑罚），直接以不符合构成要件为由宣告无罪

- C. ☒ 甲的行为构成犯罪，但情节轻微，免予刑事处罚
D. ☒ 甲的行为符合构成要件但有违法阻却事由，根据但书宣告无罪

答案：B（入罪限制条件说——“符合但书规定的行为原本就不符合犯罪的构成要件”）

...

💡 张明楷原文：“只能以行为不符合构成要件或者不具备其他犯罪成立条件为由宣告无罪，而不能直接根据但书宣告无罪。”五种不当用法：①完全符合构成要件→不能用但书出罪；②形式化理解构成要件→先认定符合再用但书→应直接说不符构成要件；③原本不符→多此一举用但书；④有违法阻却事由→用但书（应用违法阻却事由）；⑤把自首/坦白等罪后表现作为但书依据（只影响量刑）。

辨析题。关于传统四要件体系与张明楷两阶层体系的对比，下列哪一说法是正确的？

- A. ☒ 四要件体系将正当防卫放在犯罪构成之后讨论，张明楷体系在不法阶层内判断
B. ☒ 张明楷体系将犯罪客体（社会关系）作为独立的构成要件
C. ☒ 四要件体系严格区分了不法与责任
D. ☒ 张明楷体系将故意放在构成要件中，作为主观违法要素

答案：A（A对：四要件在四个要件之后讨论正当防卫；张明楷体系在不法阶层内逐层判断。B错：张明楷认为“犯罪客体=法益=条文目的，将目的本身作为要件不合适”。C错：四要件体系没有将犯罪实体区分为不法与责任。D错：张明楷将故意作为责任要素。）

...

💡 四要件=四个和尚并排走；两阶层=前后排队走。最大区别：四要件“综合判断”→容易先肯定后找排除理由；两阶层“逐层过滤”→先客观后主观→先不法后责任。

辨析题。关于亲告罪，下列哪一说法正确？

- A. ☒ 告诉才处理=只能向人民法院提起自诉
B. ☒ 告诉才处理是对国家追诉原则的限制（诉讼条件），自诉是国家追诉原则的例外
C. ☒ 亲告罪中的“告诉”只能向法院提出
D. ☒ 被害人告诉的，检察机关仍可提起公诉

答案：B（告诉才处理=诉讼条件，没有被害人告诉就不能进入刑事诉讼；自诉=为减轻追诉机关负担。告诉可向公安机关、检察机关或法院提出。被害人不告→公安、司法机关不得进入刑事诉讼。）

...

💡 张明楷原文：“告诉才处理是对国家追诉原则的限制（诉讼条件），而自诉是国家追诉原则的例外，只是为了减轻追诉机关的负担。”日本实行国家追诉主义、没有自诉制度，但同样有亲告罪——说明告诉才处理≠自诉。被害人不告→公安、检察机关不能进入刑事诉讼。

第五章 不法

第一节 不法概述

形式的违法性与实质的违法性——填空。

形式的违法性：行为违反实定法的禁止或命令。

实质的违法性：用"违反实定法"以外的实质根据来说明违法性。张明楷采取法益侵害说。三种学说分别是：伦理规范违反说、法规范维护说、法益侵害说。

...

三种学说的缺陷：伦理规范违反说→内容不明确，容易处罚思想。法规范维护说→无法说明违法程度（抢劫和盗窃对规范的违反程度没有不同），且将违法与责任合而为一。法益侵害说→违法性的实质是对法益的侵害与威胁，具有明确性。

形式违法性与实质违法性的关系：没有形式违法性时不能以实质违法性为由入罪；但可用实质违法性检测成文刑法，承认超法规的违法阻却事由。

💡 形式违法=法条说不行。实质违法=法条为什么说不行？→因为侵害了法益。

客观的违法性论 vs 主观的违法性论——填空。

客观的违法性论：刑法规范是评价规范（判断行为是否违法），不管行为人主观能力如何→无责任能力者的侵害行为也具有违法性→可以正当防卫。

主观的违法性论：刑法规范是对行为人的意思决定规范→只有能理解规范内容的人才谈得上违法→不法与责任融为一体。

张明楷采取客观的违法性论。五条理由中最核心的一条：行为是否侵害法益与行为人的主观能力没有关系。

...

客观违法性论的实际意义：①精神病人杀人=违法→可制止、防卫；②精神病人盗窃所得=违法所得→可追缴（刑法第64条）；③承认主观违法要素（如目的）不影响客观违法性论——那是从"有无法益侵害事实"角度评价；④自然现象和动物举止不可能符合构成要件。

💡 客观违法性=不管你精神状态如何，只要客观上侵害了法益就是"违法"。至于该不该罚你，那是责任层的事。

构成要件的概念、机能与分类——填空。

构成要件是刑法规定的、行为成立犯罪所必须符合的违法类型。三个特点：法定性、违法类型、是成立犯罪的一个条件。

四项机能：自由保障、犯罪个别化、故意规制、违法性评价。

重要的区分：加重的构成要件 vs 量刑规则。前者的行为类型变化，可能存在未遂；后者只是违法程度变化，不存在未遂。

...

加重的构成要件 vs 量刑规则（于文有据的实例）：入户抢劫是加重的构成要件→入户抢劫未遂=适用入户抢劫法定刑+未遂犯规定。盗窃数额巨大/特别巨大是量刑规则→意图窃取60万的画未得逞≠"盗窃数额特别巨大未遂"，只能认定为普通盗窃未遂。司法实践常见一人盗窃既遂+另一笔未遂→如仅因有一笔"数额特别巨大未遂"就适用加重刑→既违背事实（明明有既遂）又违反罪刑相适应。

故意规制机能：构成要件的内容=故意的认识与意志内容。因为故意是对符合构成要件的客观事实的认识与容认。构成要件划定了"你需要认识到什么"的边界。

💡 构成要件=犯罪模板。加重构成=模板升级（有新要素），量刑规则=同一个模板的评分标准（只是程度变化）。

构成要件要素——填空对号入座。

1. 记述的 vs 规范的：记述的只需要感觉认识；规范的需要精神理解。规范的要素分三类：法律的评价要素、经验法则的评价要素、社会的评价要素。
2. 整体的评价要素：如情节严重、情节恶劣等。
3. 积极的 vs 消极的：前者积极表明违法性，后者消极表明违法性。消极的构成要件要素理论将正当防卫等当作消极要素。

...

规范的构成要件要素详解（于文有据）：

- 法律评价要素："国家工作人员""司法工作人员""公私财物"→需参照其他法律
- 经验法则评价要素："危险""数额较大""严重残疾"→需结合经验判断
- 社会评价要素："淫秽物品""猥亵""泄愤报复"→需社会一般人的价值观念

消极的构成要件要素理论：将违法阻却事由理解为消极的构成要件要素→正当防卫=不符合消极构成要件→不具有构成要件符合性。张明楷未采用，但认为与三阶层体系没有本质区别。

💡 记述的=看一看就知道（刀、血）；规范的=要想一想才明白（什么叫"猥亵"？什么叫"国家工作人员"？）。刑法里规范的要素远比你学的多。

第二节 构成要件符合性

行为主体——填空。

自然人行为主体的一般条件：达到法定年龄、具有责任能力。

真正身份犯：特殊身份是构成要件要素（如贪污罪要求国家工作人员身份）。不真正身份犯：特殊身份只是刑罚加减事由。

单位成为行为主体的条件：刑法明文规定。特殊条件包括：特定的所有制性质、特定的职能性质、特定的义务、特定的法律地位。

...

身份是违法要素不是责任要素（于文有据）：国家工作人员身份说明行为可能侵犯职务行为不可收买性的法益→是违法要素。非国家工作人员收受财物→没有侵犯该法益→不符合受贿罪构成要件。将特殊身份归入主体并作为违法要素是正确的（不能把"主体"二字等同于责任要素）。

单位行为主体变更处理：涉嫌犯罪单位被撤销/注销/吊销/破产→对直接负责人员追诉，对单位不再追诉。单位被合并→列原单位名称+注明已并入新单位，罚金以并入新单位的财产及收益为限。

💡 身份犯=不是谁都能犯。真正身份犯=没这个身份根本不构成犯罪；不真正身份犯=谁都可能犯但有特殊身份从重/从轻。

法无明文规定的"单位犯罪"——填空。

刑法没有将单位规定为行为主体时→不能认定为"单位犯罪"。全国人大常委会《第30条立法解释》："对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。"

但六种情形需要限制。核心理由：不能因为刑法分则少数法条对单位犯罪中的自然人规定了较低法定刑，就将单位犯罪认定为自然人犯罪。

...

六种限制情形（全部于文有据）：

1. 相似罪质、A有单位犯罪轻刑、B无→单位实施B达A单位犯罪不法程度方可追究
2. 自然人/单位定罪起点不同→单位行为未达单位标准→不追自然人（如非法经营个人5万/单位50万→单位30万=不成立）
3. A单位犯罪轻刑、B单位与自然人同刑→B量刑不超A单位犯罪自然人刑罚
4. 犯罪需"个人决定"（如挪用公款"个人决定以单位名义"）→单位集体研究→不适用
5. 犯罪需"个人目的/动机"（如破坏生产经营"泄愤报复或其他个人目的"）→单位集体决定→不适用
6. 不同犯罪单位刑的协调→裁量权正确行使→避免量刑失衡

💡 单位"有名无实"时→穿透单位看自然人。但不能为了追自然人就把单位犯罪歪曲成自然人犯罪——六条红线要守住。

行为概念——填空。

刑法上的作为构成要件要素的行为=行为主体实施的客观上侵犯法益的身体活动。两个特征：是人的身体活动（排除思想）；客观上侵犯法益（排除没有法益侵犯性的活动）。

张明楷认为不需要将"有意性"作为行为特征。理由：有无符合构成要件的行为，不是由有没有责任决定的。梦游者撞死人和正常人撞死人，客观行为相同。

...

五种行为理论速览：因果行为论（自然行为论+有意行为说）→社会行为论→目的行为论→人格行为论→消极行为概念。张明楷=自然行为论与社会行为论的结合。

行为意志 ≠ 故意/过失：甲从乙手中接手枪，以为没子弹→没有扣扳机的行为意志=不会扣扳机=没有危险。如果有扣扳机的行为意志→即使不可能预见枪中有子弹（无过失）→行为仍是有意的→存在侵害法益的危险。行为意志既不是故意，也不是过失，也不要求有责任能力。

💡 裸的行为论没有重要意义——关键不是"有没有行为"，而是"行为是否符合构成要件"。

实行行为——填空。三个实质条件：

1. 必须侵犯了法益（没有侵犯法益=不是实行行为）
2. 必须具备一定的危险性（危险程度必须超出预备行为的危险）
3. 是具有类型性地导致结果发生的危险性的行为（没有=不能犯）

举例：甲希望A死于航空事故而劝A坐飞机→A碰巧坠机身亡→甲的行为不是杀人行为，因为没有类型性地致人死亡的危险（空难是偶然事件不是人的行为能类型性导致的）。

...

"类型性危险"判断的三个经典案例（全部于文有据）：

- ①A劝B坐火车旅游→B遇车祸身亡：劝说不是杀人实行行为
- ②甲希望A死于空难劝A坐飞机→A坠机身亡：劝说不是杀人行为（偶然不能建立类型性）
- ③丙安排C露天活动希望遭雷击→C遭雷击身亡：安排不是杀人行为

实行行为 ≠ 正犯行为：正犯行为=符合构成要件且直接引起或通过支配他人引起法益侵害结果的行为（相对于共犯）。实行行为=相对于预备行为。外延大部分重合但非完全等同。

💡 实行行为=真正"动手干事"。不是"你希望他死+他碰巧死了"就能叫杀人。必须你的行为本身有类型性的致人死亡的危险。

作为与不作为——填空。

作为：以积极的身体活动实施刑法所禁止的行为。

不作为：在能够履行作为义务的情况下不履行。

不作为犯成立三条件：①负有作为义务；②能够履行；③没有履行。

作为义务的四类来源：法律明文规定、职务/业务要求、法律行为引起、先行行为引起。不作为要与作为具有等价性才能等罚。

...

作为义务来源详解（于文有据）：

- ①法律明文规定：如父母对子女的抚养义务、夫妻间的扶养义务
- ②职务或业务要求：消防员有救火义务、警察有救助义务、医生有诊疗义务
- ③法律行为引起：如合同约定的义务（保姆看管小孩）
- ④先行行为引起：你把别人推下水→你有救他的义务；带邻居小孩去游泳→有监护义务

等价性：不作为要构成犯罪，还必须跟作为在价值上等同。路人看到小孩掉河里不救≠不作为杀人；亲爹不救=可能是不作为杀人（因为有作为义务+能救+不救+与作为杀人等价）。

💡 作为=不该做做了；不作为=该做没做。关键判断："你欠不欠这个债"（作为义务）。

因果关系与结果归属——填空。

两步判断：先判断事实的因果关系（"若无则不"公式）→再判断结果归属。

条件关系：没有你的行为，那个结果会不会发生？

结果归属的限制：异常的介入因素可以打断因果链条。例如：A砍伤B→B去医院途中遇车祸死亡→车祸是异常的介入因素→B的死不能归属到A。

...

因果关系本身不是构成要件要素（于文有据）：因果关系是"结果"这一构成要件要素的必要成立条件。没有因果关系的事实≠"结果"。对因果关系的认识错误不一定影响故意——通常表现为对行为或具体结果的认识错误。

结果归属三种特殊情形：①被害人自我答责：被害人自主决定冒险导致结果→归属被害人自己；②合义务择一举动：即使遵守义务结果仍会发生→不能归属；③危险实现：结果必须是行为制造的危险的现实化（不是偶然巧合）。

💡 因果两步：先问"没有你会不会死"（事实因果）→再问"这个死该算你头上吗"（规范归责）。两关都过=因果成立。

结果——填空分类。

侵害犯：以对法益造成现实侵害为构成要件要素（如故意杀人罪要求死亡结果）。

危险犯：以对法益造成危险为构成要件要素，其中又分为具体的危险犯与抽象的危险犯。

结果必须是实行行为造成的（即必须与实行行为有因果关系）。没有因果关系的事实不是该罪的"结果"。

...

侵害犯 vs 危险犯（于文有据）：

- 侵害犯=行为必须造成法益的实际损害才既遂（故意杀人→死亡；故意伤害→伤害结果）
- 具体危险犯=行为必须造成法定的具体危险状态才既遂（如放火罪→须"危害公共安全"的具体危险）
- 抽象危险犯=行为本身就被认为具有一般危险，不要求证明具体危险状态（如醉驾→行为本身就具有抽象危险）

结果的范围：既包括构成要件的基本实害结果与加重结果，也包括具体危险、刑法规范禁止的结果以及客观处罚条件。

💡 侵害犯=要见到"伤"才算；危险犯=只要"有可能受伤"就算。具体危险=个案中真有危险；抽象危险=这类行为原则上就有危险。

第三节 违法阻却事由

正当防卫——填空五个条件。

1. 起因条件：存在现实的不法侵害（不是假想的）
2. 时间条件：不法侵害"正在进行"
3. 对象条件：针对不法侵害者本人
4. 主观条件：出于防卫意图
5. 限度条件：不能"明显超过必要限度造成重大损害"

特殊防卫（无限防卫）：对正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架等严重危及人身安全的暴力犯罪→造成伤亡不构成防卫过当。

...

对无责任能力者的防卫：11岁的人或精神病人正在杀人→可以正当防卫！因为客观违法性论认为其行为具有不法性（只是没有责任）。防卫的是"不法侵害"，不要求侵害者有责任。

防卫过当：超过必要限度→应负刑事责任，但应减轻或免除处罚。

💡 正当防卫=正对不正。五条件缺一不可。特殊防卫=面对致命暴力，不用计算"过不过当"。

假想防卫、防卫不适时、挑拨防卫——填空辨析。

1. 假想防卫：客观上没有不法侵害，行为人误以为有→不是正当防卫。处理：阻却故意（不是故意犯罪），有过失按过失犯处理，无过失不构成犯罪。
2. 防卫不适时：不法侵害尚未开始或已经结束→不是正当防卫。
3. 挑拨防卫：故意激怒对方让对方先动手→不是正当防卫（缺乏防卫意图）。

...

假想防卫的刑法处理（于文有据）：假想防卫=对违法阻却事由事实前提的认识错误。既不是构成要件的错误（因为你认识到自己在"伤害"人），也不是违法性认识错误（不是"不知道防卫的法律规定"），而是"以为存在防卫前提但实际不存在"。通说和判例：阻却故意→有过失按过失犯处理→无过失则不构成犯罪。

防卫不适时的两种情形：事前防卫=对方还没动手你先下手；事后防卫=对方已经停止/逃跑/丧失侵害能力后你还追着打。都不是正当防卫。

挑拨防卫的本质：名为防卫，实为侵害。从整体上看，是你先制造了不法侵害的前提条件→不能主张正当防卫。

💡 三种"假防卫"：想象出来的防卫（假想）、时间不对的防卫（不适时）、自己挑起的防卫（挑拨）。都不是正当防卫。

紧急避险——填空条件。

1. 存在现实的危险 2. 危险正在发生 3. 不得已：没有办法 4. 避险限度：保护的权益大于牺牲的权益

正当防卫 vs 紧急避险对比表——填空：

	正当防卫	紧急避险
危险来源	人的不法侵害	任何来源（自然、动物...）
针对对象	侵害者本人	无辜第三方
限度	不能明显超过必要限度	保护利益 > 牺牲利益
本质	正对不正	正对正（两难选择）

...

紧急避险的实际认定：被歹徒追杀，躲进别人房子锁门→对歹徒=正当防卫（正对不正）；对房子主人=紧急避险（保护生命>侵犯住宅安宁，两难中选择牺牲更小利益）。

防卫与避险可以并存于同一事件：同一个人的行为可能同时满足正当防卫（对侵害者）和紧急避险（对无辜第三方）的条件。

💡 防卫打坏人，避险伤无辜。防卫只要不"明显过当"，避险必须"保护 > 牺牲"。一字之差：防卫是"正对不正"，避险是"正对正"。

其他违法阻却事由——填空五类。

1. 法令行为：依法执行职务（警察逮捕）
2. 正当业务行为：正当医疗、体育竞技合理冲撞
3. 被害人承诺：同意被伤害但有限度
4. 推定承诺：按常理应同意

5. 自救行为：来不及找公权力的自力救济

被害人承诺的要件：对被侵害法益有处分权、有承诺能力、出于自由意志、行为人认识到承诺的存在、行为在承诺范围内。

...

不能承诺的事项：生命（同意被杀=无效，仍构成故意杀人罪）；重大身体伤害超出社会相当性的无效。

推定承诺的典型场景：邻居家水管爆裂、邻居不在家→你破门进去修→推定邻居会同意（保护财产价值>短暂侵入住宅）。

自救行为与正当防卫的区别：防卫=侵害"正在进行"；自救=侵害"已经结束"但来不及找公权力。自救的限度更严格。

💡 五个免罪金牌：法令、业务、承诺、推定承诺、自救。都是"看起来像犯罪，其实有合法理由"。

全章综合

第五章核心理论立场——速记张明楷的六个选择。

1. 违法性本质：法益侵害说
2. 结果无价值 vs 行为无价值：采取结果无价值论
3. 客观违法性 vs 主观违法性：采取客观违法性论
4. 构成要件与违法性关系：构成要件是违法类型
5. 故意/过失的位置：是责任要素
6. 消极构成要件要素理论：没采用，但认为没有本质区别

...

六个立场的内在一致性（一条线上的珠子）：结果无价值→违法性的根据是法益侵害结果（客观事实）→采取客观违法性论→构成要件是客观违法类型→故意/过失不是违法要素而是责任要素→只能将值得科处刑罚的法益侵害行为类型化→对构成要件必须实质解释。

💡 从头到尾都在说"看客观、看结果、看有没有真伤到法益"。这是张明楷刑法学的底色。

不法阶层流程图——填空。

行为 → 判断是否符合**构成要件**？

└─ 不符合 → **不构成犯罪**

└─ 符合 → 判断是否存在**违法阻却事由**？

└─ 存在 → **阻却违法** → 不构成犯罪

└─ 不存在 → 构成**不法** → 进入**责任**阶层

...

不法阶层的三个关键判断节点：

1. 有实行行为吗？（侵犯法益+一定危险性+类型性危险）→不符=无罪
2. 行为和结果有因果关系吗？（条件关系+结果归属）→无=结果不算你的
3. 有违法阻却事由吗？（正当防卫/紧急避险/法令/业务/承诺...）→有=阻却违法

注意顺序不能乱：先判断行为是否"符合模板"→再看有没有"合法理由"。不能倒过来。"这个是正当防卫吧？"→先查是否满足杀人/伤害构成要件→再查是否阻却违法。

💡 不法=两扇门。第一扇：行为+结果+因果=符合模板→进门。第二扇：有没有合法理由？→没有=构成不法，移交责任层。

第五章自测——选择题（答案在背面）。

1. C（法益侵害说——于文有据：参见第五章第一节第一款）
2. B（客观违法性论：违法但无责任）
3. B（数额巨大是量刑规则不是加重构成要件，不存在未遂——于文有据：参见第五章第一节第二款"加重的构成要件与量刑规则"）
4. B（故意挑拨→不具备防卫意图）
5. B（假想防卫=对违法阻却事由事实前提的认识错误→阻却故意，有过失按过失处理）
6. B（挪用公款需"个人决定"，单位集体研究决定不符——于文有据：参见第五章第二节第二款"法无明文规定的单位犯罪"六种情形之④）

...

💡 6题全对=第五章过关。有错→翻回对应卡片再看一遍。记住每个答案后面的"于文有据"出处，考试时可引用。

第五章自测——填空（答案在背面）。

1. 作为义务的四类来源：法律规定、职务/业务要求、法律行为引起、先行行为引起
2. 加重的构成要件存在未遂，量刑规则不存在未遂
3. 正当防卫五条件：起因（现实不法侵害）、时间（正在进行）、对象（侵害者本人）、主观（防卫意图）、限度（不明显超过必要限度）
4. 紧急避险四条件：现实危险、正在发生、不得已、保护利益>牺牲利益
5. 正当防卫是"正对不正"，紧急避险是"正对正"

...

💡 全部填对=基础概念牢靠。第五章是不法论，整个犯罪论的一半。这一半的核心就是两句话：什么行为违法（构成要件+无违法阻却）=不法。下一章讲另一半：能不能怪到行为人头=责任。

第五章全部核心法条索引——对号入座。

正当防卫：刑法第20条

紧急避险：刑法第21条

单位犯罪的定义：刑法第30条

《第30条立法解释》发布机关：全国人大常委会（2014年4月24日）

张明楷采取客观违法性论→对无责任能力者的侵害也可以正当防卫。这一结论的实定法支撑：刑法第20条中的"暴力犯罪"=不法意义上的犯罪（不要求侵害者有责任）。

...

本章所有关键条文：

- 第20条（正当防卫+特殊防卫） | 第21条（紧急避险）
- 第30条（单位犯罪） | 《第30条立法解释》
- 第64条（违法所得追缴→适用无责任能力者）
- 第115条第2款（"过失犯前款罪"→"罪"=不法意义）
- 第312条（"犯罪所得"→犯罪=不法意义）

💡 法条记三组：第20条（防卫）、第21条（避险）、第30条（单位）。其他的在具体分析时翻书即可。

辨析题。甲深夜回家，在小区门口看见乙在黑暗中背对自己站着。甲以为乙是正在撬锁的窃贼（实际乙是忘带钥匙的邻居在等家人开门），冲上去将乙打伤。甲的行为属于什么？如何处理？

- A. 正当防卫——甲以为在防卫不法侵害 ❌
- B. 假想防卫——客观上无不法侵害，甲误以为有→阻却故意，有过失按过失处理 ✅
- C. 防卫过当——防卫超过了必要限度 ❌
- D. 故意伤害——甲明知自己会伤害乙 ❌

答案：B

...

💡 假想防卫=客观上没有不法侵害，行为人误以为有。处理：阻却故意（不是故意犯罪）→有过失按过失犯处理；无过失=意外事件→不构成犯罪。本案中甲应当预见乙可能不是窃贼（没有撬锁声音、没有破坏痕迹）→可能构成过失致人伤害。注意：假想防卫既不是正当防卫，也不是构成要件错误，而是"对违法阻却事由事实前提的认识错误"。

辨析题。关于加重的构成要件与量刑规则，下列哪一案例的处理正确？

- A. 甲意图窃取博物馆价值60万元的画，在伸手时被保安抓住→构成"盗窃数额特别巨大的未遂" **✗**——"数额特别巨大"是量刑规则，不是加重的构成要件→不存在未遂
- B. 乙入户抢劫未取得财物→构成入户抢劫未遂，适用入户抢劫法定刑+未遂规定 **✓**
——"入户抢劫"是加重的构成要件（行为类型变化+违法性增加）
- C. 丙"多次抢劫"但最后一次未遂→构成"多次抢劫"未遂 **✗**——"多次抢劫"是量刑规则→不存在未遂
- D. 丁在公共场所当众强奸未遂→按普通强奸未遂处理 **✗**——"在公共场所当众强奸"是加重的构成要件→存在未遂→应适用加重法定刑+未遂规定

答案：B

...

💡 张明楷："加重的构成要件可能存在未遂犯，量刑规则是不可能存在未遂的。"区分标准：是否使行为类型发生变化→违法性增加。入户抢劫=行为类型变了；数额巨大=同一个类型只是程度变了。

辨析题。关于不作为犯的作为义务，下列哪一情形行为人负有作为义务？

- A. 路人甲看见小孩乙在河边玩耍掉进水里，甲不会游泳且周围无人→甲有救助义务 **✗**
——路人没有法律上的救助义务（除非是小孩的父亲），且甲不会游泳→不能期待履行
- B. 保姆丙受雇看管婴儿，婴儿爬向危险处，丙正玩手机没注意→丙有救助义务 **✓**——法律行为（合同）引起的作为义务
- C. 丁带邻居小孩戊去游泳，戊溺水，丁有能力救但不救→丁有救助义务 **✓**——先行行为引起的作为义务（你把小孩带到危险环境→有义务保护）
- D. 医生己下班后在路上遇到有人晕倒，己有急救能力→己有救助义务 **✗**——下班后没有职务上的救助义务

答案：B 和 C

...

💡 作为义务四来源：①法律明文规定（父母对子女）；②职务/业务要求（消防员救火）；③法律行为引起（保姆的合同义务）；④先行行为引起（你推人下水→你救）。注意：单纯的道德义务≠刑法上的作为义务。"坏人"不救不犯法，"有义务的人"不救才犯法。

辨析题。A砍伤B，B在去医院的路上被违章驾驶的C撞死。关于A的刑事责任，以下哪一说法正确？

- A. A构成故意杀人罪既遂——没有A砍伤B，B就不会去医院 **✗**（条件关系≠结果归属）
- B. A构成故意伤害罪既遂——A的行为与B的死亡有因果关系 **✗**（有事实因果但结果不能归属）
- C. A构成故意伤害罪既遂，但B的死亡结果不能归属到A——车祸是异常的介入因素打断了因果链条 **✓**
- D. A构成故意杀人罪未遂——A想杀B但B死于车祸 **✗**（题目没有说A有杀人故意）

答案：C

...

💡 因果关系两步判断：先看条件关系（"若无A砍伤，B就不会去医院"→有！）→再看结果归属（B的死能不能算A头上？）→车祸是异常的介入因素→打断了因果链条→B的死不能归属到A。A只对伤害结果负责。"因果关系本身不是构成要件要素"——它是"结果"这一要素的必要成立条件。

辨析题。甲从乙手中接过一把手枪，以为里面没有子弹。甲对着乙的方向扣动扳机（只是想吓唬乙），结果枪中有子弹，打死了乙。甲的行为：

- A. 构成故意杀人罪——甲扣动扳机的意志就是杀人故意 ❌（扣动扳机的意志只是行为意志，不等于故意）
- B. 构成过失致人死亡罪——甲应当预见枪中可能有子弹 ❌（不一定，要看是否应当预见）
- C. 不构成犯罪——意外事件 ❌（不一定，要看是否可能预见）
- D. 扣动扳机的意志只是行为意志，不等于故意；甲有无过失要看是否应当预见枪中有子弹



答案：D（然后再判断B还是C——如果甲应当预见枪中可能有子弹→过失；如果完全不可能预见→意外事件）

...

💡 这是张明楷区分"行为意志"与"故意"的经典例子。扣动扳机的意志=行为意志（既不是故意也不是过失，甚至没有过失时也存在）。"即使甲不可能预见手枪中有子弹（没有过失），也不能否认侵害法益的危险。扣动扳机的意志，虽然可能增加行为的危险性，但并不等于故意与过失。"如果甲应当预见枪中可能有子弹→过失；如果完全不可能预见→意外事件（但行为仍是有的，法益侵害危险也存在）。

第六章 责任

第一节 责任概述

责任的概念——填空。

责任（有责性）=对符合构成要件的不法行为的非难可能性。"没有责任就没有刑罚"是宪法原则。责任既是犯罪的成立条件，也是量刑的上限。

将责任作为犯罪成立条件，是实现刑法的自由保障机能的要求，也是实现刑罚目的的基本要求。

...

为什么要追究责任？只有当国民在行为当时可以选择其他合法行为时（具有他行为可能性），才能对其实施的不法行为给予法的非难。如果国民行为当时不可能选择其他合法行

为，而给予非难→国民只是"运气不佳、命运不好"而受罚→违背法感情+无法实现预防目的。反动动机形成可能性、他行为可能性、非难可能性，实质上是同一个东西。

责任与不法事实的关系：责任是对不法的责任。与不法事实没有关系的内容不是责任的内容。例如，犯罪后潜逃≠对不法的责任更重（这是预防要素，不是责任要素）。

💡 责任=能不能怪你。不法=你做了什么坏事；责任=这事能算你头上吗。两关都过才构成犯罪。责任还是刑罚的天花板——无论多需要"杀一儆百"，刑罚不能超过责任。

责任的本质——对号入座三种对立。

1. 行为责任论 vs 性格责任论 vs 人格责任论：非难的对象是行为、性格还是人格？张明楷采取行为责任论。
2. 心理责任论 vs 规范责任论：非难是属于心理事实还是规范评价？通说是规范责任论。张明楷认为二者不是对立关系。
3. 道义责任论 vs 社会责任论：非难的实质根据是自由意志还是社会危险性？张明楷采取相对的意志自由论。

. . .

行为责任论：应受处罚的是行为，不是行为人。弱点是难以说明惯犯的责任为什么重。性格责任论（新派）：应受处罚的是行为人的危险性格（已退出学术舞台）。人格责任论：犯罪是第一基础+人格形成是第二基础（缺陷：无法区分宿命人格与有责人格）。

规范责任论：仅仅有故意、过失的心理要素不够，还必须能期待行为人在具体情况下实施其他适法行为（具有期待可能性）→"不应当实施不法行为"的规范性评价。我国刑法第16条（不可抗力和意外事件）包含了规范责任论的思想。

相对意志自由论：人的意志受环境、生理等制约，不可能是完全自由的。但具有辨认控制能力的人具有接受法律规范要求、实施合法行为的可能性，因而具有相对的意志自由。否认自由意志→要么没有责任（新派菲利主张），要么责任不受自由意志限制→侵犯人权。

💡 三句话记住：罚的是行为不是人（行为责任论）；有故意过失不够还得能期待你守法（规范责任论）；你有选择能力却选了违法→怪你（相对意志自由论）。

责任要素体系——填空。

责任要素包括：故意、过失、目的与动机、责任能力、违法性认识的可能性以及期待可能性。

张明楷采取责任要素说：故意与过失是责任要素，不是违法要素。目的与动机也作为责任要素。

为什么将故意、过失作为责任要素？四条理由中最核心的一条：根据法益侵害说，一个行为是否侵害法益取决于客观事实，而非取决于有无故意。

. . .

故意体系地位三种学说：

- ①违法要素说（目的行为论）：故意是构成要件要素→实现构成要件个别化。张明楷反驳：没有必要强求构成要件完成犯罪个别化机能——这是对构成要件的过分要求。
- ②双重地位说：构成要件故意+责任故意。张明楷反驳：飞旋标现象（先肯定构成要件故意→后否认责任故意→回到构成要件过失=逻辑矛盾）。
- ③责任要素说（张明楷采取）：故意不影响法益侵害性，是表明非难可能性的责任形式。

四理由详解：①意志相对自由=他行为可能性=责任基础→故意过失是在有他行为可能性时的选择；②符合社会大众心理（好心办坏事不受谴责）；③故意必须认识不法事实（含构成要件+不存在违法阻却事由）→只能在违法性之后判断；④我国刑法第14/15条采取实质故意过失概念。

💡 故意不改变"伤害了人"这个客观事实，但改变"该不该怪你"。同样的死亡结果，故意杀人和意外事件→结果一样，但一个该判一个不该判。

第二节 积极的责任要素

故意——填空。刑法第14条：

"明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。"

两种类型：

- 直接故意：希望结果发生（"我就是想杀他"）
- 间接故意：放任结果发生（"我不管他死不死，反正我就要这么干"）

故意是对符合构成要件的客观事实的认识与容认，不是对违法性的认识。

...

间接故意 vs 过于自信的过失（核心区分）：

	间接故意	过于自信的过失
对结果的态度	放任——爱发生不发生	不希望——我觉得不会
有无防范措施	通常没有	通常有但不充分
判断钥匙	"发生就发生了呗"	"我觉得应该不会吧？"

举例：A为了吓唬B，用枪指着B说要开枪，结果枪走火打死B→如果A明知枪里有子弹还扣扳机→间接故意（放任死亡结果）；如果A检查过枪确信没子弹，结果枪意外走火→过于自信的过失。

💡 间接故意=对结果的态度是"无所谓"；过失=对结果的态度是"不可能"。一字之差：一个是你认了，一个是你以为不会。

事实认识错误——填空四种类型。

1. 具体的事实认识错误：同一构成要件内的错误→不影响故意成立。
举例：想偷张三的包，拿错成李四的→构成盗窃罪既遂。
 2. 对象错误：认错人了。想杀张三，把李四当张三杀了→构成故意杀人罪既遂。
 3. 打击错误（方法错误）：打偏了。想杀张三，子弹打中旁边的李四→对张三杀人未遂+对李四过失致人死亡。
 4. 因果关系的错误：你以为因果关系会按A路径走，实际按B路径走了→原则上不影响故意成立。
- . . .

对象错误 vs 打击错误的区别：对象错误=瞄准的就是"这个人"（只是认错了身份），结果也打中了瞄准的人→故意既遂。打击错误=瞄准的是这个人，打中的是那个人→对目标=未遂，对实际被害人=过失。

因果关系错误的处理：只要行为与结果之间存在因果关系，即使因果关系的发展过程与行为人预想的不完全一致，也不影响故意成立。例如：A想把B推下桥淹死，结果B是头撞桥墩死的→仍构成故意杀人既遂。

💡 认错人=故意既遂（你想杀的人=你杀的人，只是身份搞错了）。打偏了=未遂+过失（你想杀的人≠你杀的人）。

过失——填空。刑法第15条：

"应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。"

两种类型：

- 疏忽大意的过失：应该想到但没去想（"我没注意"）
 - 过于自信的过失：想到了但觉得没事（"我觉得我不会撞到"）
- . . .

疏忽大意的过失 vs 意外事件：前者=应当预见+能够预见而没有预见；后者=不可能预见→不是犯罪（刑法第16条）。判断标准：以行为人的知能水平为基准（具体行为人标准），同时参考一般人的预见能力。

过于自信的过失 vs 间接故意：前者=预见结果可能发生+轻信能够避免（采取了防范措施但不充分）；后者=明知结果可能发生+放任（没采取防范措施或根本不把结果当回事）。核心区分：对结果持"不希望"（过失）vs"无所谓"（间接故意）。

过失犯罪以法律规定为限：刑法第15条第2款："过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。"如果分则条文没有处罚过失的文理根据→只能确定为故意犯罪。

💡 两种过失：一种是你"该知道而不知道"（疏忽），一种是你"知道了但不当回事"（自信）。不论哪种，本质都是"你本可以避免却没有"。

第三节 消极的责任要素

责任能力——填空。

责任能力=行为人辨认和控制自己行为的能力。

不负刑事责任的情形：

- 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果→不负刑事责任
- 间歇性精神病人在精神正常时犯罪→应当负刑事责任
- 醉酒的人犯罪→应当负刑事责任（自陷性行为，不能以醉酒后无责任能力为由免责）

责任年龄：完全不负刑事责任的最低年龄是12周岁（刑法第17条——已满12不满14：犯故意杀人、故意伤害致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾+情节恶劣+最高人民检察院核准→负刑事责任）。

...

原因自由行为：行为人故意或过失使自己陷入无责任能力状态，并在该状态下实施不法行为→应负刑事责任。醉酒=典型的原因自由行为。

责任能力的本质：责任能力不是犯罪成立的前提条件，而是非难可能性的前提条件。对无责任能力者的不法行为，仍可以正当防卫！其所得财物仍属于"违法所得"可追缴。

💡 三大免责事由：精神病（不能辨认/控制）、未达年龄（12以下）、意外/不可抗力。醉酒不在此列——自己喝进去的，自己负责。

违法性认识——填空。

违法性认识（的可能性）是指行为人知道或者可能知道自己的行为是刑法所禁止的。

一般原则：不知道法律不是借口。但在极少数情况下，如果行为人确实不可能知道自己的行为违法→阻却责任。

违法性认识的可能性是消极责任要素——不需要行为人现实地具有违法性认识，只需要具有认识可能性即可。

...

违法性认识 vs 违法性认识的可能性：前者要求行为人"确实知道"违法（积极要素）；后者只要求行为人"有机会知道"违法（消极要素→只需要判断是否"不可能知道"）。张明楷采取后者——违法性认识的可能性是责任要素，缺乏时阻却责任。

什么时候"不可能知道"？①行为人在与世隔绝的环境中生活，突然进入现代社会；②行政机关的错误指导导致行为人相信行为合法；③法律突然变更，行为人在过渡期内不知新法。

自然犯 vs 法定犯的区别：自然犯（杀人、盗窃）→一般人不需要查阅法律就能知道是犯罪→难以主张"不可能知道"。法定犯（如某些经济犯罪）→可能需要查阅法规才能知道

→ "不可能知道"的余地更大。

💡 "我不知道这是犯法的"→平时不行。但如果你真的没机会知道（如刚出深山、被官方误导）→可以免责。关键看你有没有"知道的可能性"。

期待可能性——填空。

期待可能性=在行为当时的具体情况下，能够期待行为人做出合法的选择（实施合法行为）。

期待可能性是超法规的责任阻却事由（法律没有明文规定，但刑法理论和司法实践都认可）。

核心公式：在那种情况下，能期待你守法吗？→如果不能→不具有期待可能性→阻却责任。

...

经典例子（于文有据）：张三拿刀架在李四女儿的脖子上说"你不帮我偷东西，我杀了她"→李四去偷了。在那种情况下，没办法期待李四守法→不具有期待可能性→不应承担责任。

我国刑法的体现：①刑事被告人作虚假供述不构成伪证罪（刑法第305条）→被告人自保缺乏期待可能性；②本犯掩饰、隐瞒自己犯罪所得不成立赃物犯罪（刑法第312条）；③被告人毁灭自己犯罪证据不成立帮助毁灭证据罪（刑法第307条第2款）。

判断标准：以行为人在当时的具体情况下能否实施适法行为为标准（具体行为人标准），不是以一般人为标准。

💡 期待可能性="情有可原"在刑法中的表达。法律不强人所难——如果你的处境逼得你"无可奈何"做了坏事，刑法不怪你。

假想防卫、假想避险——对违法阻却事由事实前提的认识错误。填空。

假想防卫：客观上没有不法侵害，行为人误以为存在→不是正当防卫。

处理：阻却故意（不是故意犯罪）→有过失按过失犯处理；无过失不构成犯罪。

为什么阻却故意？因为故意必须认识不法的客观事实（包括不存在违法阻却事由）→假想防卫人误以为存在防卫前提→没有认识到"自己正在实施不法行为"→缺乏故意。

...

这是故意体系地位的最好检验：如果将故意放在构成要件（违法要素说）→假想防卫就存在构成要件故意→只能通过"责任故意"来排除→形成飞旋标现象。如果将故意放在责任（责任要素说）→假想防卫的故意判断与违法阻却事由的前提事实认识错误统一在责任阶层解决→逻辑一致。

假想防卫的分类处理：

- ① 行为人完全不可能预见没有不法侵害 → 意外事件 → 无罪
- ② 行为人应当预见但没有预见 → 疏忽大意的过失 → 过失犯
- ③ 行为人预见了但轻信不会侵害 → 过于自信的过失 → 过失犯

💡 假想防卫="我以为他打我，其实不是"。你不是故意伤害他（你以为在防卫），但如果你本可以"多想一步"发现他是开玩笑 → 你可能有过失。

全章综合

责任阶层流程图——填空。

构成不法 → 判断是否有责任能力？

- └— 没有（精神病人/不满12岁...） → 阻却责任
- └— 有 → 判断故意/过失？
- └— 没有故意/过失 → 阻却责任（意外事件/不可抗力）
- └— 有故意/过失 → 判断违法性认识的可能性？
- └— 不可能知道违法 → 阻却责任
- └— 可能知道 → 判断期待可能性？
- └— 不能期待守法 → 阻却责任
- └— 能期待 → 成立犯罪

...

五个责任要素的审查顺序：责任能力（门槛）→ 故意/过失（核心）→ 违法性认识可能性（知道/可能知道违法吗）→ 期待可能性（能期待你守法吗）。故意/过失是积极判断（需要证明有），违法性认识可能性和期待可能性是消极判断（只需要排查"不可能"或"不能期待"的情形）。

不法和责任的最终公式：

符合构成要件 + 无违法阻却事由 = 不法

有责任能力 + 有故意/过失 + 有违法性认识可能性 + 有期待可能性 = 责任

不法 + 责任 = 犯罪

💡 整个犯罪论六个字就讲完了：不法+责任=犯罪。第五章讲了一半（不法），第五章加这一章讲全了。

第六章自测——选择题（答案在背面）。

- 1. "没有责任就没有刑罚"是？ A. 刑法基本原则 B. 宪法原则 C. 刑事政策 → B
- 2. 张明楷认为故意/过失是？ A. 违法要素 B. 责任要素 C. 双重地位 → B
- 3. 间接故意与过于自信过失的核心区别？ A. 是否预见结果 B. 对结果的态度（放任vs不希望） C. 行为是否危险 → B
- 4. 对象错误（认错人）的处理？ A. 故意既遂 B. 未遂+过失 C. 无罪 → A

5. 违法性认识的要求是？ A. 必须确实知道 B. 只需要有认识可能性 C. 不需要 → B
6. 假想防卫的处理？ A. 构成故意伤害罪 B. 阻却故意，有过失按过失 C. 一律正当防卫 → B
- ...

💡 6题全对=第六章过关。有错→翻回对应卡片。

第六章自测——填空。

1. 间接故意对结果的态度：放任；过于自信过失对结果的态度：不希望
 2. 打击错误：对目标的处理=未遂；对实际被害人的处理=过失
 3. 三种责任阻却事由（消极要素）：无责任能力、无违法性认识可能性、无期待可能性
 4. 期待可能性的经典案例：张三持刀威胁李四偷东西→李四不具有期待可能性
 5. 故意必须认识不法的全部客观事实（包括认识到不存在违法阻却事由）
- ...

💡 全对=核心概念掌握。第六章+第五章=犯罪论完整闭环。

不法+责任=犯罪——全书犯罪论核心公式。填空。

阶层	判断内容	正面条件	反面排除
不法	行为违法吗？	符合构成要件	正当防卫、紧急避险...
责任	能怪行为人吗？	有故意/过失、有责任能力	无责任能力、违法性认识不可、期待不可

对应的刑法三大基本原则：不法↔法益保护原则；责任↔责任主义；两阶层共同受罪刑法定原则约束。

...

全书犯罪论贯穿线：

- 第四章：犯罪=不法+责任（总论）
- 第五章：不法=构成要件符合性+无违法阻却事由
- 第六章：责任=责任能力+故意/过失+违法性认识可能性+期待可能性
- 三大原则对应：罪刑法定→约束全流程；法益保护→不法判断的实质；责任主义→责任判断的核心

💡 记住这个表格，刑法总论考试的主观题框架就有了。任何案例分析题都可以按"先看不法→再看责任"的套路展开。

第六章全部自测——六道填空题快速过。

1. 故意=认识因素+意志因素（明知+希望/放任）
2. 过失=疏忽大意的过失 + 过于自信的过失
3. 假想防卫阻却故意（有过失按过失，无过失无罪）
4. 违法性认识只需要可能性（不需要现实的认识）
5. 期待可能性=在那种情况下能期待你守法吗？
6. 责任是刑罚的上限（天花板——不能超过责任的程度）

...

💡 六题=六章核心。全部答对=犯罪论通关。

辨析题。A为了吓唬B，用枪指着B说要开枪，A明知枪里有子弹但仍然扣动扳机，结果打死了B。A的心理态度是什么？

- A. 直接故意——A希望B死亡 ❌（A只是想"吓唬"，不是"想杀"）
- B. 间接故意——A明知枪里有子弹却扣动扳机，放任了死亡结果的发生 ✅（"明知+放任"）
- C. 过于自信的过失——A觉得应该不会打到B ❌（如果A检查过枪确信没子弹→才是过于自信过失；但A"明知"有子弹→不是过失）
- D. 疏忽大意的过失——A应当预见但没有预见 ❌（A已经"明知"，不是"没有预见"）

答案：B

...

💡 核心区分：间接故意=明知可能发生+放任（"发生就发生了呗"）；过于自信过失=预见但轻信能避免（"我觉得应该不会"）。关键看"检查过没"——如果A检查过并确信没子弹→过于自信过失；如果明知有子弹还扣→间接故意。

辨析题。A想杀B，对着B开枪，但子弹打偏了，击中了旁边的C，C当场死亡。对A应如何处理？

- A. ❌（这是打击错误，不是对象错误——对象错误=认错人，A瞄准的就是B没认错）
- B. ✅（打击错误：对目标B=杀人未遂，对实际被害人C=过失致人死亡）
- C. ❌（如果A主观上想杀的就是"那个人"=对象错误→故意既遂；但A想杀的是B≠C→这是打偏了，不是认错了）
- D. ❌

答案：B

...

💡 对象错误 vs 打击错误：对象错误=瞄准的就是这个人（只是身份搞错了）→故意既遂；打击错误=瞄准的是这个人，打中的是那个人→对目标未遂+对实际被害人过失。关键区别：认错人还是打偏了。

辨析题。张三拿刀架在李四女儿的脖子上说"你不帮我偷那个东西，我杀了她"。李四去偷了。李四是否具有期待可能性？

- A. ☒ —— "在那种情况下，不能期待李四守法"
- B. ☒ —— 不具有期待可能性→阻却责任→不构成犯罪
- C. ☒ —— 不是减轻，是阻却（完全不存在期待可能性）
- D. ☒ —— 不是紧急避险（紧急避险=保护利益>牺牲利益，这里李四保护的是女儿生命，牺牲的是他人财产→成立紧急避险也有可能，但题目问的是"期待可能性"→张明楷认为这是缺乏期待可能性的经典案例）

答案：B

...

💡 期待可能性="法律不强人所难"。当一个人的处境逼得他"无可奈何"做了坏事，刑法不怪你。判断标准：以行为人在当时的具体情况下能否实施适法行为为标准（具体行为人标准），不是以一般人为标准。我国刑法体现：被告人作虚假供述不构成伪证罪（自保缺乏期待可能性）。

辨析题。甲长期生活在与世隔绝的深山中，某日被带到城市，在不知情的情况下实施了某种法定犯罪行为（该行为在深山中完全合法）。甲是否具有违法性认识的可能性？

- A. ☒ —— 一般情况下"不知法律不是借口"，但甲属于"确实不可能知道"的例外
- B. ☒ —— 甲确实不可能知道该行为违法→缺乏违法性认识的可能性→阻却责任
- C. ☒ —— 法定犯也需要违法性认识的可能性（对法定犯，"不可能知道"的余地反而比自然犯更大）
- D. ☒ —— 应以行为人的知能水平为标准（具体行为人标准），不是一般人标准

答案：B

...

💡 违法性认识的可能性是"消极责任要素"——不需要行为人现实地具有违法性认识，只需要具有认识"可能性"。一般情况：不知法不是借口。例外：确实不可能知道→阻却责任（如与世隔绝、行政机关错误指导导致相信行为合法、法律突然变更过渡期）。

辨析题。关于饮酒后犯罪的责任能力，下列哪一说法正确？

- A. ☒ —— 刑法第18条第4款："醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。"不能以醉酒后无责任能力为由免责（自陷性行为）
- B. ☒ —— 自己主动喝酒导致丧失或减弱辨认控制能力→属于原因自由行为，应负刑事责任
- C. ☒ —— 没有"一律从轻"的规定
- D. ☒ —— 首次且不知情的病理性醉酒（无法预见自己会醉）→不具有责任能力→不负刑事责任（但如果是明知自己有病理性醉酒史仍饮酒→应负刑事责任）

答案：B

...

💡 原因自由行为=行为人故意或过失使自己陷入无责任能力状态，并在该状态下实施不法行为→应负刑事责任。醉酒=典型。但"不知情的病理性醉酒"（第一次发作、不知道会醉）→不具责任能力→不负刑事责任。

快速自测——第六章核心概念辨析速查。

1. 间接故意对结果：放任；过于自信过失对结果：不希望
2. 对象错误（认错人）：故意既遂；打击错误（打偏了）：对目标未遂+对被害人过失
3. 假想防卫阻却故意；按过失犯或意外事件处理
4. 期待可能性=在那种情况下能期待你守法吗？不能→阻却责任
5. 原因自由行为=故意或过失使自己陷入无责任能力状态→应负刑事责任

...

💡 五个辨析点全是第六章最容易出错的考点。一分钟全对=责任论过关。

第七章 犯罪的特殊形态

第一节 犯罪的特殊形态概述

犯罪的特殊形态包括哪三种？填空：犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止。这三种形态统称为故意犯罪形态（与既遂形态相对）。

特殊形态只能出现在犯罪过程中，是终局性的停止（不是暂时停顿）。就同一犯罪行为而言，出现了一种形态后不可能再出现另一种形态。

...

犯罪阶段与犯罪形态的关系：预备阶段只能出现预备与中止；实行阶段只能出现未遂、中止与既遂。阶段是动态过程，形态是终局状态。一个行为可能经过多个阶段，但只有一个终局形态。

间接故意：传统理论认为间接故意没有预备、未遂、中止。张明楷不赞成——从规范意义上说间接故意与直接故意没有质的区别，且间接故意人与直接故意人可以成立共同犯罪，没有理由仅处罚直接故意的未遂。

💡 口诀：三特殊（预备/未遂/中止）+一正常（既遂）=四形态。终局性=到了这一步就"定住了"，不能又变成别种。

特殊形态与犯罪构成的关系——填空。

使用以既遂为模式的犯罪构成概念→特殊形态不完全符合犯罪构成→不得不认为符合"修正的犯罪构成"。

使用成立犯罪的最低标准意义上的犯罪构成概念→特殊形态都符合犯罪构成。

处罚犯罪预备、未遂、中止具有例外性——只有不法和责任达到值得科处刑罚的程度时才处罚。

...

可罚性三分法（以未遂为例）：①罪质严重的未遂→应当处罚（如故意杀人未遂、抢劫未遂、强奸未遂）；②罪质一般的未遂→只有情节严重时才处罚（如盗窃未遂、诈骗未遂）；③罪质轻微的未遂→不以犯罪论处（如非法侵入住宅未遂、侵犯通信自由未遂）。罪质轻重取决于保护法益的重要程度。

💡 不是所有预备/未遂/中止都罚。刑法只是"有条件地"把处罚范围扩张到这些特殊形态，扩张的前提是"确实值得罚"。

第二节 犯罪预备

犯罪预备的四个特征——填空。

1. 客观上实施了犯罪预备行为（准备工具、制造条件）
2. 主观上为了实行犯罪（"为了犯罪"=为了实行犯罪，不包括为了预备而准备）
3. 事实上未能着手实行犯罪
4. 未能着手是由于行为人意志以外的原因

...

预备行为分类：准备工具=准备实行犯罪必需的、杀伤力较强的工具（如凶器），不包括"为抢劫后逃跑买摩托车"之类。制造条件=除准备工具以外的为实行犯罪制造条件的行为，如调查犯罪场所与被害人行踪、前往犯罪场所、诱骗被害人、商议犯罪计划等。

"为了犯罪"的限制解释："为了购买毒药而打工挣钱"不是犯罪预备。因为预备行为是为了实行行为制造条件，而不能无限往前追溯。

预备犯的处罚：对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。实践中处罚预备犯极为例外。

💡 四特征两两分组：客观（实施了预备+没着手）+主观（为了实行+意志以外）。刑法第22条只说了"准备工具、制造条件"，完整定义要补齐后三个特征。

第三节 犯罪未遂

犯罪未遂的概念与特征——填空。

刑法第23条："已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。"

三个特征：

1. 已经着手实行犯罪（与犯罪预备相区别）
2. 犯罪未得逞（与犯罪既遂相区别）
3. 未得逞是由于犯罪人意志以外的原因（与犯罪中止相区别）

...

未遂犯的处罚根据：客观的未遂论=处罚根据在于行为具有发生结果的客观危险性；主观的未遂论=处罚根据在于行为人的法敌对意思。张明楷采取客观的未遂论——只有当行为具有达致既遂的紧迫危险时才能处罚。

未遂犯的处罚：对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

💡 三个特征正好与其余三种形态一一对照：着手↔预备；未得逞↔既遂；意志以外↔中止。记住这一对照关系，四个形态的边界就清楚了。

"着手"的判断——填空。

着手=开始实施刑法分则所规定的实行行为。是预备与未遂的分界点。

形式客观说：以实施构成要件的一部分行为为着手。实质客观说：以行为具有达致既遂的紧迫危险为着手。

张明楷采取实质的客观说：以行为时存在的所有客观事实为基础，判断行为是否具有达致既遂的紧迫危险。

...

"着手"的各种学说：主观说（犯意可以被确认时）→形式客观说（开始实施构成要件行为）→实质客观说（具有达致既遂的紧迫危险）→折中说（从行为人整体计划看是否对法益造成直接危险）。

着手的判断资料：行为时存在的所有客观事实，不能仅以行为人计划的内容为准。

💡 着手=犯罪进入"实操"阶段的标志。不是你"以为自己开始干了"就是着手，而是客观上你的行为已经具有了"马上就要成功"的紧迫危险性。

"未得逞"与"意志以外的原因"——填空。

"未得逞"=犯罪未既遂。判断标准：构成要件结果说（是否发生了构成要件结果——是否发生了行为人所意欲的、法律性质相同的结果）。

"意志以外的原因"=违背行为人意志的原因。包括三种情形：物理的障碍、生理的障碍、心理的障碍。

...

"意志以外的原因"详解:

- 物理障碍: 第三人阻止(被警察抓住)、自然力量(强风使子弹打偏)
- 生理障碍: 行为人突然昏倒、体力不支
- 心理障碍: 行为人产生恐惧、害怕被处罚而不敢继续

"未得逞"的判断: 对结果犯=没有发生法定结果; 对行为犯=没有完成法定行为; 对危险犯=没有造成法定危险状态。

💡 关键区分在于"我能不能继续": 我不能继续了→意志以外→未遂; 我还能继续但选择不继续了→中止。

第四节 不能犯

不能犯的概念与学说——填空。

不能犯=行为人主观上具有犯意, 但客观行为没有达致既遂的任何危险。

各家学说对比:

- 纯粹主观说: 只要有犯意就成立未遂→处罚范围最宽
- 抽象的危险说: 以行为人认识的内容判断危险→主观归罪之嫌
- 具体的危险说: 以一般人的认识判断危险(新客观说)
- 客观的危险说: 以客观因果法则事后判断→过度缩小处罚范围
- 印象说: 行为动摇了公众对法秩序的信赖→没有明确标准

张明楷采取修正的客观的危险说。

...

修正的客观危险说三要素:

- ①判断资料=行为时存在的所有客观事实(包括事后查明的事实)
- ②判断方法=对客观事实进行一定抽象+分析未发生结果的原因(缺什么要素? 能否继续? 是否基于重大无知? 有无降低/阻止危险?)
- ③判断基准=客观的因果法则(不是一般人观念)

💡 传统理论把"不能犯"当作"未遂犯的一种类型", 张明楷反对——真正的不能犯不是未遂, 是"根本没有危险所以根本不构成犯罪"。区分关键: 行为客观上有没有达致既遂的危险。

不能犯的具体判断——填空配对。

案例	属于什么
将白糖当砒霜给人吃	不能犯(手段不能——客观上无任何危险)

案例	属于什么
向尸体开枪（以为是活人）	不能犯（对象不能——不存在变为活人的可能性）
使用没有子弹的枪射击（附近无子弹）	不能犯（手段不能——不能继续开枪）
开枪瞄准但因被害人移动没打中	未遂犯（行为本身通常具有造成结果的较大可能性，移动是偶然细节）
扒窃但被害人口袋无财物（被害人身上有财物）	未遂犯（可立即伸入另一口袋）
向静脉注射3毫升空气（以为能致死）	不能犯（危险性极小且无继续条件——通常120毫升才致死）

...

判断方法口诀：抽象掉偶然细节（打偏了=未遂）→分析缺什么要素（缺主体/对象/有效手段=不能犯）→看能否继续（能继续=未遂）→查是否基于重大无知（迷信犯=不能犯）→判断危险程度（极小=不能犯）。

💡 未遂和不能犯的区别不在于"行为人怎么想的"，而在于"客观上有没有危险"。危险判断=行为时所有客观事实+客观因果法则。

幻觉犯（误想犯）——填空。

幻觉犯=某种事实本来不违法，但行为人误认为违法。最典型两种：反面的禁止错误（误以为刑法处罚其行为）和反面的允许错误（误以为自己的正当行为构成犯罪）。

幻觉犯与违法性错误正相反——违法性错误=事实本来就违法，行为人误以为不违法。

幻觉犯不具有形式的违法性与实质的违法性→不可罚。

...

四种错误类型对比：

- 幻觉犯：行为不违法，行为人以为违法→不可罚（如得到17岁少女同意后性交，以为构成犯罪——实际上不构成）
- 违法性错误：行为违法，行为人以为不违法→可能阻却责任（如知道女方不满14岁但以为同意就合法）
- 不能犯：没有违法事实，行为人以为有→不构成未遂（如以为对方13岁实际16岁）
- 事实错误：有违法事实，行为人以为没有→可能阻却故意（如对方12岁但以为14岁以上）

💡 幻觉犯=法律上的"不能犯"。你觉得自己正在犯罪，但法律说"你这根本不算犯罪"。和未遂的本质区别：未遂有实质违法性，幻觉犯连形式违法性都没有。

第五节 犯罪中止

犯罪中止的概念与类型——填空。

刑法第24条："在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。"

两种类型：

1. 未实行终了的中止：在预备阶段或实行行为还没实行终了时自动放弃
2. 实行终了的中止：在实行行为终了后自动有效地防止结果发生

中止行为本身不是犯罪，而是刑法鼓励的行为。

...

犯罪中止与中止行为的区别：中止行为是原因（刑法鼓励），犯罪中止形态是结果（犯罪状态）。中止行为之前的行为是处罚根据，中止行为本身是减免处罚的根据。不可混为一谈。

中止犯的处罚：没有造成损害的→免除处罚；造成损害的→减轻处罚。

💡 中止=能继续但选择停下来+真的停住了。两个"自动"是关键——自动放弃、自动防止结果。不是被迫的，是你自己选的。

犯罪中止的成立条件——填空。

1. 时间条件：必须发生在犯罪过程中（预备阶段或实行阶段）
2. 自动性条件：必须是自动放弃犯罪（不是被迫停止）
3. 彻底性条件：必须是彻底放弃犯罪（不是暂时的停顿）
4. 有效性条件（实行终了的中止）：必须有效地防止犯罪结果发生

"自动性"=行为人出于本人意志而放弃。判断标准：弗兰克说（"能达目的而不欲"=中止；"欲达目的而不能"=未遂）。

...

"自动性"的核心判断：关键不在于外部障碍有多大，而在于行为人自己怎么想。即使有外部障碍，如果行为人不是因为障碍而停止，而是自己选择停止→仍然是中止。

经典案例：A用刀杀B，B说"我家里有老母亲要养，求你放过我"，A心软了放下刀走了→中止（能杀但选择不杀）。A用刀杀B，发现B身边站着两个警察，A转身就走→未遂（不敢杀了，不是不想杀了）。

💡 弗兰克公式："能达目的而不欲"=我想停所以停了=中止；"欲达目的而不能"=我想继续但被迫停=未遂。一字之差，天壤之别。

犯罪中止的法律性质——填空。

对中止犯减免刑罚的根据（学说）：

- 法律说：违法性减少/消灭说（因中止而减少违法性）或责任减少/消灭说（因中止而减少责任）
- 政策说：为行为人架设"后退的黄金桥"（鼓励放弃犯罪）
- 并合说：法律说+政策说的结合
- 刑罚目的说：中止行为使一般预防、特殊预防的必要性减少或消灭

张明楷倾向并合说（法律说+政策说）。

...

各种学说的实践影响：

- 如果采取违法性减少说→中止行为使行为的违法性降低了→对中止犯减免处罚是因为"行为没那么坏了"
- 如果采取责任减少说→中止行为表明行为人责任降低→减免是因为"没那么值得谴责了"
- 如果采取政策说→中止是给行为人"回头是岸"的机会→减免是"奖励"
- 不同学说影响"自动性"的判断标准——如果采政策说，只要客观上没有外部障碍就认定为自动性；如果采法律说，还要看行为人主观上是否真的"后悔"。

💡 "后退的黄金桥"=刑法给你一个体面退出的机会。哪怕你已经开始犯罪了，只要你真心实意停下来并且真的防止了结果，刑法就会奖励你（减免处罚）。

全章综合

全章四形态核心对比表——填空。

	预备	未遂	中止	既遂
所处阶段	预备阶段	实行阶段	预备/实行阶段	实行后
停止原因	意志以外	意志以外	本人意志	—
处罚	从轻/减轻/免除	从轻/减轻	免除（无损害）/减轻（有损害）	法定刑

...

三条分界线：

- ① 预备↔未遂：看"着手"——是否已经开始实行行为
- ② 未遂↔中止：看"意志"——是本人想停还是被迫停（弗兰克公式）
- ③ 未遂↔既遂：看"结果"——构成要件结果是否发生

不能犯的特殊地位：不是未遂的一种类型，而是"根本不构成犯罪"——客观行为没有达致既遂的任何危险。

💡 四形态+不能犯=五个概念。三个分界标准：着手（预备/未遂）、意志（未遂/中止）、结果（未遂/既遂）、危险（未遂/不能犯）。

自测卡专区

辨析题。A准备了毒药想杀B，但在准备毒药的过程中被警察抓获。A的行为属于什么？

- A. 犯罪预备——客观上实施了预备行为，由于意志以外的原因未能着手 ☒
- B. 犯罪未遂——已经着手实行，但由于意志以外的原因未得逞 ☒（准备毒药≠着手实行杀人）
- C. 不能犯——毒药还没投放，没有危险 ☒（预备阶段不谈不能犯，不能犯是相对于未遂而言的）
- D. 犯罪中止——A可以选择不继续 ☒（被警察抓=意志以外的原因）

答案：A

...

💡 着手是关键分界线。准备毒药=预备行为；给被害人投放毒药=着手实行。本案中A还没到达“投放”这一步就被抓了→预备。不能犯是相对于未遂而言的（有犯意但客观行为没危险），不能在预备阶段讨论。

辨析题。甲用刀砍乙，砍了两刀后乙血流满面。甲心生怜悯，放下刀将乙送往医院，乙经抢救未死。甲的行为属于什么？

- A. 故意杀人未遂——已经着手实行，未得逞 ☒
- B. 故意杀人中止——自动放弃犯罪并有效防止死亡结果 ☒（“自动放弃+有效防止”=中止的两个关键词都满足）
- C. 故意伤害既遂——砍两刀已造成伤害 ☒（甲有杀人故意，不是只想要伤害）
- D. 前面砍两刀=未遂，后面送医院=中止→未遂 ☒（同一犯罪行为只有一个终局形态）

答案：B

...

💡 张明楷原文：“如若认为前面的行为成立犯罪中止形态，就不应认为其前面的行为已经构成故意杀人未遂。易言之，如果后面的行为成立犯罪中止，就不应认为前面的行为已经形成了终局性的犯罪未遂形态。”同一个犯罪行为，只有一个终局形态。

快速自测——第七章核心概念辨析速查。

1. 预备↔未遂分界：着手
2. 未遂↔中止分界：意志（能达目的而不欲=中止，欲达目的而不能=未遂）
3. 未遂↔不能犯分界：客观危险（行为客观上有没有达致既遂的危险）
4. 中止的核心词两个：自动+有效
5. 未遂的三特征：着手 + 未得逞 + 意志以外的原因
6. 预备的四特征：预备行为 + 为了实行 + 未能着手 + 意志以外的原因

...

💡 六问全对=第七章通关。第七章的核心就一句话：犯罪从开始到结束，中间可能停在哪、为什么停、停了怎么处理。停的位置×停的原因=四种形态。

辨析题。关于未遂犯的处罚范围，张明楷的三分法是什么？

1. 罪质严重的未遂→应当处罚（如故意杀人、抢劫、强奸）
2. 罪质一般的未遂→只有情节严重时才处罚（如盗窃、诈骗）
3. 罪质轻微的未遂→不以犯罪论处（如非法侵入住宅、侵犯通信自由）

罪质轻重取决于保护法益的重要程度。

...

💡 不是所有未遂都罚。三个等级：严重=必罚，一般=严重才罚，轻微=不罚。刑法只是"有条件地"把处罚范围扩张到未遂——扩张的前提是"确实值得罚"。这体现了刑法的谦抑性。

辨析题。关于不能犯的判断——张明楷的修正客观危险说，判断步骤是什么？填空。

1. 判断资料：行为时存在的所有客观事实（包括事后查明的）
2. 判断方法：①对客观事实进行一定抽象（抽象掉偶然细节）；②分析未发生结果的原因（缺什么要素？能否继续？是否基于重大无知？有无降低/阻止危险？）
3. 判断基准：客观的因果法则（不是一般人观念）

...

💡 三步法口诀：资料（全事实）→方法（抽象+分析缺什么）→基准（科学法则）。最常考：①打偏了=抽象掉偶然→未遂；②白糖当砒霜=分析要素→不能犯；③注射3ml空气以为是致死量=判断危险程度→几乎为零=不能犯。

第八章 共同犯罪

第一节 共同犯罪的理论前提

共同犯罪的本质——填空。张明楷的核心命题：

共同犯罪是不法形态，其成立不以责任要素为必要。处理共同犯罪时，先从不法层面判断法益侵害结果归属于哪些人的行为，再从责任层面个别地判断各参与人是否具有责任。

刑法第25条第1款"共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪"应当理解为"共同犯罪是指二人以上共同在故意犯罪"，而非"共同犯罪是指二人以上共同故意在犯罪"。

...

为什么是"不法形态"? ①15岁甲入户盗窃, 17岁乙望风→传统理论: 甲未达责任年龄→不成立共犯→乙无法定罪(荒谬)。张明楷: 甲和乙在不法层面成立共犯(甲是正犯, 乙是帮助犯), 乙具备责任→成立盗窃罪。②不知情的甲与精神病乙共同杀人→不承认共犯=不能将死亡结果归甲→甲无罪(荒谬)。承认不法层面共犯→结果归甲→甲有责任=故意杀人既遂。

共同犯罪的两个目的: ①归责范围扩张——让没有直接造成结果但对结果有因果贡献的人也对结果负责; ②正犯性确认——让在共同犯罪中起主要作用但没有实施构成要件行为的人承担共同正犯责任。

💡 "共同犯罪=不法形态"是张明楷共同犯罪论的基石。记住: 共犯"共同"的是不法, 不是责任。责任各算各的。

共同犯罪的认定方法——填空。三个重心:

1. 以不法为重心: 先从不法层面判断, 再从责任层面个别判断
2. 以正犯为中心: 先确定谁的行为符合构成要件(正犯), 再判断谁是教唆犯、帮助犯
3. 以因果性为核心: 只有当教唆、帮助行为与正犯结果之间具有物理因果性或心理因果性时, 才让共犯对结果负责

...

传统理论的三个缺陷: ①混合认定——同时在不法与责任层面判断, 且先判断责任后判断不法; ②整体认定——将二人以上行为作为整体判断, 难以分别考察因果性; ③抽象判断——只判断是否有"共同的犯罪行为", 不具体考察行为与结果的因果性。

张明楷的路径: 甚至可以淡化"共同犯罪"概念——直接认定正犯与共同正犯→判断哪些参与人的行为与正犯结果有因果性→分别判断各参与人的责任→按共犯处罚原则量刑。在这个过程中, 不需要提出"谁和谁成立共同犯罪"这样的问题。

💡 三重心口诀: 不法为根(先看不法)→正犯为干(先找主犯)→因果为脉(要有因果联系才追责)。

间接正犯——填空。

间接正犯=通过支配或者操纵他人实现犯罪的人。与直接正犯的区别: 不是亲自实施构成要件行为, 而是利用他人作为工具。

被利用者欠缺构成要件要素的典型情形: 利用他人的反射身体活动、利用他人的过失行为、利用他人的合法行为。

被利用者欠缺责任的典型情形: 利用无责任能力者、利用他人的禁止错误(违法性认识错误)。

...

亲手犯：必须由正犯自己直接实施的犯罪，不能以间接正犯方式实施。如伪证罪（必须由证人、鉴定人自己作虚假陈述）、重婚罪（必须自己实施重婚行为）。

间接正犯与教唆犯的区分：关键在于是否"支配"了犯罪事实。如果幕后人只是引起他人犯意，他人自由决定是否实施→教唆犯；如果幕后人操控了整个过程，他人只是工具→间接正犯。

💡 间接正犯=把别人当枪使。你躲在幕后遥控全局，前台那个人只是你的工具。教唆犯=你煽动别人，但别人自己决定去干。

共同正犯——填空。

共同正犯=二人以上共同实行犯罪。核心原则："部分实行，全部责任"。

成立条件：

1. 客观的成立条件：二人以上具有共同实施行为的意思联络和共同的实行行为
2. 主观的成立条件：各参与人的行为对法益侵害结果的发生都起到了重要或关键的作用

处罚原则：部分行为全部责任——各共同正犯人都要对整体结果承担全部责任。

...

"部分实行全部责任"的含义：一人击中案——甲乙基于意思联络共同向丙开枪，甲击中丙致死，乙没击中。甲乙成立共同正犯→死亡结果归属于两人→甲=既遂、乙=既遂。如果否认共犯关系→乙只成立杀人未遂（不公平）。

共同正犯的本质：犯罪共同说（两人必须有共同犯罪故意才能成立）vs 行为共同说（两人共同实施行为即可，故意可以不同）。张明楷倾向于行为共同说——甲有杀人故意、乙有伤害故意，两人基于意思联络共同对丙实施暴力致丙死亡→甲=杀人既遂、乙=伤害致死，两人仍成立共同正犯。

💡 一人打中，全组负责。不是因为"你们是一伙的"这种道德判断，而是因为每个人的行为都对结果有因果贡献（物理或心理因果性）。

共犯从属性——填空。

张明楷采取限制从属性说：正犯的行为符合构成要件且违法时，共犯才成立。不需要正犯具有责任（因为责任是个别的）。

五种程度：夸张从属性（需具备可罚条件）→极端从属性（需具备有责性）→限制从属性（需符合构成要件且违法）→最小从属性（只需符合构成要件）→一般违法从属性（只需一般违法性）。

...

限制从属性的应用：13岁Y杀人，X教唆→限制从属性说：Y的行为符合构成要件且违法→X成立教唆犯；极端从属性说：Y无责任→X不成立教唆犯→只能按间接正犯处理（但X并没有

支配V，不符合间接正犯特征→出现处罚漏洞）。

不需"罪名从属性"：甲对乙说"入户盗窃"，让乙望风，但甲入户后抢劫。正犯甲=抢劫罪，帮助犯乙=盗窃罪。罪名可以不同——这是行为共同说的结论。

💡 限制从属性=正犯行为得是"坏事"（不法），但不需要正犯能被"怪罪"（责任）。因为责任是每个人自己的事，不连带。

狭义的共犯

教唆犯——填空。

教唆犯=故意唆使并引起他人实施符合构成要件的违法行为的人。

成立条件：

1. 教唆对象：原则上必须是实际具有责任能力的人（不必达到法定年龄）
2. 教唆行为：使他人产生实施符合构成要件的违法行为的意思（不要求引起被教唆者的犯罪故意）
3. 因果性：教唆行为与正犯结果之间需有心理因果性
4. 教唆故意：认识到自己的教唆行为会使被教唆人产生犯罪意图并实施犯罪
- ...

"土药案"：甲教唆乙"把毒药递给丙"但乙听成"把土药递给丙"，乙无杀人故意。传统观点要求教唆引起被教唆者的"犯罪故意"→甲不成立教唆犯（因为乙没有故意）→甲也不成立间接正犯（甲没有支配意思）→甲无罪（荒谬！）。张明楷：乙的行为符合构成要件且违法，实施该行为的意思由甲引起→甲成立故意杀人罪的教唆犯。

未遂的教唆（侦查陷阱）：甲将没有子弹的枪给乙让乙杀丙。如果甲唆使的是不能犯=不成立教唆犯。如果唆使的是未遂犯（客观上仍有危险）→需判断甲是否真的希望结果发生。侦查陷阱中唆使无犯意者犯罪→以教唆犯论处。

💡 教唆犯的核心：你引起了别人干坏事的想法。不需要别人真的形成"犯罪故意"——只要他客观上干了违法的事，且是受你唆使，你就成立教唆犯。

帮助犯——填空。

帮助犯=帮助他人犯罪的人。帮助行为必须与正犯结果之间具有物理因果性或心理因果性。

成立条件：

1. 帮助行为：实施了使正犯行为更为容易的行为
2. 帮助故意：认识到正犯在实施犯罪，且自己的帮助行为会促进正犯的犯罪
3. 因果性：帮助行为与正犯结果之间需有因果性

中立的帮助行为（日常生活行为）——如五金店老板甲明知乙买螺丝刀用于入室盗窃仍卖给乙。张明楷：如果甲确切知道乙的犯罪计划且乙的犯罪依赖甲的帮助才能完成→可成立帮助犯；如果只是概括知道且帮助作用轻微→不成立。

...

物理因果性：提供犯罪工具→正犯用工具实施犯罪→有帮助。心理因果性：望风→正犯知道有人望风更放心→有帮助（即使客观上没有被发现的风险）。

帮助犯与教唆犯的区别：教唆犯=引起他人犯意（对方本来不想犯罪）；帮助犯=强化他人犯意或提供便利（对方本来就想犯罪）。在被教唆者已有犯意时，再"教唆"=帮助犯。

💡 帮助犯=给正犯"递刀子"。不需要你亲自动手，只要你的帮助让犯罪更容易了、更可能成功了，而且你对犯罪结果有因果贡献。

共同犯罪基本术语——填空。

最广义的共犯：二人以上共同实施犯罪的情形（含故意与过失）。

中间意义的共犯：二人以上故意共同实施犯罪。

狭义的共犯：正犯（含共同正犯）之外的教唆犯与帮助犯。

正犯包括：直接正犯、间接正犯与共同正犯。

...

术语辨析：

- 直接正犯=自己亲自实施构成要件行为
- 间接正犯=利用他人作为工具实现犯罪
- 共同正犯=二人以上共同实行犯罪（部分实行全部责任）
- 教唆犯=唆使他人产生犯罪意图并实施犯罪
- 帮助犯=为正犯犯罪提供便利

"共犯"一词的三种用法：最广义=所有参与人；中间意义=二人以上故意共同犯罪；狭义=教唆犯+帮助犯（不包括正犯）。阅读文献时要注意语境。

💡 共同犯罪的基本公式：直接正犯（自己干）+间接正犯（把别人当工具）+共同正犯（一起干）+教唆犯（煽动别人干）+帮助犯（帮别人干）=五种参与形态。

共犯的脱离——填空。

共犯的脱离=行为人虽然实施了共犯行为，但后来又消除了该行为对犯罪的促进作用，导致先前的共犯行为与结果之间不具有因果性。

实质：是共犯的因果性问题。脱离成功→只对脱离前的行为负责（可能成立中止犯或未遂犯）；脱离失败→对全部结果负责。

. . .

脱离的判断：教唆犯=消除被教唆者的犯意（如真诚劝说放弃并让对方打消犯意）→脱离。
帮助犯=消除帮助的物理或心理因果性（如取回提供的工具、明确告知不再参与）→脱离。
共同正犯=消除自己的行为对后续犯罪的因果贡献→脱离。

经典案例：甲教唆乙杀人，乙同意。甲随后反悔，多次打电话劝乙放弃，乙口头同意但第二天仍杀了人→甲的教唆行为与结果的心理因果性未被消除→未脱离→仍为教唆既遂。甲需要有效阻止结果发生才成立中止。

💡 脱离的实质就是"切断因果链条"。你虽然开了头，但后来你做的"抵消工作"让开头不再对结局有影响=脱离成功。

全章综合

共同犯罪五大参与形态对比——填空。

形态	行为特征	核心规则
直接正犯	亲自实施构成要件行为	对结果直接负责
间接正犯	支配他人实现犯罪	被利用者是工具
共同正犯	二人以上共同实行	部分实行全部责任
教唆犯	引起他人犯意	引起他人实施违法行为
帮助犯	便利正犯犯罪	物理或心理因果性

. . .

五种形态的责任：直接正犯=全部责任；间接正犯=正犯责任；共同正犯=部分实行全部责任；教唆犯=按其所教唆的罪定罪；帮助犯=从犯，比照正犯从轻、减轻或免除处罚。

💡 五种形态一句话：自己干（直接）、把别人当枪使（间接）、一起干（共同）、煽动别人干（教唆）、帮别人干（帮助）。

自测卡专区

辨析题。15岁甲入户盗窃，17岁乙望风。按张明楷的观点，以下哪一处理正确？

- A. 甲未达责任年龄，甲乙不成立共同犯罪，乙无罪 ❌（传统理论结论，张明楷反对）
- B. 甲乙成立共同犯罪，甲是正犯（不处罚），乙是帮助犯 ✅（共同犯罪是不法形态——甲的行为符合构成要件且违法=不法层面的正犯，乙的望风行为有心理因果性=帮助犯，甲因未达责任年龄不承担责任，乙具备责任=成立盗窃罪）
- C. 甲未达责任年龄，乙成立间接正犯 ❌（乙没有支配、操纵甲）
- D. 甲和乙均成立盗窃罪 ❌（甲没有责任能力）

答案：B

...

💡 这是张明楷"共同犯罪是不法形态"命题最直接的检验案例。传统理论=两人不符合"主体条件"→不成立共犯→乙无法定罪→荒谬。限制从属性说=甲的不法行为+乙的帮助+乙的责任=乙成立盗窃罪。

辨析题。甲教唆乙："把毒药递给丙喝。"乙听成了"把土药递给丙"，将毒药递给丙，丙死亡。乙无杀人故意。甲是否成立故意杀人罪的教唆犯？

- A. 不成立——甲没有引起乙的杀人故意 ❌（不要求引起被教唆者的"犯罪故意"，只要求引起"违法行为"）
- B. 成立——甲引起了乙实施符合构成要件的违法行为 ✅（乙客观上实施了符合构成要件且违法的行为，该行为的意思由甲引起）
- C. 成立间接正犯——甲利用乙作为工具 ❌（甲没有支配、操纵乙的意思，仅有教唆故意）
- D. 成立故意杀人未遂——乙没有杀人故意，结果不能归属 ❌（正犯乙的行为已经既遂→教唆犯也是既遂）

答案：B

...

💡 这是张明楷"教唆犯只要求引起违法行为，不要求引起犯罪故意"的经典案例。如果要求引起犯罪故意→甲不成立教唆犯（乙没有故意）→甲也不成立间接正犯（没有支配故意）→甲无罪→荒谬。

辨析题。"一人击中案"：甲乙基于意思联络共同向丙开枪，甲击中丙致死，乙未击中。关于乙的责任，以下哪一说法正确？

- A. 乙成立故意杀人未遂——乙没有打中丙 ❌（共同正犯，部分实行全部责任）
- B. 乙成立故意杀人既遂——共同正犯，部分实行全部责任 ✅（甲乙基于意思联络共同开枪→乙的开枪行为对甲有心理帮助→有心理因果性→死亡结果也归属乙）
- C. 乙无罪——没有证据证明乙的行为与死亡有因果性 ❌（有心理因果性——甲知道乙也在开枪，信心更足）
- D. 乙成立过失致人死亡 ❌（乙有杀人故意）

答案：B

...

💡 共同正犯的核心：不是"两个人一起造成了结果"（物理上可能只有一人造成），而是"每个人的行为都对结果有因果贡献"（包括心理因果性——你知道有人配合，你更坚定、更大胆）。这就是"部分实行全部责任"的真正含义。

辨析题。关于限制从属性说的应用，以下哪一处理正确？

- A. 13岁Y杀人，X教唆→极端从属性说：X成立教唆犯 ❌（极端从属性说正是相反——Y无责任→X不成立教唆犯）
- B. 13岁Y杀人，X教唆→限制从属性说：X成立教唆犯 ✅（Y行为符合构成要件且违法→X成立教唆犯）
- C. W正当防卫打死B，Z教唆W→限制从属性说：Z成立教唆犯 ❌（W是正当防卫→阻却违法→正犯行为不违法→Z不成立教唆犯）
- D. P诈骗未达数额，O帮助→限制从属性说：O成立帮助犯 ❌（P的行为不符合构成要件→O不成立帮助犯）

答案：B

...

💡 限制从属性的核心：正犯行为必须同时满足①符合构成要件+②违法。缺任一项→共犯不成立。C中正当防卫=违法阻却→不满足"违法"。D中未达数额=不满足"构成要件符合性"。

快速自测——第八章核心命题速查。

- 1. 共同犯罪的本质：不法形态
- 2. 认定三重心：以不法为重心+以正犯为中心+以因果性为核心
- 3. 间接正犯的本质：支配他人实现犯罪
- 4. 共同正犯的核心规则：部分实行，全部责任
- 5. 张明楷采取的从属性说：限制从属性说
- 6. 教唆犯不要求引起被教唆者的犯罪故意，只要求引起违法行为

...

💡 六问全对=第八章通关。第八章的核心就一句话：你们一起造成了不法结果，需要把结果算到每个人头上，但怪不怪每个人，各算各的。不法共享，责任独算。

辨析题。甲对乙声称入户盗窃，让乙在门外望风，但甲入户后实施了抢劫行为，乙不知情。乙的行为应如何定罪？

- A. ❌（不采取罪名从属性——共犯罪名可以不从属于正犯）
- B. 盗窃罪的帮助犯——乙只有盗窃的故意，在盗窃范围内成立帮助犯 ✅（行为共同说的结论）
- C. ❌（乙的帮助行为与甲的盗窃预备/未遂有因果性，乙有责任）
- D. ❌（乙不知情抢劫，没有抢劫故意）

答案：B

...

💡 这是"罪名不从属性"的经典案例。限制从属性说≠罪名从属性。甲=抢劫罪，乙=盗窃罪。罪名可以不同！这是行为共同说的核心——"共同"的是不法行为，不是故意内容。甲有抢劫故意、乙只有盗窃故意→在盗窃的不法范围内成立共犯。

承继的共同犯罪——填空。

承继的共同正犯=前行为人已经实施了一部分正犯行为之后，后行为人以共同实施意思参与犯罪，并对结果的发生起重要作用。

张明楷的核心立场：除了继续（持续）犯以外，承继的共犯只能存在于犯罪既遂之前。犯罪既遂之后不可能有承继的共犯。

责任范围：后行为人对参与之前的前行为人的行为造成的结果不承担责任。

...

典型场景：①甲对丙实施暴力（抢劫）→乙中途参与取走财物→乙成立抢劫罪（承继的共同正犯/帮助犯）。②甲绑架丙后，乙与甲共同杀害丙→甲=绑架杀人，乙=仅故意杀人罪（结合犯可分割，后行为人仅成立后一犯罪）。③A非法拘禁丙三天后B参与拘禁→B不承担前三天的责任（后行为人不承担参与前的结果）。

💡 承继="半途加入"。你可以中途入伙，但你只对你加入之后的事负责。别人之前捅的刀子，不能算你头上。

身份犯的共同犯罪——填空。

问题：非身份者（无特殊身份的人）与身份者（有特殊身份的人）共同犯罪时，如何处理？

真正身份犯：非身份者可以成为教唆犯或帮助犯，但不能成为共同正犯。例如：非国家工作人员帮助国家工作人员受贿→成立受贿罪的帮助犯。

不真正身份犯：非身份者成立普通犯罪，身份者成立加重犯罪。例如：普通人甲与国家机关工作人员乙共同诬告陷害→甲=诬告陷害罪，乙=诬告陷害罪从重处罚。

...

核心理由：身份是违法要素——非身份者不可能通过他人的身份"获得"对相应法益的侵犯能力。但非身份者可以通过教唆、帮助身份者来间接侵犯该法益→成立共犯。

间接正犯的特殊问题：无身份者不能成为真正身份犯的间接正犯（因为不可能"支配"有身份者使其成为工具时，自己也获得该身份带来的违法性）。例如A（普通公民）欺骗国家工作人员B挪用公款→A不成立挪用公款罪的间接正犯，但成立教唆犯。

💡 身份犯=特殊身份才能犯的罪。没有身份的人可以"帮"有身份的人犯罪（共犯），但不能"替"有身份的人犯罪（正犯），也不能"控制"有身份的人成为间接正犯。

片面的共同犯罪——填空。

片面的共同犯罪=一方有共同犯罪的意思，另一方不知道对方在和自己一起犯罪。

典型情形：片面的帮助犯——甲知道乙要盗窃，主动为乙望风，乙不知情。

张明楷的观点：肯定片面的帮助犯可以成立。因为片面的帮助行为与正犯结果之间可能具有物理因果性。

片面的共同正犯：否定。因为共同正犯要求意思联络，片面的参与不可能成立共同正犯。

...

传统理论的误区：要求"共同的故意"=双方都知情→甲主动望风但乙不知情→不成立共犯→甲无罪。张明楷：甲的望风行为客观上帮助了乙的盗窃，具有物理因果性→甲成立片面的帮助犯。

片面的教唆犯：否定——教唆要求"引起他人犯意"，如果被教唆者不知道有人教唆，不可能被"引起"。

💡 片面帮助=我偷偷帮你，你不知道。你能成立帮助犯，因为你的帮助对结果有客观贡献。但你不能成立共同正犯——因为共同正犯需要双方知道"我俩一起干"。

共犯与违法阻却事由——填空。

问题：正犯行为因违法阻却事由（如正当防卫）而不违法时，不可以成立共犯。

理由：限制从属性说要求正犯行为符合构成要件 + 违法。正当防卫阻却违法→正犯行为不违法→不成立共犯。

但如果部分参与人存在违法阻却事由、部分不存在→违法性具有相对性。例如：甲、乙共同伤害丙，甲是正当防卫（阻却违法），乙不具有防卫条件→乙成立故意伤害罪。

...

关键理解：共犯的成立以正犯行为违法为前提。指示他人实施正当防卫=不成立教唆犯（因为正犯行为合法）。但同一事件中各参与人的违法性可以不同——甲的防卫合法，乙的参与违法，可以分别判断。

💡 违法是"共享"的，但不是"绝对共享"的。正犯不违法=共犯不成立。但违法在参与人之间可以不同——这就是"违法的相对性"。

辨析题。甲以抢劫故意对丙实施暴力（致丙轻伤），压制反抗后，乙知情后中途参与，与甲共同取走财物。乙的行为应如何定罪？

A. ❌（张明楷采取中间说——抢劫是独立犯罪类型，乙参与取财=参与抢劫的构成要件行为）

B. 抢劫罪——乙利用了甲压制反抗的状态，参与了抢劫的取财行为 ✅

- C. ✖ (乙对甲单独造成的轻伤结果不承担责任——承继的共犯只对参与后的结果负责)
D. ✖ (抢劫尚未既遂——取财行为是抢劫实行行为的一部分)

答案: B (乙成立抢劫罪, 但不承担"抢劫致人轻伤"的责任——仅成立普通抢劫)

...

💡 这是承继的共同正犯的经典案例。张明楷的立场: ①肯定承继共犯(在既遂前可以中途加入); ②后行为人不承担参与前的结果(轻伤是甲单独造成的); ③后行为人的罪名=前行为人的罪名(抢劫而非盗窃)。三句话总结: 可以加入、只算加入后、罪名跟前人。

快速自测——第八章全部核心命题速查。

1. 共同犯罪的本质: 不法形态
2. 共犯从属性: 张明楷采取限制从属性说
3. 教唆犯不要求引起犯罪故意, 只要求引起违法行为
4. 罪名从属性: 不要求
5. 承继的共犯: 只能存在于犯罪既遂之前, 后行为人不承担参与前的结果
6. 真正身份犯: 非身份者可以成立教唆犯/帮助犯, 但不能成立共同正犯
7. 片面的帮助犯: 可以成立

...

💡 七问全对=第八章通关。这七问覆盖第八章从理论前提(不法形态)到具体形态(间接正犯/共同正犯/教唆犯/帮助犯)再到特殊问题(承继/身份/片面)的全部核心。

第九章 罪数

罪数概说

罪数体系的四种类型——填空。

1. 单纯的一罪
2. 包括的一罪
3. 科刑的一罪
4. 并罚的数罪

...

为什么中国不用德国的竞合论? 德国竞合论将中立关系的吸收关系也归入法条竞合(如杀人时捅破衣服=故意杀人+故意毁坏财物=法条竞合中的吸收关系), 这与我国刑法理论将法条竞合限定为"包容或交叉关系"的传统不符。且德国将连续犯、集合犯归入实质竞合(数罪并罚), 我国大多将连续犯规定为一罪或法定刑升格情形。

为什么要有"包括的一罪"? 因为我国不承认中立关系的法条竞合中的吸收关系, 所以像共罚的事前行为、共罚的事后行为这些现象不能归入法条竞合, 也不能归入想象竞合, 必须单

列一类。

💡 口诀：单纯=本来就是一事，包括=整体评价是一事，科刑=虽是数罪只罚最重，并罚=数罪各罚相加。

单纯的一罪

继续犯（持续犯）——填空。

继续犯=行为人从着手实行到终止以前，一直处于持续状态的犯罪。典型例子：非法拘禁罪。

三个特征：

1. 实行行为与不法状态同时继续（与状态犯的主要区别）
2. 实行行为在一定时间内持续
3. 一个行为侵犯了同一具体的法益（同一对象、同一法益）

两类：法定的继续犯（如非法拘禁）+ 事实的继续犯（如网络诽谤）。

...

继续犯 vs 状态犯：继续犯=实行行为本身在持续（如一直拘禁着）；状态犯=实行行为已完成，但法益受侵害的状态在持续（如盗窃后的占有状态）。关键区别：行为是否还在"进行中"。

继续犯的处理：无论持续时间多长，均以一罪论处。持续时间跨越新旧两法→适用新法。追诉期限从行为终了之日起算。在继续犯行为持续期间参与犯罪→成立共同正犯或帮助犯。

💡 继续犯=犯罪在"进行时"而非"完成时"。非法拘禁3天=一罪，不是3个非法拘禁罪。

法条竞合——填空。

法条竞合=一个行为同时符合数个法条的犯罪构成，但从法条之间的逻辑关系来看，只能适用一个法条。

四个逻辑关系（只有一种成立法条竞合）：

- 对立关系：不可能成立法条竞合（盗窃vs诈骗——一个行为不可能同时触犯）
- 交叉关系：张明楷认为应认定为想象竞合（不是法条竞合）
- 中立关系：不可能成立法条竞合（杀人vs毁坏财物——可能同时触犯，但法条间无包容交叉）
- 包容关系：成立法条竞合！属于A的所有事项都属于B

...

包容关系的两种类型：①特别关系——特别法条包含普通法条的所有要素再加特别要素（如故意杀人罪包含故意伤害罪）；②补充关系——基本法条与补充法条（如第114条放火

罪未造成严重后果补充了第115条的放火罪造成严重后果)。

法条竞合的处理原则：特别法优于普通法；重法优于轻法仅在法律有明文规定时适用。法条竞合是单纯的一罪——适用一个法条就完整评价了行为，同时适用多法条=重复评价=重复处罚。

💡 只有包容关系（特别法vs普通法）才是真正的法条竞合。交叉和中立都不是——那属于想象竞合。

包括的一罪与科刑的一罪

包括的一罪——填空。

包括的一罪=对行为进行孤立评价可能得出数罪，但整体评价只需适用一个分则条文。

典型情形：

- 共罚的事前行为
- 共罚的事后行为

...

共罚的事后行为：基本犯罪行为完成后实施的行为，如果该事后行为没有侵犯新的法益，且缺乏期待可能性→不另定罪。如：①盗窃犯自己窝藏、销售赃物→不另定赃物犯罪（缺乏期待可能性）；②杀人后碎尸→不另定侮辱尸体罪（是杀人行为的自然延伸）。

包括的一罪 vs 法条竞合：法条竞合=一个行为触犯数法条；包括的一罪=数行为触犯数法条，但整体评价为一罪。包括的一罪是"数行为→一罪"，法条竞合是"一行为→一罪（排除其他法条）"。

💡 包括的一罪=分开看像是好几件事，合起来看其实是一件事的"套餐"。就像"入户盗窃"=非法侵入+盗窃，但刑法评价为一个盗窃罪（入户是加重情节），不会拆成两个罪。

想象竞合——填空。

想象竞合=一行为同时触犯数罪名。从一重罪处罚（不并罚）。

特征：一个行为（自然意义上的一个行为）+ 触犯数罪 + 侵害数个法益。

与法条竞合的区别：法条竞合是法条之间存在包容关系（逻辑关系），想象竞合是事实上的竞合（没有逻辑关系但一个行为实际触犯了）。

...

典型例子：①开一枪打死一人、打伤一人→一行为同时触犯故意杀人罪与故意伤害罪→想象竞合，从一重（故意杀人）。②盗窃正在使用中的电线→一行为同时触犯盗窃罪与破坏电力设备罪→想象竞合。③以揭发隐私相威胁敲诈勒索→一行为可能触犯敲诈勒索罪与侮辱罪→想象竞合。

"一个行为"的判断：以社会的一般观念为基准进行判断。自然意义上的一个行为=想象竞合；数个行为=可能构成牵连犯或数罪并罚。

💡 想象竞合=一枪打出两个洞。真的只干了一件事，但这一件事惹了好几个罪名。从最重的那个罪罚你——不能让你"一罪二罚"。

牵连犯——填空。

牵连犯=以实施某一犯罪为目的，而其手段行为或结果行为又触犯了其他罪名。从一重罪处罚（不并罚，但刑法明文规定并罚的除外）。

特征：数行为 + 触犯数罪名 + 数行为之间存在牵连关系（手段与目的、原因与结果的牵连）。

与想象竞合的区别：想象竞合=一行为；牵连犯=数行为。

...

典型例子：①伪造国家机关公文后用于诈骗→手段行为（伪造公文）+目的行为（诈骗）=牵连犯，从一重处。②侵入他人住宅进行盗窃→手段行为（非法侵入住宅）+目的行为（盗窃）=牵连犯。

牵连关系判断：数行为之间必须具有内在的、必然的联系。不能仅因"为了犯A罪而实施了B罪"就认定为牵连犯——如果B罪不是A罪的通常手段行为，则不应认定为牵连犯，而应数罪并罚。

💡 牵连犯=你干了两件事，但这两件事是"一条龙服务"——前一件是后一件的必经之路或自然结果。就像伪造了假钞又去用假钞——两个罪名但按一个重罪罚。

全章综合

罪数四大类型核心对比——填空。

	行为数	罪名数	处理
单纯的一罪	一	一	适用一个法条
包括的一罪	数	数（整体为一）	适用一个法条
科刑的一罪	一或数	数	从一重处断
并罚的数罪	数	数	数罪并罚

...

快速识别口诀：一行为一法益=单纯；数行为一评价=包括；一行为数法益=想象竞合；数行为数法益有牵连=牵连犯；数行为数法益无牵连=并罚。

💡 罪数论的核心：一个行为还是数个行为？数个行为之间有牵连吗？有牵连→科刑一罪；无牵连→并罚数罪。

自测卡专区

辨析题。甲入户盗窃，破坏门锁进入室内，窃取现金5000元。甲的行为构成几个罪？如何处理？

- A. ✖
- B. 盗窃罪一罪——入户是盗窃罪的加重情节，破坏门锁是共罚的事前行为 ✔（非法侵入住宅+故意毁坏财物都被包括在"入户盗窃"的评价中——属于包括的一罪）
- C. ✖（牵连犯=数行为数罪名，但这里不是"从一重"，而是只定一罪）
- D. ✖（数行为，不是一行为）

答案：B

...

💡 入户盗窃=非法侵入+毁坏财物+盗窃。分开看三个罪，合起来看是一个盗窃罪的"完整套餐"。这就是包括的一罪——整体评价为一罪，不需要拆开罚。

辨析题。甲开一枪，子弹穿透乙的身体后又击中丙，乙死亡、丙重伤。甲的行为如何定罪？

- A. ✖（一行为，不能数罪并罚）
- B. ✖（不是牵连犯——只有一个行为）
- C. 故意杀人罪与故意伤害罪的想象竞合——从一重（故意杀人） ✔（一个自然意义上的行为+触犯数罪+侵害数个法益=想象竞合）
- D. ✖（甲对丙的伤害结果至少有过失——应当预见到子弹可能穿透）

答案：C

...

💡 想象竞合=一行为触犯数罪。关键判断：是不是"一个行为"？开一枪=一个行为。这一枪造成了两个法益侵害结果=触犯两个罪名。处理：从一重罪处罚（故意杀人），不并罚。

辨析题。持续犯与状态犯的核心区别是什么？关于非法拘禁的持续性问题，以下哪一说法正确？

- A. ✖（方向反了：持续犯=实行行为+不法状态同时持续；状态犯=只有不法状态在持续，行为已终了）
- B. ✖（中间有间断的，司法实践一般认定为一罪，非法拘禁时间为3+4=7天）
- C. 在持续犯行为持续期间参与犯罪→成立共同正犯或帮助犯 ✔
- D. ✖（从犯罪行为终了之日起算——刑法第89条）

答案：C

...

💡 继续犯（持续犯）三个要点：①行为在持续——不只是结果在持续（区别于状态犯）；②持续期间加入=共犯；③追诉时效从终了日起算。

辨析题。关于法条竞合中的逻辑关系，下列哪一处理正确？

- A. 故意杀人罪与故意伤害罪——交叉关系→想象竞合 ❌（故意杀人罪与故意伤害罪=包容关系，不是交叉——所有故意杀人都触犯故意伤害，但反过来不成立→法条竞合，特别法优于普通法）
- B. 盗窃罪与诈骗罪——包容关系→法条竞合 ❌（盗窃与诈骗=对立关系——不可能同时触犯→不是法条竞合）
- C. 故意杀人罪与故意毁坏财物罪——中立关系→法条竞合 ❌（中立关系→张明楷认为应认定为想象竞合，不是法条竞合）
- D. 放火罪第114条与第115条——包容关系→法条竞合 ✅（以第114条为基准，它包含了第115条的行为——补充关系）

答案：D

...

💡 只有包容关系才成立法条竞合。四个关系口诀：对立（水火不容）→不可能；交叉（部分重叠）→想象竞合；中立（八竿子打不着但行为碰巧都触犯了）→想象竞合；包容（A全在B里）→法条竞合。

快速自测——第九章核心概念速查。

- 1. 四种罪数类型：单纯的一罪、包括的一罪、科刑的一罪、并罚的数罪
- 2. 继续犯的三个特征：实行行为+不法状态同时继续、在一定时间内持续、侵犯同一法益
- 3. 法条竞合只有包容关系才成立；交叉和中立应认定为想象竞合
- 4. 包括的一罪典型：共罚的事前行为和事后行为
- 5. 想象竞合=一行为触犯数罪名→从一重处罚
- 6. 牵连犯=数行为+数罪名+有牵连关系→从一重处罚

...

💡 六问全对=第九章通关。罪数论就两件事：判几罪（一罪还是数罪）+ 怎么罚（一罚还是并罚）。判断流程：看行为数→看关系（包容/牵连/独立）→确定类型→决定处理。

连续犯——填空。

连续犯=基于同一的或者概括的犯罪故意，连续实施性质相同的数个行为，触犯同一罪名的犯罪。

四个特征：

1. 基于同一或概括的故意
2. 实施性质相同的数个行为
3. 数次行为具有连续性
4. 触犯同一罪名

对于侵犯个人专属法益的犯罪（如轻伤），宜采取同一法益说——连续伤害三个不同人=认定为同种数罪并实行并罚。

...

连续犯的处理：一般以一罪论处。刑法第89条：犯罪行为有连续状态的，追诉期限从行为终了之日起算。对于侵犯非专属法益的犯罪（如财产犯罪），连续诈骗不同被害人的=认定为连续犯，以一罪论处，累计数额。

💡 连续犯=同一犯意下，反复干同一类事。关键区分：侵犯专属法益（人身）=同种数罪并罚；侵犯非专属法益（财产）=连续犯一罪。因为人身不可加总，财产可以累加。

集合犯——填空。

集合犯=犯罪构成预定了数个同种类行为的犯罪。三种类型：

- 常习犯：具有常习性的人反复实施（我国未规定）
- 职业犯：将犯罪作为职业/业务反复实施（如非法行医罪——刑法第336条）
- 营业犯：以营利为目的反复实施（如赌博罪"以赌博为业的"——刑法第303条）

营业犯与职业犯的共同点：都要求反复、多次实施的意思。区别：营业犯要求营利目的。

...

集合犯的处理：即使行为人实施了数次行为，也只成立一罪。只要行为人以反复实施的意思实施，第一次行为时就可能被认定为集合犯。不要求将犯罪行为作为唯一职业（可以是副业），也不要求不间断性（可以有间断）。

💡 集合犯=行为人的"职业习惯"。非法行医=职业犯（把犯罪当职业），赌博=营业犯（以营利为目的反复干）。都是一罪，不是数罪——因为刑法已经把"反复干这个"写进了犯罪模板里。

吸收一罪——填空。

吸收一罪=事实上数个不同的行为，其一行为吸收其他行为，仅成立吸收行为一个罪名。三种类型：

1. 附随犯：一个行为引起了数个法益侵害，附随对次法益的侵害不作为处罚（如开枪杀人同时毁损西服→只定故意杀人罪）
2. 发展犯：针对同一法益的犯罪，根据阶段发展形态设计为复数犯罪类型（如杀人预备→着手→既遂→只定既遂，之前的预备和未遂是共罚的事前行为）
3. 狭义的吸收犯：数个行为触犯不同罪名，但一行为包含另一行为（如伪造货币后出售/使用→只定伪造货币罪，不另定出售假币罪）

...

💡 吸收一罪="大鱼吃小鱼"。大罪把小罪的违法内涵都消化了，不需要再单独罚小罪。附随犯=附带伤害不单罚；发展犯=只罚最终形态；狭义吸收犯=伪造了假币又用了假币→只罚伪造（伪造包含了使用的典型风险）。

同种数罪 vs 异种数罪——填空。

同种数罪=行为人实施二次以上相同性质的行为，二次以上符合相同的犯罪构成。

异种数罪=行为人实施二次以上不同性质的行为，二次以上符合不同的犯罪构成。

处理原则：异种数罪必须并罚。同种数罪原则上应当并罚；但在判决宣告前发现的同种数罪可不并罚（但一罪论处不等于仅成立一罪）。

...

同种数罪不并罚的情形：刑法分则规定将"多次"作为一罪或法定刑升格条件的（如多次抢劫→适用加重抢劫一罪，不并罚）；数额犯累计计算时（如多次盗窃累计数额→一罪）。

💡 同种=重复干一样的事。原则上应并罚，但如果刑法本身把"多次"写进了犯罪模板（如多次抢劫=加重抢劫），就不用并罚——因为加重法定刑已经体现了对"多次"的评价。

辨析题。甲连续三天，每天盗窃不同被害人的财物，每次价值2000元（共计6000元），盗窃罪数额较大起点为3000元。对甲应如何处理？

- A. ✗（连续犯的数次行为不需要每次都独立构成犯罪——整体累计达到数额即可）
- B. ✗（财产犯罪=侵犯非专属法益→认定为连续犯，一罪论处）
- C. 构成盗窃罪的连续犯→累计数额6000元→以一罪论处 ✓
- D. ✗

答案：C

...

💡 财产犯罪采用"同种法益说"——不同被害人的财产可以累计计算，认定为连续犯一罪。人身犯罪采用"同一法益说"——连续伤害三个不同人=同种数罪并罚。区别在于：财产可以加总，人身不可加总。

快速自测——第九章全部核心概念速查（完整版）。

1. 单纯的一罪、包括的一罪、科刑的一罪、并罚的数罪
2. 实行行为+不法状态；只有不法状态
3. 包容；想象
4. 事前；事后
5. 想象；牵连
6. 同种数罪并罚；连续犯一罪
7. 职业犯（非法行医）+营业犯（赌博）
8. 附随犯+发展犯+狭义吸收犯

. . .

💡 八问全对=第九章通关。这八问覆盖第九章从罪数体系到具体类型的全部核心。